

고용노동부 정책연구용역보고서

근로감독 행정 제도적 기반 연구

2023. 12. .

연구수행기관: 한국노동법학회



근로감독 행정 제도적 기반 연구

책임연구원 노상헌 (서울시립대)

연구참여자 김홍영 (성균관대학교)

조용만 (건국대학교)

노호창 (호서대학교)

조재호 (법무법인 민)

목 차

I. 서론	1
1. 연구 목적 및 필요성	1
2. 연구 내용 및 방법	7
II. 근로감독에 관한 국제기준	9
1. 개요	9
2. ILO 제81호 협약의 취지 및 주요 내용	9
3. 우리나라 근로감독에 있어서 시사점	14
III. 외국법과의 비교 연구	15
1. 일본의 경우	15
2. 대만의 경우	26
3. 스페인의 경우	39
4. 검토 및 시사점	47
IV. 근로감독 법제화를 위한 입법이론	48
1. 규범제정에 관한 일반론	48
2. 의무이행확보를 위한 수단의 입법 및 검토	68
V. 근로감독 법제화 관련 현행 규범의 검토	80
1. 현행 법령상 근로감독의 법적 근거 및 근거 규정의 특징	80
2. 근로감독의 구체적 행위별 법적 성격	83
3. 권한의 근거 간에 있어서 법치행정 관점의 문제점	86
4. 근로감독관의 수사권한에 속하는 법규범의 종류에 관한 법률상 규정	89
5. 근로감독관의 수사 관련하여 형사법적 역량의 필요성과 중요성	93
6. 경찰의 수사권과 근로감독관의 수사권의 경합 문제	95
7. 특별사법경찰관리 법제와 비교·검토	99
8. 특별사법경찰관리에 관한 규정 비교	100
9. 검토 및 시사점	120

10. 소결	123
VI. 근로감독에 관한 근거 법률안 제시	125
1. 근로감독에 관한 법률안의 구체적 내용	125
2. 근로감독에 관한 법률의 입법 방향	142
참고문헌	144
[부록] 노동기준감독관 직무규정	148

I. 서론

1. 연구 목적 및 필요성

가. 연구 목적

헌법 제32조는 근로권 보장을 선언하면서 근로조건에 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정하도록 규정하고 있으며, 헌법 제33조는 노동3권을 보장하여 노동단체를 통한 노동자 권익 향상·유지 등을 구현하고 있으며, 이러한 목적과 취지를 구현하기 위하여 우리나라는 「근로기준법」, 「노동조합 및 노동관계조정법」 등을 위시하여 다양한 노동 관련법을 제정하여 실시하고 있다.

노동법의 올바른 적용과 집행을 위해서는 1차적으로 근로감독이 잘 작동하여야 함. 이러한 점에서 근로감독은 노동에 관한 헌법적 가치를 옹호하고 사회·노동정책을 집행하며 노동법의 준수를 감독하기 위한 정부의 공적 책무라 할 수 있다.

노동관계는 일반적인 계약관계와는 달리 당사자가 상호 대등하지 못할 가능성이 높기 때문에 노사간의 대등성을 확보하고 근로자의 인권과 권익을 보호하기 위해서는 국가 개입이 필요할 수 있고 근로감독은 그러한 국가 개입의 한 가지 예라고 할 수 있다.¹⁾ 즉 노동관계법의 올바른 적용과 집행을 위해서는 1차적으로 근로감독이 잘 작동하여야 한다. 특히 근로감독이 무엇 때문에 존재하는지 그 스스로의 존재취지에 대한 명확한 인식이 필요하다.

예컨대, 스페인의 근로감독법(노동사회보장감독법)이라든가 대만의 근로감독법에서 그 단초를 찾아볼 수 있다.

... sin duda se encuentra el derecho que tiene todo trabajador a recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando considere que sus derechos han sido conculcados. (의심할 바 없이, 노동자의 권리가 짓밟혔다고 생각할 때, 모든 노동자가 가지는 노동사회보장감독에 호소할 권리가 발견된다.)

- 스페인 노동사회보장감독법 서문

1) 노상현, “근로감독관제도의 재검토와 과제”, 「노동법학」 제42호, 한국노동법학회, 2012, 181면.

第一條

為實施勞動檢查，貫徹勞動法令之執行、維護勞雇雙方權益、安定社會、發展經濟，特制定本法。(근로감독을 실시하고 노동법령의 집행을 관철하고 노사쌍방의 권익을 유지·보호하고 사회를 안정시키고 경제를 발전시키기 위하여 특별히 본법을 제정한다.)

- 대만 근로감독법(勞動檢查法)

다음 표 1, 2에서 보는 바와 같이 연간 근로감독을 통해 처리되는 사건 수는 대단히 많고 이 많은 노동사건들이 모두 근로자의 권익보호와 관련성이 있다.

<표 1> 연도별 신고사건 처리유형별 현황(단위: 건수, %)²⁾

구분	접수	처리	행정종결	사법처리
2011년	303,293	305,657(100.0)	224,327(73.4)	81,330(26.6)
2012년	320,582	323,133(100.0)	236,382(73.2)	86,751(26.8)
2013년	329,261	334,007(100.0)	244,844(73.3)	89,163(26.7)
2014년	331,370	336,308(100.0)	248,680(73.9)	87,628(26.1)
2015년	341,704	343,731(100.0)	259,611(75.5)	84,120(24.5)
2016년	363,291	366,361(100.0)	279,698(76.3)	86,663(23.7)
2017년	372,330	374,006(100.0)	294,525(78.7)	79,481(21.3)
2018년	390,736	399,207(100.0)	318,153(79.7)	81,054(20.3)
2019년	403,023	417,708(100.0)	335,764(80.4)	81,944(19.6)
2020년	364,355	380,138(100.0)	313,462(82.5)	66,676(17.5)
2021년	314,308	322,994(100.0)	271,119(83.9)	51,875(16.1)
2022년	305,519	310,805(100.0)	267,987(86.2)	42,818(13.8)

2) 고용노동부, 「고용노동백서 2023」, 2023. 7, 251면.

<표 2> 연도별 사업장 감독 및 자율점검 등 실적³⁾

구분	총계		감독				노무관리 지도	기타 (자율 점검 등)
	사업장 수	증감률		정기	수시	특별		
2011년	39,980	14.1	23,688	17,157	6,511	20	-	16,292
2012년	31,048	▽22.3	21,719	7,093	14,424	202	-	9,329
2013년	22,245	▽28.4	13,280	5,844	7,386	50	-	8,965
2014년	24,281	12.2	16,889	1,897	14,985	7	-	7,392
2015년	29,425	18.9	19,536	5,873	13,651	12	-	9,889
2016년	31,867	7.4	22,094	6,297	15,770	27	-	9,773
2017년	29,454	▽7.6	22,574	5,869	16,604	101	-	6,880
2018년	34,594	17.5	26,082	21,751	4,319	12	-	8,512
2019년	35,077	1.4	25,415	20,714	4,666	35	-	9,662
2020년	25,686	▽26.8	5,740	3,625	2,110	3	10,057	9,889
2021년	33,319	29.7	11,191	7,471	3,711	9	11,061	11,067
2022년	38,892	16.7	27,180	22,416	4,753	11	-	11,712

※ 2020년, 2021년은 코로나19에 따른 현장 여건 등을 고려하여 감독 대상 조정

※ 2022년은 노무관리지도를 노무관리지도·점검(정기감독)으로 개편 시행

근로감독은 노동에 관한 헌법적 가치를 옹호하고 사회·노동정책을 집행하며 노동법의 준수를 감독하기 위한 정부의 공적 책무라 할 수 있다. 특히 정부의 노동존중사회 실현을 위한 정책 추진과 국민들의 성숙해진 노동존중의식에 힘입어 근로감독행정의 선진화에 대한 기대는 상당한 실정이다.

근로감독의 질적 향상은 국민의 노동에 대한 높아진 의식은 물론이고 우리나라의 국제적 위상을 고려하여 ILO(국제노동기구) 등이 제시하는 국제적 기준에도 부합하는 수준에 이르러야 할 것이다. 그와 관련하여 ILO의 근로감독에 관한 협약의 한 대목을 보면 참조가 될 것이다.

3) 고용노동부, 「고용노동백서 2023」, 2023. 7, 253면.

ILO 제81호 근로감독 협약 (C 81 Labour Inspection Convention, 1947)

제3조. 1. 근로감독제도는 다음의 기능을 수행하여야 한다.

- (가) 근로시간, 임금, 안전, 건강 및 복지, 아동 및 연소자의 고용, 그 밖의 관련 사항에 관한 규정 등 근로조건 및 작업 중인 근로자 보호에 관한 법규정이 근로감독관에 의해 집행가능한 한도 내에서 집행되도록 보장할 것.
 - (나) 사용자 및 근로자에게 법규정을 준수하는 가장 효과적인 방법에 관하여 기술적 정보와 조언을 제공할 것.
 - (다) 현행 법규정에 구체적으로 규정되어 있지 않은 결함이나 폐해에 관하여 권한 있는 기관에 알릴 것.
2. 근로감독관에게 부여될 수 있는 추가적 임무는 근로감독관이 주된 임무를 효과적으로 수행하는 데 지장을 주어서는 안 되며, 어떠한 경우에도 사용자 및 근로자와의 관계에서 근로감독관에게 필요한 권위 및 공정성을 해하여서는 안 된다.

오늘날 법제도의 변화 및 기술발달 등으로 인해 노동현장이 과거와 달리 복잡하고 다양해진데다 그 변화의 속도와 폭 역시 예측하기 어려울 정도로 빠르고 넓다. 근로시간 단축, 직장 내 괴롭힘 금지, 적정임금 보장, 고용안정성 보장, 부당노동행위 등 노동 현안에 대한 관심으로 근로감독 행정에 대한 기존 사업장 내에서의 수요가 증가하고 있다. 최근에 들어서는 플랫폼 노동과 같이 새로운 고용형태의 확산으로 노동보호의 사각지대 확대에 대한 우려가 커지고 있으며, 코로나-19 창궐에 의한 경기 침체 및 그에 따른 일자리 부족과 이로 인한 노사갈등 증가 등 노동사건이 점차 복잡하고, 다양해지고 있는 추세에 있다. 현장의 변화를 따라잡고 법제도의 변화에 적응할 수 있도록 근로감독의 변화와 개선이 요구되는 시점이기도 한다.

근로감독은 구체적으로는 근로감독관에 의해 수행되고 있다. 근로감독관은 근로시간, 임금, 노동3권 등에 관한 국내 노동기준이 산업 현장에서 어떻게 적용되는지를 조사하고 그 적용의 개선방법에 대하여 행정적 관점에서 조언·지도하며, 현장조사 기타 자료제출 요구, 심문이나 검진 등 권력적·비권력적 사실행위를 하기도 하고 경우에 따라서는 법령상 근거에 따라 시정명령 등 행정처분을 내리거나 시정지시를 하기도 한다. 아울러 사법경찰관으로서 형벌에 의해 강제되는 노동법의 집행을 사법적 관점에서 보장하기 위한 전단계의 중요한 역할을 수행한다.

그러나 근로감독의 개념 자체는 법률에 정의된 바 없고 근로감독관의 권한만 몇 가지 법률에 규정되어 있을 뿐이라 근로감독의 개념이 정확히 어느 범위까지 포섭될 수 있는지 법률상 불분명한 실정이다. 고용노동부소관의 법률만 40여가지가 넘는 상황에서 소관 부처는 당연히 소관 법률의 준수 및 집행에 대한 행정감독권한을 가지고 있는데 이러한 일반적인 행정감독권한에 의해 수행되는 행정감독과 근로감독이 그 경계나 범위가 모호하다. 행정감독이 모두 근로감독에 속한다고 볼 수 있는 것인지 아니면 근로감독도 일반적 행정감독에 포함되는 것인지 의문이 있는 상황이다.

정부의 노동존중사회 실현을 위한 정책 추진과 국민들의 성숙해진 노동존중의식에 힘입어 근로감독행정의 효율화 선진화에 대한 기대는 상당한 실정이다. 이에 근로감독 업무 수행 및 노동관계법령 위반 사건의 수사 등을 수행하기 위해 근로감독관 규모가 꾸준히 증가해오는 등 근로감독에 관한 양적 성장은 어느 정도 달성되었고, 2019년 4월 근로감독정책단의 신설 및 관련 정책연구 실시 등 근로감독행정 개선을 위한 정부의 지속적 노력이 있었다. 다만 양적 성장에도 불구하고 질적 성장이 이에 미치지 못하고 있다는 지적이 제기되고 있는 실정이다. 이 와중에 2023년 근로감독정책단마저 해체되어 근로기준국 산하로 근로감독 업무가 복귀된 바 있다.

<표 3> 근로감독관 정원 현황(근로기준 분야)⁴⁾

연 도	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'22년
정원	1,243	1,282	1,450	1,902	2,213	2,290	2,283

근로감독의 질적 성장은 근로감독의 본질적 기능인 노동기준의 준수를 통한 사고 및 분쟁의 예방에 충실할 수 있는 근로감독 행정체계 구축을 통해 달성되어야 한다. 나아가 근로감독의 질적 성장은 높아진 국민의 노동에 대한 의식은 물론이고 우리나라의 국제적 위상을 고려하여 ILO 등이 제시하는 국제적 기준에도 부합하는 수준에 이르러야 할 것이다.

근로감독 행정이 이러한 문제에 적절하게 대응하기 위해서는 양적으로 성장한 근로감독관을 적극적으로 활용하기 위한 체계를 구비하여야 한다. 이는 근로감독

4) 고용노동부, 「고용노동백서 2023」, 2023. 7, 250면.

행정의 체계화의 관점은 물론이고 근로감독관 개인의 전문성 강화의 관점도 고려하여야 한다. 특히 근로감독의 결과 경우에 따라서는 근로감독관의 권한 행사를 통해 형사사건으로 이행될 여지도 있어 조사, 심문 등 전문적 능력의 향상이 필요하고 특별사법경찰관으로서의 역할이 중요해지기 때문에 노동관계법 위반죄 여부에 대한 판단을 위한 기본적인 형사법적 역량이 요구되고 있기도 하다.⁵⁾

예컨대, 특히 피해자가 장애인 근로자인 경우 고용, 착취, 돌봄이 혼재하고 있어서 조사 기법이 비장애인 근로자의 경우와 동일할 수도 없을 것이다.

나. 연구 필요성

근로시간 단축, 직장 내 괴롭힘 금지, 적정임금 보장, 고용안정성 보장, 부당노동행위 등 노동 현안에 대한 관심으로 근로감독 행정에 대한 기존 사업장 내에서의 수요가 증가하고 있고, 최근 들어서는 플랫폼 노동과 같이 새로운 고용형태의 확산으로 노동보호의 사각지대 확대에 대한 우려가 커지고 있으며, 코로나 창궐 및 포스트 코로나 이후 경기 침체 및 그에 따른 일자리 부족과 이로 인한 노사갈등 증가 등 노동사건이 점차 복잡하고, 다양해지고 있는 추세에 있다.

근로감독 행정이 이러한 문제에 적절하게 대응하기 위해서는 양적으로 성장한 근로감독관을 적극적으로 활용하기 위한 체계를 구비하여야 한다. 이는 근로감독 행정의 체계화의 관점은 물론이고 근로감독관 개인의 전문성 강화의 관점에서도 개선방안의 법제도적 기반을 모색할 필요가 있다.

근로감독 결과 경우에 따라서는 근로감독관의 권한 행사를 통해 형사사건으로 이행될 여지도 있어 조사, 심문 등 전문적 능력의 향상이 필요하고 특사경으로서의 역할이 중요해지기 때문에 노동관계법 위반죄 여부에 대한 판단을 위한 기본적인 형사법적 역량이 요구되고 있기도 함. 따라서 그러한 역량 강화의 법적 근거가 필요하다.

노동존중사회 실현이라는 시대적 가치 및 고용형태의 다변화, 기술발달에 따른 노동보호의 사각지대 확대 등으로 인해 근로감독 업무의 중요성이 강조되고 있으나, 여전히 근로감독 행정의 선진화는 미흡한 실정인바, 이를 개선하기 위해서는 근로감독 행정의 체계화 및 근로감독관의 전문화라는 관점에서 우리나라 근로감독

5) 고용노동부, 「고용노동백서 2023」, 2023. 7, 250면.

행정의 선진화를 위한 법제도적 기반의 구축이 요구된다.

산업전환, 플랫폼 노동 등 일하는 형태 다변화 등 노동환경 변화 속에서 취약 계층을 두텁게 보호하기 위해, 체계적이고 전문적인 근로감독 행정을 뒷받침할 법제도적 기반을 위한 연구가 필요하다.

근로감독 제도는 「근로기준법」 등 19개 노동관계법령에서 정한 근로조건이 실제 사업장에서 제대로 보장·이행되고 있는지 관리·감독하는 핵심수단이나, 현재 근로감독 제도는 「근로기준법」 내의 1개 장(6개 조문) 및 「최저임금법」에서 단편적으로 근거하고 있는 실정이라 근로감독의 선진화, 체계화, 첨단화 등을 위한 법제도적 기반이 매우 취약한 실정이다. 근로감독의 개념, 종류, 내용에 대해서는 훈령에 해당하는 「근로감독관집무규정」에 근거하고 있는 것도 법치행정의 원리, 법체계적 정당성 등 법적 관점에서 문제로 볼 수 있다.

2. 연구 내용 및 방법

가. 연구 내용

첫째, 본 연구에서는 근로감독에 관한 국제기준을 검토한다. 특히 ILO 제81호 협약의 취지와 주요 내용을 살펴보고, 우리나라 근로감독에 있어서의 시사점을 도출한다.

둘째, 본 연구에서는 외국법과의 비교연구를 검토한다. 기존 연구에서 여러 국가의 법제도에 관한 연구가 이루어져왔으나, 본 연구에서는 근로감독 법제화를 위한 목적에 부합하기 위해, 일본 외에도 대만 및 스페인의 근로감독법제를 살펴본다. 이를 통해 근로감독 법제화를 위한 시사점을 도출한다.

셋째, 본 연구에서는 근로감독 법제화를 위한 입법이론을 연구한다. 구체적으로는 i) 규범제정에 관한 일반론 및 ii) 의무이행확보를 위한 수단의 입법 및 검토를 한다.

넷째, 본 연구에서는 근로감독 법제화 관련 현행 규범에 대해 검토한다. 「근로기준법」, 「근로감독관집무규정」 등 현행 법규정의 내용을 체계적으로 분석한다. 아울러 수사권과 관련한 법령과 특별사법경찰관리에 관한 법령들을 검토하고 이로부터 시사점을 도출한다.

다섯째, 본 연구의 결론으로서 근로감독에 관한 근거 법률안을 제시한다. 근로감독에 관한 별도의 법률의 제정은 많은 논의과정을 거쳐야한다는 현실적인 고려에서 현행 「근로기준법」 제11장에 근로감독에 관한 규정을 보완하는 법개정 방식으로 법제화를 검토한다.

나. 연구 방법

본 연구에서는 문헌 연구 및 자료 조사 등을 통한 실증적 연구를 병행한다. 일본, 대만, 스페인 등의 법제에 대한 비교법적 연구를 포함한다.

II. 근로감독에 관한 국제기준

1. 개요

ILO는 근로감독에 관한 몇 가지 협약을 채택한 바 있다. 기본적으로는 1947년 제81호 근로감독협약을 채택하였고 농업 부문에 대해서는 1969년 제129호 근로감독(농업)협약을, 1996년 제178호 근로감독(선원)협약을 채택한 바 있다.

우리나라는 1992년 ILO 제81호 협약을 비준한 바 있고 발효 중이다.⁶⁾

2. ILO 제81호 협약의 취지 및 주요 내용

ILO 제81호 협약(C 81 Labour Inspection Convention, 1947)은 공업(industry) 및 상업(commerce) 부문 사업장에서 근로조건과 근로자 보호에 관한 법규정 집행을 보장하기 위한 근로감독 체계를 제공하기 위한 것이다. 기본적으로는 공업 부문 사업장에서의 근로감독에 필요한 사항들을 명시하고 이를 상업 부문 사업장에도 준용하는 방식으로 규정되어 있다.

제81호 협약은 감독기능 및 조직, 중앙기관의 책임, 감독관과 공·사 기관, 사용자·근로자 또는 노사단체와의 협력, 여성을 포함한 충분한 수의 감독관의 채용, 감독관의 적절한 지위, 사무실과 교통수단 등 물질적 수단 및 장비, 철저하고 정기적인 사업장의 감독, 감독작업에 관한 보고서 및 연간 통계 출간 등을 규정하고 있다. 근로감독관의 기능 및 권한과 관련하여서는, 그의 기능(법규정 집행 보장, 사용자와 근로자에게 자문 제공, 권한 있는 기관에 정보 제공) 및 권한, 감독대상인 사업장에 자유롭게 출입할 수 있는 권한, 자유롭게 조사 특히 신문할 수 있는 권한, 서류 검토, 견본수거의 권한, 결함 시정에 관한 명령을 내리거나 경고 혹은 조건의 적절성 여부를 결정하거나 절차이행 또는 추천할 권한을 규정하고 있다. 또한 근로감독관의 준수사항으로 근로감독관은 감독을 받는 사업체에 대하여 직·간접적인 이해관계를 가져서는 안되며 업무처리 중 알게 된 제조상·영업상 비밀 또

⁶⁾ https://www.ilo.org/gateway/faces/home/standards?_adf.ctrl-state=7tbct9re_9&locale=EN&countryCode=KOR (국제노동기구, 한국 비준 현황, 최종방문 2023. 10. 27)

는 진정한 출처를 누설하여서는 안 된다는 점도 명시하고 있다. 몇 가지 주요 조문을 예시하면 다음과 같다.

제1조. 이 협약의 적용을 받는 국제노동기구의 회원국은 공업 사업장(industrial workplaces)에서 근로감독 제도를 갖추어야 한다.

제2조. 1. 공업(industrial) 부문 사업장의 근로감독제도는 근로감독관(labour inspector)에 의해 해당 사업장 관련 근로조건 및 작업중인 근로자 보호에 관한 법규정 집행이 가능한 모든 사업장에 적용되어야 한다.
2. 광업 및 운송업체 전체 또는 일부는 국내법규에 따라 이 협약의 적용을 면제받을 수 있다.

제3조. 1. 근로감독제도는 다음의 기능을 수행하여야 한다.
(가) 근로시간, 임금, 안전, 건강 및 복지, 아동 및 연소자의 고용, 그 밖의 관련 사항에 관한 규정 등 근로조건 및 작업중인 근로자 보호에 관한 법규정이 근로감독관에 의해 집행가능한 한도 내에서 집행되도록 보장할 것.
(나) 사용자 및 근로자에게 법규정을 준수하는 가장 효과적인 방법에 관하여 기술적 정보와 조언을 제공할 것.
(다) 현행 법규정에 구체적으로 규정되어 있지 않은 결함이나 폐해에 관하여 권한 있는 기관에 알릴 것.
2. 근로감독관에게 부여될 수 있는 추가적 임무는 근로감독관이 주된 임무를 효과적으로 수행하는 데 지장을 주어서는 안 되며, 어떠한 경우에도 사용자 및 근로자와의 관계에서 근로감독관에게 필요한 권위 및 공정성을 해하여서는 안 된다.

제4조. 1. 회원국의 행정관행에 양립하는 한, 근로감독은 중앙당국(central authority)의 감독 및 관리 하에 두어야 한다(So far as is compatible with the administrative practice of the Member, labour inspection shall be placed under the supervision and control of a central authority.).
2. 연방국가의 경우 ‘중앙당국’이라 함은 연방당국 또는 연방구성단위의 중앙당국을 의미할 수 있다.

제5조. 권한있는 기관은 다음 사항을 촉진하기 위하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

(가) 근로감독기관과 유사한 활동에 관여하는 그 밖의 정부기관 및 공공·민간 기관간의 효과적 협력.

(나) 근로감독기관의 감독관과 사용자 및 근로자와의 협력 또는 이들 단체와의 협력.

제6조. 근로감독관은 신분 및 근무조건에 있어서 고용의 안정성이 보장되고 정권 교체 및 외부의 부당한 영향으로부터 독립적인 공무원으로 구성되어야 한다.

제7조. 1. 근로감독관은 국내법규에 규정되어 있을 수 있는 공무원 채용조건에 따라 그들의 임무를 수행하기 위하여 필요한 능력만을 고려하여 채용되어야 한다.

2. 상기 능력을 확인하는 방법은 권한 있는 기관이 결정하여야 한다.

3. 근로감독관은 임무수행을 위하여 적절한 훈련을 받아야 한다.

제8조. 남녀 모두 감독관으로 임명될 수 있어야 하며, 필요한 경우 남녀 감독관에게 특별한 임무가 부여될 수 있다.

제9조. 회원국은 작업중인 근로자의 건강과 안전 보호에 관한 법규정 집행을 보장하고, 작업공정과 재료, 방법이 근로자의 건강과 안전에 미치는 영향을 조사하기 위하여, 국내여건상 가장 적절하다고 생각되는 방법으로 의학·공학·전기·화학 분야 전문가를 포함한 적절한 절차에 따라 자격을 인정받은 기술자 및 전문가가 감독업무에 관여하도록 하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제10조. 근로감독관 수는 감독 임무의 효과적 수행을 보장하기 위하여 충분한 인원이어야 하며, 다음 사항을 적절히 고려하여 결정되어야 한다.

(가) 감독관이 수행하여야 하는 임무의 중요성, 특히

(1) 감독대상 사업장의 수와 성격, 규모, 위치

(2) 이들 사업장에 고용된 근로자의 수와 직급

(3) 집행될 법규정의 수와 복잡함의 정도

(나) 감독관이 사용할 수 있는 물적수단.

(다) 효과적 감독을 위하여 임검(臨檢, visits of inspection)이 요구되는 실제적 조건.

제12조. 1. 적절한 증명서를 소지하고 있는 근로감독관에게 다음과 같은 권한이 부여되어야 한다.

(가) 감독대상인 사업장에 주야 어느 시간이든 예고없이 자유롭게 출입할 수 있는 권한

(나) 감독대상이라고 인정할 만한 합당한 사유가 있는 부지에 주간에 출입할 수 있는 권한

(다) 법규정의 엄격한 준수 여부를 확인하기 위하여 필요한 조사, 검사 또는 실험을 할 수 있는 권한, 특히

(1) 법규정의 적용에 관련된 사항에 대하여 단독으로 또는 증인의 입회하에 사용자 또는 사업체 직원을 신문할 권한

(2) 근로조건이 법규정에 부합하는지 여부를 확인하기 위하여 근로조건 관련 국내법규에 따라 비치하여야 할 장부, 대장 또는 그 밖의 서류의 제출을 요구하고, 이들 문서를 복사하거나 발췌할 권한

(3) 법규정에서 요구하는 고지사항을 게시하도록 할 권한

(4) 분석을 목적으로 수거하는 샘플과 물질을 사용자 또는 그 대리인에게 통고하는 것을 조건으로, 사용 또는 취급되는 원료의 견본 및 물질을 분석하기 위하여 수거할 권한

2. 근로감독관이 임검(臨檢, inspection visit)을 하는 경우, 통고하는 것이 감독관의 임무수행에 방해가 될 수 있다고 생각되지 않는 한 임검(臨檢)계획을 사용자 또는 그 대리인에게 통고하여야 한다.

제13조. 1. 근로감독관은 시설, 배치 또는 작업방법에서 발견된 결함이 근로자의 건강 또는 안전을 위협한다고 믿을 만한 합당한 이유가 있을 때 이를 시정하기 위한 조치를 취할 권한을 가져야 한다.

2. 감독관은 위 조치를 취하기 위하여 다음 사항을 요구하는 명령을 내릴 권한을 가져야 한다. 다만, 사법 또는 행정기관에 이 명령에 대한 이의를 제기할 권리가 주어져야 하고, 이 이의제기권은 법에 규정되어 있을 수 있다.

(가) 근로자의 건강 또는 안전에 관련된 법규정 준수를 확보하기 위하여 필요한

경우 일정한 기간 안에 시설 또는 설비를 변경하도록 하는 조치.

- (나) 근로자의 건강 또는 안전에 급박한 위험이 있을 경우 즉각적 집행효력을 가지는 조치.

3. 제2항에 정한 절차가 회원국의 행정 또는 사법관행과 양립하지 않는 경우 감독관은 권한 있는 기관에 명령 또는 즉각적 집행효력을 가지는 조치의 시행을 요청할 권리를 가져야 한다.

제15조. 국내법규로 정할 수 있는 예외를 제외하고는, 근로감독관은

- (가) 자신의 관할하에 있는 기업체에 대하여 직접 또는 간접적 이해관계를 가지는 것이 금지되어야 한다.
- (나) 감독관직을 사퇴한 후에도 임무수행 중 알게 된 제조상·영업상 비밀 또는 작업공정을 누설하지 않도록 하기 위하여 (위반하는 경우) 적절한 처벌 또는 징계처분 대상이 되어야 한다.
- (다) 법규정의 결함 또는 위반에 관하여 감독관에게 제기되는 진정의 출처를 극비로 취급하여야 하며, 이러한 진정에 따라 임검(臨檢)을 하였음을 사용자 또는 그 대리인에게 시사해서는 안 된다.

제16조. 관련 법규정의 효과적 적용을 위하여 필요한 경우 사업장을 수시로 철저하게 감독하여야 한다.

제17조. 1. 근로감독관이 집행하는 법규정을 위반하거나 이의 준수를 태만히 한 사람은 사전경고 없이 즉각적 사법절차의 대상이 되어야 한다. 다만, 시정조치 또는 예방조치를 이행하기 위한 사전 안내가 주어지는 경우에 대하여 국내법규로 예외를 정할 수 있다.

2. 사법절차를 개시하거나 권고하는 대신 경고 및 조언을 하는 것은 근로감독관 재량사항이어야 한다.

제18조. 근로감독관이 집행하는 법규정 위반 및 그 임무수행의 방해에 대해서는 국내법규로 적절한 벌칙을 정하고 이를 효과적으로 집행하여야 한다.

제22조. 이 협약 제2절의 적용을 받는 국제노동기구의 회원국은 상업부문 사업장(commercial workplaces)에 근로감독제도를 두어야 한다.

제24조. 상업부문 사업장의 근로감독제도는 적용 가능한 한 협약의 제3조 내지 제21조의 규정을 따라야 한다.

3. 우리나라 근로감독에 있어서 시사점

ILO 제81호 협약은 근로감독의 주요 기능, 역할, 집행의 중심, 근로감독관의 권한, 준수사항, 이의제기 등에 대해 상세히 그 원칙을 규정하고 있다. 대부분의 내용이 향후 우리나라에서 근로감독에 관한 법제화에 있어서 지향해야 할 지점이라고 볼 수 있다. 특히 중앙행정기관 중심 원칙은 지방자치제도가 활성화되어 있는 우리 현실에서 근로감독의 법제화에 있어서도 준수되어야 할 원칙일 것이다. 또한 근로감독에 대한 이의절차나 불복절차가 별도로 없는 상황에서 향후 법제화를 하는 경우 근로감독에 관한 이의절차나 불복절차를 둘 것인가 아니면 후속 절차에서 다투도록 할 것인가 등은 고민해야 할 지점이 될 것이다.

Ⅲ. 외국법과의 비교 연구

1. 일본의 경우

우리나라의 입법체계 전반에 걸쳐 다방면에 걸쳐 지대한 영향을 준 일본의 근로감독에 관한 규범적 상황을 살펴보지 않을 수 없다. 일본의 경우, 근로감독 관련하여 독립적인 근로감독만의 법률이 있지는 않지만, 근로감독관 설치 및 운용 법체계가 상당히 정비되어 있다. 예컨대, 1911년 제정되고 1916년 시행되었던 공장법(工場法)에서 근로감독의 근거를 처음 명시한 이래로⁷⁾ 1947년 제정된 노동기준법(労働基準法)에서⁸⁾ ‘후생노동성-도도부현 노동국(현재 47국) - 노동기준감독서(현재 321서+4지서)’ 체제의 노동기준감독 체계의 근거를 명시하고 구축하였다. 노동기준감독서는 도도부현 노동국의 지휘감독을 받고, 도도부현 노동국은 주로 후생노동성 노동기준국의 지휘감독을 받는다.

가. 노동기준감독관제도 도입

(1) 법적 근거

1911년 일본은 최초의 노동보호법인 공장법(工場法)을 제정하였고, 1916년에 시행되었다.⁹⁾ 공장법의 주요내용은 ① 15인 이상의 공장 적용, ② 최저취업연령 12세, ③ 최장근로시간 12시간(15세 미만 및 여성에게만 적용), ④ 월 2회의 휴일(15세 미만 및 여성에게만 적용), ⑤ 오후 10시부터 오전 4시까지의 심야업 금지(15세 미만 및 여성에게만 적용), ⑥ 업무상 질병이나 사망에 대한 본인 및 유족에 대한 부조 등이다.

7) 공장법(1911년 제정, 1916년 시행) 제14조 당해 관리는 공장 또는 그 외 부속건설물을 입검할 수 있다. 이 경우 그 증표를 휴대하여야 한다. 일본 공장법(1911년 제정, 1916년 시행)(https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000006288&ID=M0000000000001748214&NO=&TYPE=imagePrint&DL_TYPE=pdf, 일본 국립공문서관, 최종방문 2023. 2. 28.)

8) 일본 노동기준법(<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00000000049>, 일본 법령검색, 최종방문 2023. 2. 28.)

9) 渡辺章, “工場法史が今に問うもの”, 日本労働研究雑誌 제562호(2007.5), 102쪽.

공장법은 ‘노동보호’를 목적으로 법이라기보다는 인적 자원으로서의 ‘노동력보호’라는 관점에서 안전보건법에 해당하고, 법 시행을 관장하는 행정관청 설치가 규정되었다(공장법 제13·14조, 시행령 제41조). 1916. 1. 22. 도쿄경시청 및 오사카 등 8도부현 경찰부에 공장감독관을 설치하는 칙령을 공포하여 일본에서 처음으로 공장감독관제도가 도입되었다.

공장법(1911. 3. 28)

[제13조] 행정관청은 명령으로 정하는 바에 따라 공장 및 부속건물과 설비가 위험의 발생 또는 보건, 풍기 그밖에 공익을 해하는 우려가 있다고 인정되는 때에는 예방 또는 위해를 제거하기 위하여 필요한 사항을 공장주에게 명하고, 필요하다고 인정되는 때에는 그 전부 또는 일부의 사용을 정지할 수 있다.

[제14조] 당해 관리는 공장 또는 부속건물에 대하여 점검할 수 있고, 이 경우 그 증표를 휴대하여야 한다.

공장법 시행령(1916. 8. 2)

[제41조] 이 영에서 정하는 이외 주무대신 및 지방장관은 직공의 채용, 해고, 주선의 단속 그밖에 이 영 시행에 필요한 사항에 관하여 명령 발할 수 있다.

(2) 권한

공장법은 노동최저연령, 장시간 예방과 안전보건 확보를 목적으로, 행정관청(공장법의 주무관청은 내무성, 농상공부이다)으로 하여금 안전점검, 풍기 및 공익 확보를 위하여 사업주에 시정명령을 하거나 필요한 경우 사용중지명령을 발할 수 있는 권한을 부여하였다.

법 시행에 앞서 1915년 10월 농상공부 상공국에 공장과를 신설하고, 공장감독관 4명과 공장감독관보 5명을 임명하였다. 지방에는 당시 경찰행정이 정비된 경시청 및 각 부현(府縣) 경찰부(警察部)에 21명의 공장감독관과 178명의 공장감독관보를 임명하여 공장감독관 제도를 운영하게 되었다.¹⁰⁾ 이후 공장법에 따른 공장감독관

¹⁰⁾ 前田貴洋, “労働監督制度をめぐる戦前と戦後(2)”, 都法 제58권 제2호(2018.1), 221쪽

은 사무관 이외에 기사(技士), 위생기사, 의사 등이 임명되었으며, 감독관제도가 설치할 당시에는 감독관 1명이 담당하는 공장이 100개 정도였으나, 1930년대에는 230개가 넘게 되었다.¹¹⁾

나. 노동기준법 제정에 따른 노동기준감독기관 설치

일본은 패전 후 공장법을 폐지하고, 1947. 3. 37. 노동기준법을 제정하였다. 공장법에서 정한 공장감독관제도를 노동기준법 취지와 목적에 따라 ‘노동기준감독관제도’로 새롭게 재건하였다. 노동행정 담당기관은 노동성(본부)·도도부현 노동국(광역)·노동기준감독서(지역)로 구성되고, 노동기준감독서에 노동기준감독관을 배치한다.

(1) 법적 근거

노동기준법은 제11장에서 감독기관의 장을 두고, 제97조·제98조(노동기준위원회 설치-폐지)·제99조·제100조는 감독조직을, 제101조·제102조·제103조는 노동기준감독관의 권한을, 제104조는 감독기관에 대한 신고, 제105조는 노동기준감독관의 의무를 정하고 있다.

노동기준감독관의 권한 ① 사업장 등 현장조사 ② 법령위반에 대한 지도·감독 ③ 법령위반에 대한 조사·검찰송치 등이다.

제11장 감독기관

제97조(감독기관의 직원 등) ① 노동기준주관국(후생노동성 내부부국에 두는 국으로 노동조건 및 노동조건 및 노동자의 보호에 관한 사무 관장을 맡는다. 이하 같다), 도도부현 노동국 및 노동기준감독서에 노동기준감독관을 두며, 그 외 후생노동성령으로 정하는 필요한 직원을 둘 수 있다.

② 노동기준주관국의 국장(이하 「노동기준주관국장」이라 한다), 도도부현 노동국장 및 노동기준감독서장은 노동기준감독관으로 임명한다.

¹¹⁾ 大原クロニカ, 「社会・労働運動大年表」解説編, 工場監督官[政] 1915.12.25. (http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/khronika/1911-15/1915_17.html)

- ③ 노동기준감독관의 자격 및 임면에 관한 사항은 정령으로 정한다.
- ④ 후생노동성에 정령으로 정하는 바에 따라 노동기준감독관 분한심의회(分限審議會)를 둘 수 있다.¹²⁾
- ⑤ 노동기준감독관을 파면하려면 노동기준감독관 분한심의회의 동의를 필요하다.
- ⑥ 전2항에 정하는 외 노동기준감독관 분한심의회의 조직 및 운영에 관하여 필요한 사항은 정령으로 정한다.

제98조 삭제(제97조에 통합)

제99조(노동기준주관국장 등의 권한) ① 노동기준주관국장은 후생노동대신의 지휘감독을 받아 도도부현 노동국장을 지휘감독하고 노동기준에 관한 법령의 제정개폐, 노동기준감독관의 임면교양, 감독방법에 대한 규정의 제정 및 조정, 감독연보의 작성, 노동정책심의회 및 노동기준감독관 분한심의회에 관한 사항(노동정책 심의회에 관한 사항에 대해서는 노동조건 및 노동자의 보호에 관한 것에 한정한다) 그 외 이 법률 시행에 관한 사항을 관장하며 소속 직원을 지휘 감독한다.

② 도도부현 노동국장은 노동기준주관국장의 지휘감독을 받아 관내 노동기준감독서장을 지휘감독하고 감독방법의 조정에 관한 사항 그 외 이 법의 시행에 관한 사항을 관장하며 소속 직원을 지휘감독한다.

③ 노동기준감독서장은 도도부현 노동국장의 지휘감독을 받아 이 법에 따른 임검, 심문, 허가, 인정, 심사, 중재 그밖에 이 법의 실시에 관한 사항을 관장하며 소속 직원을 지휘감독한다.

④ 노동기준주관국장 및 도도부현 노동국장은 하급관청의 권한을 직접 행사하거나 소속 노동기준감독관으로 하여금 수행시킬 수 있다.

제100조(여성주관국장의 권한) ① 후생노동성의 여성주관국장(후생노동성의 내부부국으로 두는 국으로 여성노동자의 특성에 관련된 노동문제에 관한 사무를 관장하는 국장을 말한다. 이하 같다)은 후생노동대신의 지휘감독을 받아 이 법 가운데 여성에 관한 특수 규정의 제정, 개폐 및 해석에 관한 사항을 관장하며, 그 시행에 관한 사항에 대하여는 노동기준주관국장 및 그 하급의 관청의 장에게 권고를 하는 것과 더불어 노동기준주관국장이 그 하급의 관청에 대한

지휘감독을 원조한다.

② 여성주관국장은 그 지정하는 소속관리를 하여금 여성에 관하여 노동기준주관국 혹은 그 하급의 관청 또는 그 소속관리가 행한 감독 기타에 관한 문서를 열람하거나 열람시킬 수 있다.

③ 제101조 및 제105조의 규정은 여성주관국장 또는 그 지정하는 소속관리가 이 법 중 여성에게 특별한 규정의 시행에 관하여 조사하는 경우 이를 준용한다.

제101조(노동기준감독관의 권한) ① 노동기준감독관은 사업장, 기숙사 기타 부속건설물을 임검하며, 장부 및 서류의 제출을 요구하거나 사용자 또는 노동자에 대하여 심문을 할 수 있다.

② 전항의 경우 노동기준감독관은 그 신분을 증명하는 증표를 휴대하여야 한다.

제102조 노동기준감독관은 이 법 위반의 죄에 대하여 형사소송법에서 규정하는 사법경찰관의 직무를 수행한다.

제103조 노동자를 취업시키는 사업의 부속 기숙사가 안전 및 보건에 관하여 정해진 기준에 위반하거나 노동자에게 급박한 위험이 있는 경우 노동기준감독관은 제96조의3 규정에 따라 행정관청의 권한을 즉시 행사할 수 있다.

제104조(감독기관에 대한 신고) 사업장에 대하여 이 법 또는 이 법에 근거하여 발하는 명령에 위반하는 사실이 있는 경우에는 근로자는 그 사실을 행정관청 또는 노동기준감독관에게 신고할 수 있다.

제104조의2(보고 등) ① 행정관청은 이 법을 시행하기 위해 필요하다고 인정할 때에는 후생노동성령으로 정하는 바에 따라 사용자 또는 노동자에게 필요한 사항을 보고하게 하거나 출두를 명령할 수 있다.

② 노동기준감독관은 이 법을 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 사용자 또는 노동자에게 필요한 사항을 보고시키거나 출두를 명할 수 있다.

제105조(노동기준감독관의 의무) 노동기준감독관은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 안 된다. 노동기준감독관을 퇴직한 후에도 마찬가지이다.

(2) 노동기준감독기관령(1947. 9. 1)

1947. 9. 노동기준법이 시행됨에 따라 동법의 시행을 담당할 노동기준감독관의 임용과 신분을 보장하기 위한 분한심의회 설치 등을 정한 정령을 제정하였고, 현재에 이르고 있다.

제1조(노동기준감독관의 임용) 노동기준감독관은 국가공무원법(1947년 법률 제120호)이 정하는 바에 따라 실시되는 노동기준감독관 채용시험에 합격한 자 중에서 임용한다. 다만, 일반직 직원의 급여에 관한 법률(1950년 법률 제95호) 제6조제1항제1호 가목에서 규정하는 행정직 봉급표(1)에서 정하는 직무의 급이 4급 이상인 자 또는 동표의 적용을 받고 또한 후생노동대신이 정하는 조건에 해당하는 자를 임용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2조(노동기준감독관 분한심의회 설치 등) ① 노동기준감독관 분한심의회는 노동기준법(1947년 법률 제49호) 제97조제5항의 규정에 의한 동의를 필요로 하는 사안이 발생한 경우에 둔다.

② 노동기준감독관 분한심의회는 9인의 위원으로 조직하여 노동기준법 제97조제5항의 규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항을 처리한다.

③ 노동기준감독관 분한심의회 위원은 제1항의 사안이 생긴 경우에 후생노동대신이 임명한다.

④ 노동기준감독관 분한심의회 위원은 노동정책심의회에서 노동자를 대표하는 위원, 사용자를 대표하는 위원 및 공익을 대표하는 위원 중에서 각 위원별로 호선된 각 1인 및 학식경험자(후생노동대신이 미리 작성한 노동기준감독관 분한심의회 위원후보자 명부에 기재되어 있는 것에 한정한다.) 중에서 6명을 임명한다.

⑤ 노동기준감독관 분한심의회 위원은 제1항의 사안과 관련된 처리가 종료한 때에는 해임한다.

¹²⁾ 분한(分限)이란 신분보장의 한계라는 의미이고, 처분이라 함은 공무의 능률유지 및 적정한 운영의 확보라는 관점에서 행해지는 것을 말한다. 분한처분에는 일반직 공무원의 신분상실, 변동 등을 초래하는 면직, 강임, 강급, 휴직 등이 있다. 복무규율 위반에 대한 징계처분과 달리 분한처분은 징벌적 처분의 성격을 가지지 않으며, 면직이 되더라도 퇴직금이 전액 지급된다.

⑥ 노동기준감독관 분한심의회회의 위원은 비상근으로 한다.

제3조(노동기준감독관분한심의회 회장) ① 노동기준감독관 분한심의회에 회장을 둔다. 회장은 노동정책심의회 공익을 대표하는 위원 중에서 임명된 위원으로 한다.

② 회장은 회의를 총괄한다.

③ 회장에게 사고가 있는 경우에는 후생노동대신이 지정하는 위원이 회장의 직무를 대리한다.

제4조(노동기준감독관 분한심의회회의 회의) ① 노동기준감독관 분한심의회는 회장이 위원에게 적당한 방법으로 통지를 하고 소집하며 그 의결은 출석위원의 과반수로 결정한다. 가부동수인 경우에는 회장이 결정한다.

② 노동기준감독관 분한심의회는 위원의 3분의 2이상 출석하거나 노동정책심의회 위원 중에서 임명된 위원 1명 이상 및 학식경험자 중에서 임명된 위원 2인 이상이 출석하지 않으면 회의를 열고 의결을 할 수 없다.

③ 노동기준감독관 분한심의회회의 회장은 후생노동대신의 요구가 있는 경우에는 5일 이내에 노동기준감독관 분한심의회회를 소집하여야 한다.

제5조(의견의 진술) 관계 행정기관의 직원은 노동기준감독관 분한심의회회의 회장의 허가를 받아 회의에 참석하여 의견을 말할 수 있다.

제6조(노동기준감독관 분한심의회회의 사무) 노동기준감독관 분한심의회회의 사무는 후생노동성 노동기준국 총무과에서 처리한다.

제7조(잡칙) 이 정령에 정하는 것 외에 노동기준감독관 분한심의회회의 운영에 관하여 필요한 사항은 회장이 노동기준감독관 분한심의회에 자문하여 정한다.

다. 노동국 및 노동기준감독기관 설치

(1) 후생노동성설치법(구 노동성설치법)에서 노동기준감독관을 배치하여 소관 감독업무를 수행할 노동기준감독서 설치에 관한 근거 규정을 두고, 그 시행은 후생

노동성령으로 정하고 있다.

후생노동성설치법(1999. 7. 16)

제21조(도도부현 노동국) 도도부현 노동국은 후생노동성 소관사무 중 제4조 제1항 제41호부터 제47호까지, 제50호, 제53호부터 제73호까지, 제99호, 제104호 및 제109호에 규정된 사무를 담당한다.

② 도도부현 노동국의 명칭, 소재지 및 관할은 정령으로 정한다.

③ 도도부현 노동국의 내부조직은 후생노동성령으로 정한다.

제22조(노동기준점사관서) 도도부현 노동국의 소관사무의 일부를 분담시키기 위하여 필요한 장소에 노동기준감독서를 둔다.

② 근로기준감독서의 명칭, 위치, 관할구역, 소관사무 및 내부조직은 후생노동성령으로 정한다.

(2) 노동국 노동기준국의 사무에 관한 규정이다(시행규칙 제761조).

1. 근로계약, 임금지급, 최저임금, 근로시간, 휴식, 재해보상 그 밖의 근로조건에 관한 사항(고용환경·균등부 및 고용환경·균등실 소관사무 제외)
2. 아동 사용 금지
3. 산업안전(광산안전은 제외한다)에 관한 사항
4. 산업보건사항(근로자의 진폐증관리분류 결정에 관한 사항을 포함하며, 광산에서 통기 및 재해 시 구호에 관한 사항은 제외한다)
5. 노동기준감독관이 사법경찰관으로 수행하는 직무에 관한 사항
6. 정부가 관장하는 근로자 재해보상보험사업에 관한 사항
7. 근로자의 보호 및 복지에 관한 사항
8. 가사노동자의 복지증진에 관한 사항
9. 사회보험노무사에 관한 사항
10. 월간 노동통계 조사에 관한 사항
11. 기능실습법이 정하는 근로기준감독관의 권한행사에 관한 사항

(3) 노동기준감독서는 후생노동성의 일선기관으로 위 도도부현 노동국의 사무를 집행하기 위하여 전국에 321개의 사무소(지서 4개)를 두고 있다. 노동기준감독서

내부조직은 내부조직은 다음과 같다.

- ① 근로기준법 등 관련 법령에 관한 각종 신고를 접수하고 상담에 대응하며 감독 및 지도를 실시하는 **감독과(方面)**
- ② 기계·설비의 설치에 관한 신고를 심사하고 사업장의 안전보건 확보에 관한 기술지도를 실시하는 **안전보건과**
- ③ 업무상 재해에 대한 산재보험급여를 지급하는 **산재보상과**
- ④ 회계 등을 담당하는 **업무과**

라. 노동기준감독관 소관 법률

(1) 노동기준감독관이 그 규정을 위반하는 죄에 대해 사법경찰관의 직무를 행하는 법률은 다음과 같으며,¹³⁾ 법률에는 노동기준감독관에게 행정처분 또는 행정조사 권한도 부여하고 있다(괄호 안은 사법경찰원의 근거조항).

1. 노동기준법 (제102조)
2. 노동안전보건법 (제92조)
3. 진폐법 (제43조)
4. 가내노동법 (제31조)
5. 탄광재해에 의한 일산화탄소 중독증에 관한 특별조치법 (제14조)
6. 작업환경측정법 (제40조)
7. 최저임금법 (제33조)
8. 임금의 지급확보 등에 관한 법률 (제11조)

(2) 노동기준감독관이 노동행정에서 관장하는 법률이다.

1. 노동자재해보상보험법
2. 노동금고법
3. 중소기업퇴직금공제법 ,
4. 노동재해방지단체법
5. 사회보험노무사법
6. 노동보험 보험료 징수 등에 관한 법률

¹³⁾ 2019년도의 검찰송치 건수는 821건, 그 중 기소된 것은 333건이다.

7. 실업보험법 및 노동자재해보상보험법의 일부를 개정하는 법률 및 노동보험 보험료의 징수 등에 관한 법률의 시행에 따른 관계 법률의 정비 등에 관한 법률
8. 근로자재산형성촉진법
9. 노동시간 등의 설정 개선에 관한 특별조치법
10. 석면에 의한 건강피해 구제에 관한 법률
11. 과로사 등 방지대책추진법
12. 전문적 지식 등을 가진 기간제고용노동자 등에 관한 특별조치법

(3) 노동기준감독관이 노동행정에서 해석과 적용하여야할 법령

1. 과로사 및 과로자살과 관련한 정신건강
2. 노동시장 및 고용환경개선을 위한 고용대책법, 직업안정법, 파견법, 장애인고용촉진법, 고령자 고용안정법, 남녀고용기회균등법, 단시간·기간제법, 육아개호휴업법, 노동계약법 등

마. 정리 및 시사점

(1) 법제

- 일본은 근로감독관제도를 설립하고 운영한지 100년 이상으로 제도적으로 정비되었음
- 일본은 감독기관 설치 및 운용에 대하여 필요에 따라 법령으로 정하고 있으나, 분산되어 복잡함
- 사법경찰권 행사는 개별 법률에서 부여함
- 근로감독관 임명과 지위 보장에 관하여는 정령에서 정하고 있음

(2) 감독행정

- 감독행정 및 노동행정에서 근로감독관이 살펴볼 법률 증가로 보수교육의 필요성 증가
- 노동기준감독관의 권한이 분산 규정되어 혼란이 있음
- 도도부현 노동국 권한 집중으로 인한 행정의 비효율성 증가

노동기준감독관 행동규범

(기본적 사명)

1. 우리 노동기준감독기관은 노동조건의 최저기준을 정하는 노동기준법 및 노동안전위생법 등의 노동기준관계법령(이하 법령)에 근거하여, 일하는 사람의 노동조건 확보·개선을 도모함으로써 사회·경제를 발전시켜 국민 여러분에게 공헌하는 것을 목표로 합니다.

(법령의 알기 쉬운 설명)

2. 노동기준감독관(이하 감독관)은 사업주나 일하는 사람에게 법령의 취지나 내용을 충분히 이해할 수 있도록 가능한 한 알기 쉬게 설명하도록 노력합니다.

(사업주에 의한 자주적 개선의 촉진)

3. 감독관은 법령 위반이 있는 경우 위반의 내용과 시정의 필요성을 정중하게 설명함으로써 사업주에 의한 자주적인 개선을 촉구합니다. 또한 법령 위반의 시정에 대처하는 사업주의 희망에 따라 상세한 정보제공과 구체적인 대처방법에 대하여 어드바이스 등의 지원에 노력합니다.

(공평·공정하고 일의적 대응)

4. 감독관은 사업주나 일하는 사람의 사정을 정확하게 파악하는 한편, 이를 정확하게 고려하면서 법령에 근거하여 직무를 공평·공정하게 일의적으로 수행합니다.

(중소기업 등의 사정을 배려한 대응)

5. 감독관은 중소기업 등 사업주에 대해서는 그 법령에 관한 지식이나 노무관리 체제 상황을 충분히 파악하고 이해하면서, 상세한 상담·지원을 통한 법령의 취지·내용의 이해 촉진 등에 노력합니다. 또 중소기업 등에서 법령 위반이 있는 경우 그 노동시간의 동향, 노동력의 확보상황, 거래실태 그밖에 사정을 고려하여 사업주에 의한 자주적 개선을 촉진합니다.

2. 대만의 경우¹⁴⁾

가. 노동관계법 개요 및 관련 현황

대만은 과거 우리나라와 마찬가지로 일본의 식민지 지배를 받았고 일본의 법체계가 계수된 바 있다. 이후 국민당 정부가 대만에 들어온 후 독자적인 법체계를 구축하여 지금까지 내려오고 있는바 우리나라와 가까운 위치에 있고 또한 일본의 영향을 많이 받았다는 공통점, 독재와 민주화라는 공통점, 자유민주 진영의 보루라는 공통점, 자유시장경제체제라는 공통점 등 우리나라와 여러 측면에서 공통점이 있는바¹⁵⁾ 대만의 근로감독에 관한 규범적 현황에 흥미가 가지 않을 수 없다.

대만에서 개별적 근로관계법의 핵심 법률은 노동기준법(勞動基準法)이고 집단적 노사관계법의 핵심적인 법률은 노동조합법(工會法), 단체협약법(團體協約法), 노자쟁의처리법(勞資爭議處理法) 등이다. 그밖에 노동시장과 관련하여서는 취업복무법(就業服務法)이 중요한 역할을 하고 있다. 대만은 국공내전에서 패배한 국민당이 대만으로 피난온 후 수십년 간의 소위 비상법제시기를 거치면서 대단히 억압적인 노사관계를 유지해왔다. 그런 이유로 집단적 노사관계에서 특히 중요한 단결권의 촉진, 성실교섭의무, 부당노동행위, 정당한 쟁의행위의 민형사 면책 등이 법개정으로 인정된 것이 불과 2011년부터이다.¹⁶⁾ 그에 비해 개별적 노동관계에서는 핵심적인 법률인 노동기준법이 개별 근로자의 인권 신장을 위해 1980년대 제정 이후 꾸준히 개정되어 왔다.¹⁷⁾

2021년(민국 110년) 12월 말 기준으로, 대만에서 근로자를 고용하고 있는 사업장의 총계는 1,007,991개이고, 이중 제조업 사업장은 152,585개, 건축업(營建工程業) 사업장은 99,536개, 도소매업(批發及零售業) 사업장은 325,163개, 숙박 및 외식업(住宿及餐飲業)이 126,079개로 집계되고 있다.¹⁸⁾

14) 이하의 내용은 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3, 152~167면에서 재인용.

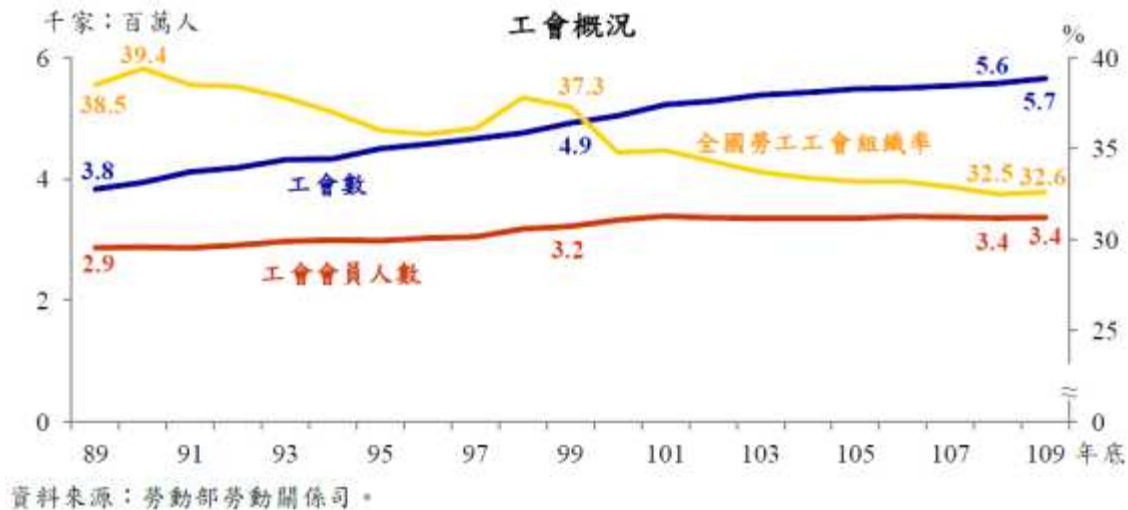
15) 이와 관련하여 상세한 내용은 노호창, “대만의 형사법 체계의 입법적 개관 및 주요 특징”, 「법학논총」 제41권 제4호, 전남대 법학연구소, 2021, 97~101면 참조.

16) 실제로 대만의 노동조합법(工會法)은 1929년에 제정되어 시행되었으나 노동조합의 설립상 발기인 요건을 충족하고(1929년 노동조합법 제1조) 주무관청의 심사와 승인을 받아야 하는 것이었고(1929년 노동조합법 제5조) 단체협약의 체결·수정·폐지는 주무관청의 승인(認可)이 없으면 효력이 발생하지 않는(1929년 노동조합법 제15조) 등 상당히 억압적인 모습이었다. 公會法 民國 18年9月28日 非現行條文 참조.

17) 賴怡欣·노호창, “대만 노동기준법과 기업인수·합병법상의 고용승계결정권에 대한 소고”, 「노동법연구」 제52호, 서울대노동법연구회, 2022 상반기, 43면.

대만의 노조 현황의 전체적인 변화 모습은 다음과 같다.¹⁹⁾

109年底工會 5,655 家(含工會聯合組織 272 家),較 108 年底多 79 家,會員人數 336.4 萬人,則年增 1 萬人,工會類型以職業工會最多(工會數及會員人數占比各為 74.9%及 79.9%),企業工會次之(占 16.2%及 17.5%);另 109 年底全國勞工工會組織率為 32.6%。



2020년(민국 109년) 기준 노조의 총계는 연합단체 272개 포함하여 5,655개로서 꾸준히 증가하고 있고 노조 가입인원도 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 그러나 오히려 노조 가입률(조직률)은 꾸준히 감소하고 있는 것을 볼 수 있다.

2011년 이후의 노조 현황은 다음과 같다.²⁰⁾ 대만의 노조 유형별 모습을 볼 수 있는데, 기업노조가 1,000개 미만이라는 점은 이채롭고 직업노조의 수와 인원수가 비율적으로는 높다는 것이 특징적이다. 노조의 조직률 자체가 30%가 넘는다는 점에서 조직률 자체는 낮지 않으나 노동3권의 촉진 이후에도 오히려 조직률이 꾸준히 감소하고 있다는 점은 무척 흥미롭다.

18) 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7, 2면.

19) 대만 노동부 통계자료(<https://www.mol.gov.tw/media/dcco1uhq/3-%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%97%9C%E4%BF%82.pdf>, 최종방문 2023. 2. 28.)

20) 劉志鵬, 勞動三法實施十周年之回顧與展望(노동3법 실시 10주년의 회고와 전망), 樂說頭條, 台灣勞工季刊 NO. 68, 勞動部, 2021. 12, 8면에서 재인용.

表 2 各級工會數及會員數							
單位：家、人							
	企業工會 工會數	產業工會 工會數	職業工會 工會數	總計會員 人數	企業工會 會員人數	產業工會 會員人數	職業工會 會員人數
100 年底	889	37	3,891	3,321,969	529,685	34,785	2,757,499
101 年底	892	84	4,016	3,387,524	537,419	51,603	2,798,502
102 年底	884	101	4,064	3,362,024	551,267	67,807	2,742,950
103 年底	905	142	4,088	3,349,521	551,367	72,781	2,725,373
104 年底	909	158	4,105	3,350,520	547,283	79,217	2,724,020
105 年底	924	179	4,127	3,348,702	553,815	79,687	2,715,200
106 年底	895	194	4,150	3,380,879	581,531	85,950	2,713,398
107 年底	900	210	4,161	3,369,165	585,153	87,271	2,696,741
108 年底	909	214	4,184	3,353,660	588,121	84,442	2,681,097
109 年底	916	231	4,236	3,363,998	590,089	86,424	2,687,485

資料來源：勞動部網頁，最後瀏覽日 110/10/08

대만의 단체협약 체결 현황의 변화는 다음과 같다.²¹⁾

109 年底團體協約有效份數計 826 份，其中企業工會 239 份，產業工會 379 份，職業工會 208 份；與 108 年底比較，增加 54 份。



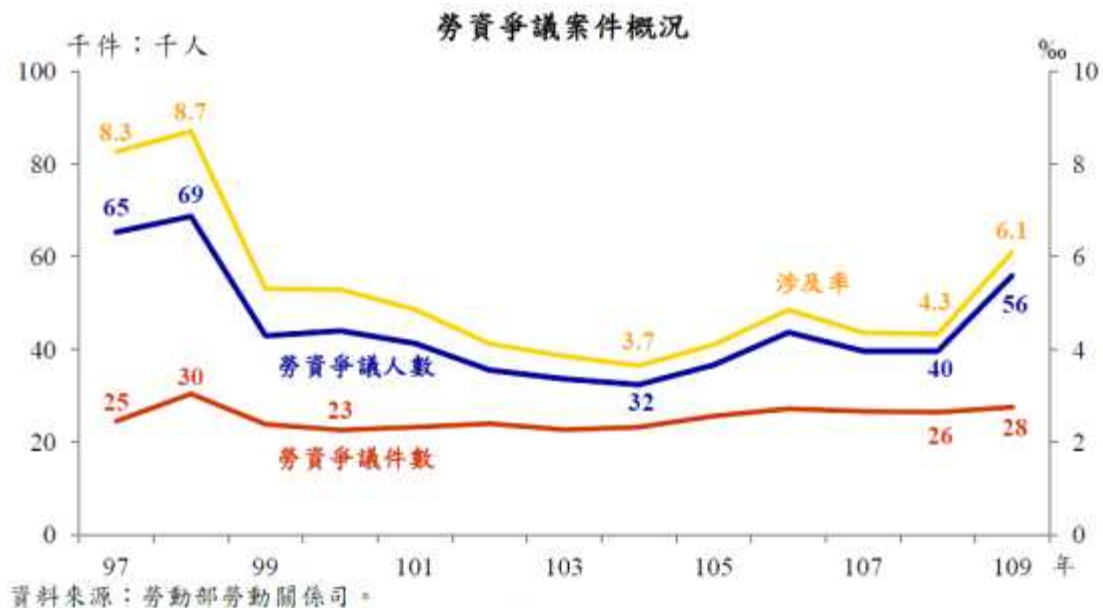
2011년 이전에는 단체협약의 체결 자체가 100건이 되지 않았음을 고려하면 2011년 이후 비약적으로 증가하였다고 볼 수 있다. 그러나 2020년(민국 109년) 말 기준으로 기업노조의 협약 체결 239건, 산업노조의 협약 체결 379건, 직업노조의

²¹⁾ 대만 노동부 통계자료(<https://www.mol.gov.tw/media/dcco1uhq/3-%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%97%9C%E4%BF%82.pdf>, 최종방문 2023. 2. 28.)

협약 체결 208건으로 도합 826건에 그치고 있다. 2020년 기준 전체 노조의 수가 5,383개(연합단체 272개 제외)라는 점을 생각하면 협약 체결된 노조가 15% 정도에 불과한 실정임을 알 수 있다.

대만의 노동쟁의(勞資爭議) 현황의 변화는 다음과 같다.²²⁾

109 年勞資爭議案件計 2.8 萬件，勞資爭議人數 5.6 萬人，各較 108 年增加 4.1%及 41.2%；爭議類別以「工資爭議」居首（109 年件數占比 41.4%），「給付資遣費爭議」居次（占 27.8%），二者合占近 7 成。終結案件 2.8 萬件，處理方式以調解占 99.1%最多。



2020년(민국 109년) 말 기준으로 노동쟁의 건수는 2만8천건, 노동쟁의 참여인수는 5만6천 명, 참여율(涉及率)은 6.1%이다. 노동쟁의는 노동3권이 촉진되기 시작한 때인 2011년 이후에 오히려 감소하였다는 점이 특징적이다. 쟁의유형은 임금(工資) 쟁의가 41.4%, 퇴직금지급(給付資遣費)쟁의가 27.8%를 차지하여 이 두 가지를 합치면 70%에 달한다. 쟁의가 종결된 건수는 2만8천건이고 99.1%가 조정(調解)으로 종결되었다.

대만의 노동관계를 보면, 노동3권이 억압되던 시기보다 오히려 촉진되기 시작한 이후의 시기에 노조 조직률이 감소하고 단체협약의 체결도 노조의 비율에 비해서

²²⁾ 대만 노동부 통계자료(<https://www.mol.gov.tw/media/dcc01uhq/3-%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%97%9C%E4%BF%82.pdf>, 최종방문 2023. 2. 28.)

는 상당히 적은 편이고 노동쟁의가 감소한 것도 매우 이채롭다.

이러한 현상과 관련하여서는 하나의 사업장에서 대부분 노자회의(勞資會議, 한국의 노사협의회에 해당)가 있는바, 아직도 13만개 정도의 사업장은 노자회의는 있는데 기업 노조가 없고, 노자회의의 기능과 기업 노조의 기능이 부분적으로는 중첩되기 때문에 노자회의와 기업 노조 간에 경쟁과 협력관계가 존재하며 대만 근로자들 스스로도 기업 노조를 조직할 의식이 결여되어 있고 사용자가 노자회의를 여는 동안에는 파업에 대한 걱정이 없으며 노자회의가 먼저 존재하면 기업 노조가 설립될 가능성이 저해되고 노동3법 시행 이후 기업노조의 조직이 좋지 않은 것은 노자회의가 노조를 대체한 측면이 있을 것이라고 설명하는 견해가 있다.²³⁾

그런 한편, 2021년 말 기준으로 대만의 근로감독의 현황을 간략히 보면, 근로조건과 관련된 감독건수 34,431건, 위반건수 5,939건으로 집계되었다.²⁴⁾ 그리고 34,431건의 감독건 중 해당 사업장에 처음으로 감독(初査)하는 건수는 32,649건으로 94.82%에 달하였다.²⁵⁾

2021년 말 기준으로 산업안전(安全衛生)과 관련된 감독건수는 164,585건으로 집계되었고 이중 위반 건수는 10,104건으로 집계된 바 있다.²⁶⁾ 그리고 산업안전 관련 감독건수 164,585건 중 해당 사업장에 처음으로 감독하는 건수는 135,152건으로 82.12%에 달하였다.²⁷⁾ 대만의 영토 크기가 경상남북도보다 약간 큰 정도로 작다는 점, 한국과 인구대비 및 노동자수 대비, 한국과의 사업장 개수 비교 등을 고려해보면, 대만에서는 근로감독이 한국보다 더욱 밀도있게 진행되는 것으로 보인다. 사건으로는 근로감독의 밀도와 효율성도 근로자들의 노조에 대한 필요성 인식에 영향을 줄 수 있지 않을까 생각된다.

23) 劉志鵬, 勞動三法實施十周年之回顧與展望(노동3법 실시 10주년의 회고와 전망), 樂說頭條, 台灣勞工季刊 NO. 68, 勞動部, 2021. 12, 9면.

24) 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7, 12면.

25) 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7, 40면.

26) 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7, 96면.

27) 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7, 97면.

나. 근로감독에 관한 규범적 근거

대만의 노동기준법(勞動基準法)²⁸⁾ 근로감독에 관한 근거 규정을 두고 있다.

노동기준법, 제정 中華民國七十三年(1984년)七月三十日, 최종 개정 民國109年(2020년) 06月 10日

제10장 감독과 조사[監督與檢查]

제72조.

제1항. 중앙주관기관은 본법 및 기타 노동법령(勞工法令)의 집행을 관철하기 위하여 근로감독(勞工檢查機構)을 설치하거나 직할시주관기관에 권한을 부여하여 감독기구를 설치하여 이를 처리하도록 하게 한다; 직할시, 현(시) 주관기관은 필요한 경우 사람을 보내어 조사를 실시할 수도 있다.

제2항. 전항에서 근로감독기구의 조직은 중앙주관기관에서 이를 정한다.

제73조.

제1항. 조사관은 직무 집행시 조사증을 제시하여야 하고 각 사업단위[사업장의 의미]는 거절하여서는 아니 된다. 사업단위가 조사를 거절하는 경우 조사관은 해당 지역 주관기관 또는 경찰기관과 합동하여 강제조사를 할 수 있다.

제2항. 조사관이 직무집행을 할 때 본법 규정사항에 관하여 사업단위에, 필요시, 보고, 기록, 장부 및 관련문건 기타 서면설명을 요구할 수 있다. 자료, 견본 또는 정보를 취득하는 경우 사용자(雇主) 또는 그 대리인에게 사전에 통지하고 영수증을 주어야 한다.

제74조.

제1항. 근로자(勞工)는 사업단위가 본법 및 기타 노동법령 규정을 위반하는 것을 발견한 경우, 사용자에게 대하여 주관기관 또는 감독기구에 진정(申訴)을 할 수 있다.

²⁸⁾ 대만 노동기준법(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=N0030001>, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

제2항. 사용자는 근로자에게 전항의 진정을 이유로 해고, 강등, 감봉, 법령·계약 또는 관습에 따라 마땅히 누려야 하는 권익을 침해하거나 또는 기타 불리한 처분을 주어서는 아니된다.

제3항. 사용자가 전항의 행위 중 하나를 하는 경우 무효로 한다.

제4항. 주관기관 또는 감독기구는 제1항 진정에 대해 접수한 후에는 필요한 조사를 하고 60일 내에 처리상황을 서면으로 근로자에게 통지하여야 한다.

제5항. 주관기관 또는 감독기구 진정인의 신분자료에 대해 비밀을 엄수해야 하고 그 신분을 식별하기에 충분한 자료를 누설하여서는 아니 된다.

제6항. 전항의 규정을 위반한 자는, 공무원이 법에 따라 형사 및 행정책임을 지는 경우를 제외하고는, 이로 인해 손해를 받는 근로자에 대하여 그 손해배상 책임을 져야 한다.

제7항. 주관기관이 수리하는 신고사건의 비밀 기타 준수해야 하는 사항은 중앙주관기관에서 이를 정한다.

그러나 일찍부터 별도의 독자적인 근로감독법(勞動檢查法)이²⁹⁾ 제정되어 시행되고 있었고 근로감독법에는 근로감독에 관한 상세한 내용이 규정되어 있다(번역 및 밑줄은 필자).

근로감독법(勞動檢查法) - 총 40개 조문, 제정 中華民國二十年(1931년)二月十日, 최종 개정 民國 109年(2020년) 06月 10日

제1장 총칙 - 4개 조문

제1조: 근로감독을 실시하고 노동법령의 집행을 관철하며 노사(勞雇) 쌍방의 권익을 유지·보호하고 사회를 안정시키며 경제를 발전시키기 위하여 특별히 본 법을 제정한다.

제2조: 본 법에서 지칭하는 주관기관: 중앙에는 노동부가 있고, 직할시에는 직할시정부가 있고, 현[縣](or 시)에는 현(or 시)정부[縣(市)政府]가 있다.

²⁹⁾ 대만 근로감독법(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070001&kw=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e6%b3%95>, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

제3조: 본 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다:

1. 근로감독기구: 중앙 혹은 직할시주관기관 혹은 유관기관이 근로감독업무를 처리하기 위해 설치하는 전문감독기구를 지칭한다.
2. 감독대행기구: 중앙주관기관으로부터, 위험한 기계 또는 설비의 를 처리하기 위하여 지정하는 행정기관, 학술기구 또는 비영리법인을 지칭한다.
3. 근로감독관: 근로감독증을 소지하고 근로감독직무를 집행하는 사람을 지칭한다.
4. 감독대행관: 감독대행증을 소지하고 감독대행직무를 집행하는 사람을 지칭한다.

제4조: 근로감독사항의 범위는 다음과 같다:

1. 본법의 규정에 의하여 감독의 집행이 되어야 하는 사항.
2. 근로기준법령이 규정하는 사항.
3. 직업안전위생법령이 규정하는 사항.
4. 기타 노동법령에 의하여 처리되어야 하는 사항.

제2장 근로감독기구 - 3개 조문

제5조.

제1항. 근로감독은 중앙주관기관에 의해 설립된 근로감독기구 또는 직할시주관기관 혹은 유관기관이 권한을 부여하여 설립한 근로감독기구에 의해 처리되어야 한다. 근로감독기구는 필요하다고 인정할 경우, 현(시) 주관기관과 함께 감독할 수 있다.

제2항. 전항에서 권한을 부여하는 근로감독은 본법의 관련 규정에 의하여 처리되어야 하며 중앙주관기관의 지휘감독을 받아야 한다.

제3항. 근로감독기구의 조직, 인원기준은 감독사업단위의 수와 지역적 특성에 따라 중앙주관기관에 의해 정해지고 행정원에 보고하여 승인을 요청한다.

제6조.

제1항. 중앙주관기관은 우리나라[我國, 대만]의 근로조건현황, 안전위생조건, 산업재해의 심각을 및 부상빈도 현황을 고려하여 해당 연도 개시 6개월 전 근로감독방침을 발표하고 홍보해야 한다. 그 내용은 다음과 같다:

1. 우선적으로 감독을 받는 사업단위의 선택 원칙
2. 감독의 중점 사항
3. 감독 및 처리 원칙
4. 기타 필요한 사항

제2항. 근로감독기구는 전항의 감독방침이 발표된 후 3개월 이내에 근로감독 계획을 정하여 중앙주관기관에 보고하고 확인 후 시행하도록 요청하여야 한다.

제7조.

제1항. 근로감독기구는 사업단위와 관련하여 근로감독에 관한 정보를 구축하여야 하고 필요한 경우 유관기관 혹은 단체에 제공을 요청할 수 있다.

제2항. 전항의 청구에 대하여 다른 법률이 특별히 규정한 경우를 제외하고는 유관기관 또는 단체는 거절할 수 없다.

제3항. 중앙주관기관은 근로감독연보를 매년 정기적으로 발표하여야 한다.

제3장 근로감독관 - 9개 조문

제8조. 근로감독관의 임용에 있어서는, 공무원에 적용하는 관계법령의 규정을 제외하고는, 그 선발(濫用)의 기준은 중앙주관기관에서 정한다.

제9조.

제1항. 근로감독관은 전문업무 훈련을 받아야 한다.

제2항. 전항의 훈련 방법은 중앙주관기관에서 정한다.

제10조. 근로감독관은 근로감독기구에서 전문성과 업무 특성에 따라 보내져서 제4조에 규정된 직무를 집행한다.

제11조.

제1항. 근로감독관은 다음의 행위를 하여서는 아니된다:

1. 변경, 은닉 또는 날조하여 사실을 보고하는 것.
2. 감독을 받는 사업단위의 관련 생산기술, 설비 및 경영재무 등 비밀을 누설하는 것; 퇴직 후에도 같다.

3. 비밀진정(秘密申訴) 사건을 처리하면서 그 신고 경위를 누설하는 것.

4. 감독을 받는 사업단위와 발생한 부당한 재무관계.

제2항. 근로감독관이 위법 혹은 직무유기[失職情事]가 있는 경우 누구라도 사실에 근거하여 고발할 수 있다.

제12조. 근로감독관이 감독을 받는 사업단위와 이해관계가 있는 경우, 스스로 회피해야 하고 직무를 집행해서는 아니 된다; 그 하위규정[辦法]은 중앙주관기관에서 정한다.

제13조. 근로감독관은 직무를 집행할 때, 다음의 사항을 제외하고는, 사전에 해당 사업단위에 통지해서는 아니된다.

1. 제26조 규정에 따른 감독 또는 조사
2. 위험성이 있는 기계 혹은 설비의 검사
3. 산업재해감독
4. 기타 노동감독기구 또는 주관기관의 승인을 받은 것

제14조.

제1항. 근로감독관은 감독직무 집행을 위하여 수시로 사업단위에 출입할 수 있으며 사용자(雇主), 사용자대리인, 근로자 및 기타 관계인은 모두 이유 없이 거절하거나 회피하거나 방해해서는 아니 된다.

제2항. 전항의 사업단위의 관계인이 거절하거나 회피하거나 방해하는 경우, 경찰의 조력이 아니고서는 그 배제를 하기에 불충분한 경우, 근로감독관은 경찰관의 조력을 요구할 수 있다.

제15조.

제1항. 근로감독관은 직무집행시 근로감독의 범위 내에서 사업단위의 사용자, 관련 부분 주관인, 노조대표 및 기타 관계인에게 다음의 행위를 할 수 있다:

1. 관계인에게 신문하고 필요시 녹취 또는 녹음을 하는 것.
2. 관계인에게 필요한 보고, 기록, 급여명세 및 관계문서의 제출을 하게 하거나 필요한 설명을 하게 하는 것.
3. 근로감독 사업단위가 법에 의거하여 비치하여야 하는 문건자료, 물품 등을

필요한 경우 자료영인, 사진촬영, 녹화 또는 측량 등을 하는 것.

4. 조사에 필요한 물품, 재료, 상품, 기재, 공구 등을 봉인하거나 반출하는 것.

제2항. 근로감독관의 전항의 행위들은 사업단위 혹은 관계인에 의해 거절되거나 회피되거나 방해되어서는 아니된다.

제3항. 근로감독관은 제1항의 제3호에 의하여 녹화, 촬영 등을 사업단위에서 필요성이 인정될 때, 근로감독기구에 신청하여 검사 또는 복제할 수 있다.

제4항. 전항의 사업단위에 대한 청구에 대하여 근로감독기구는 거절하여서는 아니 된다.

제16조. 근로감독관은 노동법률규정을 위반한 범죄혐의자에 대하여 필요한 경우 검찰관에게 압수수색영장(搜索票) 발급을 요청할 수 있고 관련있는 물건, 장소에 압수수색을 할 수 있다.

제4장 감독대행기구 및 감독대행관 - 5개 조문

제5장 감독절차 - 12개 조문

제28조.

제1항. 근로감독기관이 근로감독관을 각 사업단위의 작업장에 배치하여 안전보건점검을 실시한 결과 근로자에게 즉각적인 위험이 발생할 우려가 있다고 판단되는 경우 해당 작업단위에 서면으로 해당 작업장의 작업을 중지할 것을 통지할 수 있다.

제2항. 전항의 즉각적인 위험이 발생할 우려가 있는 사정은, 중앙주관기관이 결정한다.

제6장 벌칙 - 4개 조문

제7장 부칙 - 3개 조문

근로감독법에 근거하여 근로감독법의 집행을 위해 근로감독기구, 근로감독관(勞動檢查員), 감독대행기구, 감독대행관, 감독절차(檢查程序) 등에 관하여 노동부에 의해 보다 상세하게 마련된 근로감독법시행세칙(勞動檢查法施行細則)³⁰⁾ 및 ‘근로감독

³⁰⁾ 다만 근로감독법시행세칙(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070004>, 다만

법 제28조에 따른 노동자에 대한 즉각적인 위험발생 우려의 인정기준’(勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準)³¹⁾ 마련되어 있다.

다. 지방자치단체의 근로감독

우리나라와 달리 대만의 경우 지방자치단체의 근로감독권을 별도로 인정하고 있는 점이 매우 특징적이다.

우리나라의 경우 지방자치법에서 근로기준에 대해서는 국가사무로 규정하고 있고 지방자치단체가 처리할 수 없도록 명시하고 있다.

지방자치법 제15조(국가사무의 처리 제한) 지방자치단체는 다음 각 호의 국가사무를 처리할 수 없다. 다만, 법률에 이와 다른 규정이 있는 경우에는 국가사무를 처리할 수 있다.

5. 근로기준, 측량단위 등 전국적으로 기준을 통일하고 조정하여야 할 필요가 있는 사무

우리나라 지방자치법에서 근로 혹은 노동과 관련된 조항은 지방자치법 제15조가 유일하며 이 조항을 근거로 보면, 지방자치단체가 근로감독 사무를 수행할 수 있는 권한은 없는 것이 원칙이고, 예외적으로 법률에 의해 지방자치단체가 근로감독 권한을 부여받거나 지방자치단체에 대한 근로감독 권한 위임 근거가 있어야 가능하다는 의미가 된다.

반면, 대만의 경우 대만의 지방자치법에 해당하는 ‘지방제도법’(地方制度法)³²⁾ 제18조, 제19조에서, 직할시정부(直轄市政府), 현·시 정부(縣、市政府)의 자치사항(自治事項)에 ‘노자관계’ & ‘근로자 안정과 위생’이 포함되는 것으로 규정하고 있다. 지방제도법 제18조에서는 직할시정부의 자치사항으로 ‘근로자행정사항’(勞工行政事項)이라는 제하에 하위 내용으로 “(一)直轄市勞資關係。 (二)直轄市勞工安全衛

법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

31) 대만 ‘근로감독법 제28조에 따른 노동자에 대한 즉각적인 위험발생 우려의 인정기준’(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070016&kw=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e6%b3%95, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

32) 대만 지방제도법(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0040003&kw=%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%b3%95, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

生。” 즉 ‘직할시 노자관계’, ‘직할시 근로자안전위생’을 규정하고 있다. 그리고 지방제도법 제19조에서는 현(市)자치사항[縣(市)自治事項]으로 ‘근로자행정사항’(勞工行政事項)이라는 제하에 하위 내용으로 “(一)縣(市)勞資關係。 (二)縣(市)勞工安全衛生。” 즉 ‘현(市) 노자관계’, ‘현(市) 근로자안전위생’을 규정하고 있다.

그리고 이에 더하여 대만의 근로감독법(勞動檢查法)에서는 근로감독의 주관기관으로 중앙부처의 경우 노동부를, 지방자치단체의 경우 직할시정부·현(市)정부를 인정하는 바탕에서(동법 제2조) 지방자치단체 스스로 근로감독을 할 수 있는 권한 근거를 규정하고 있다(동법 제5조).

대만이 지방자치단체에 근로감독권한을 인정하고 있는 것은 ILO 국제기준에 비추어보면 적절치 않다. ILO는 일찍이 제81호 협약 및 제20호 권고를 채택하여 근로감독제도를 국가가 수행해야 하는 보편적 기능임을 천명한 바 있기 때문이다.³³⁾ 지방자치단체가 근로감독권한을 행사하는 것에 대해서는 ILO 제81호 협약 제4조에서 명시하고 있는 중앙기관통제원칙에 저촉될 위험이 있고 우크라이나를 비롯하여 몇몇 국가가 ILO로부터 그런 문제점을 지적받은 바 있다.³⁴⁾ 다만 대만은 정치적 이유로 아직 UN에 가입된 국가가 아니어서 ILO의 감시 대상이 아니다.

그밖에 대만에서는 ‘근로감독관 선발 및 전문직무훈련에 관한 시행령’[勞動檢查員遴用及專業訓練辦法]³⁵⁾ 별도로 존재하여 근로감독관 양성 및 역량 강화의 근거로 기능하고 있다.

33) ILO 제81호 협약 등에서 규정한 근로감독의 기본원칙은 다음과 같다. 첫째, 근로감독은 정부 책임 하에 정비되고 조직된 공적 기능으로 확립되어야 한다. 둘째, 근로감독 기관과 사용자·근로자 간의 긴밀한 협력은 필수적이다. 셋째, 근로감독은 연구기관, 대학, 사회보장 기관과 같은 관련 기관 및 전문가와의 효율적인 협업이 필요하다. 넷째, 근로감독은 예방적 기능을 유지하여야 한다. 다섯째, 근로감독의 보호·예방 조치는 모든 근로자에게 확장되어야 하고, 보편적으로 적용되어야 한다.

34) 관련 연구로 김린, “근로감독기능의 지방자치단체 배분의 법적 한계 - 우크라이나 사례의 시사”, 「강원법학」 제69권, 강원대법학연구소, 2022. 11, 372~380면 참조.

35) 대만 ‘근로감독관 선발 및 전문직무훈련에 관한 시행령’(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070006&kw=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e5%93%a1%e9%81%b4%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%b0%88%e6%a5%ad%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%be%a6%e6%b3%95>, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

3. 스페인의 경우

가. 개요

스페인은 2007년 자영노동법(Estatuto del Trabajo Autónomo)을 제정 및 시행하고 있고,³⁶⁾ 근로자헌장법(Ley del Estatuto de los Trabajadores) 및 사회보장일반법(Ley General de la Seguridad Social)에서 젠더폭력 피해자(violencia de género)에 대한 보호를 직접적으로 규정하고 있으며³⁷⁾ 유기고용에 있어서 여성을 채용하거나 무기직 전환에 있어서 여성의 무기직 전환의 경우 사용자의 사회보험료 할인을 남성근로자에 대한 것보다 더 많이 해주는³⁸⁾ 등 여성에 대한 고려를 특히 많이 해주는 모습을 보이고 있고, 최근에는 플랫폼 배달(reparto) 종사자에 대해 고용관계 추정(presunción de laboralidad) 규정을 근로자헌장법에 도입하는 등,³⁹⁾ 최소한 노동입법적 측면에서만 보면, 여러 국가들 중에서도 상당히 앞서나가는 면모가 보이는 국가이다. 이런 면모들로 인해 근로감독에 있어서는 어떤 규범적 상황일지 궁금하지 않을 수 없다.⁴⁰⁾

스페인은 근로감독에 관해서도 독자적인 법률로 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (노동 및 사회보장 감독 시스템에 대해 규율하는 2015년 7월 21자 법률 23/2015호, 이하 ‘근로감독법’)이 제정되어 시행 중이다.⁴¹⁾

스페인의 경우 노동감독과 사회보장감독을 모두 단행 법률로 규율하고 있는 점이 특징이고 상당한 분량의 서문을 두고 있는데 서문에서는 근로감독 및 사회보장

36) 스페인 자영노동헌장법(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409>, 최신 개정 2022. 9. 7, 최종방문 2023. 2. 28.)

37) 에컨대, 근로자헌장법 제49조에서 근로자 측에 의한 근로계약 해지 요청이 정당한 사유로 규정되어 있으며, 사회보장일반법(Ley General de la Seguridad Social)상 실업급여가 인정되는 정당한 사유에 해당한다. 노호창, “실업으로부터 노동자 보호에 관한 스페인의 법제도적 대응에 관한 연구”, 『노동법학』 제85호, 한국노동법학회, 2023. 3, 287~288면.

38) 2012년 ‘노동시장개혁을 위한 긴급조치에 관한 왕실 명령법’에 의한 개정 근로자헌장법 내용(<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-2076>, 최종방문 2023. 2. 28.)

39) 디지털플랫폼 영역에서 배달에 종사하는 사람의 노동권을 보장하기 위하여 왕실입법령에 의해 승인된, 근로자헌장법 개정(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15767>, 최종방문 2023. 2. 28.)

40) 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3, 168면.

41) 스페인 근로감독법(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168>, 최종방문 2023. 2. 28.)

감독에 관한 단행 법률의 제정과정 및 취지 기타 상징성 등에 대해 서술하고 있다.

특히, 스페인의 근로감독법은 그 서문에서 근로감독에 대해 독자적인 중요한 의미들을 부여하고 있는 점이 매우 눈에 띈다(밑줄은 필자).

서문

“ ... 한편, 노동 및 사회보장 감독이라는 공적 서비스(servicio público)의 제공은 우리의 사회노동적 질서(ordenamiento sociolaboral)에서 발생하는 규범적 변화(cambios normativos)에 적응해야 한다. 그 안에서는 지속적인 입법적 개혁(reformas legislativas) 이후 중요한 수정이 도입되고 있으며, 이는 인적자원(recursos humanos) 관리에서 필요한 유연성과 근로자 권리들의 더 큰 보호의 결합을 추구한다. 그러한 권리들 중에 근로자의 권리가 짓밟혔다고 생각될 때, 의심할 바 없이, 모든 근로자들이 가지고 있는, 노동 및 사회보장 감독에 호소할 권리가 발견된다.⁴²⁾ ... 사회적 규범의 감시와 통제를 부여받은 공적 서비스로서의 노동 및 사회보장 감독은 노동입법이 헌정한 근로자의 권리 보전에 결정적으로 기여하고, 특히 노동계약 체계와 관련된 것으로서 시민의 높은 수요가 있는 영역에서 감시와 통제 활동을 적절히 계획해야 하는 사회적 보호 시스템(sistema de protección social)의 유지에 기여하고, 노동시장의 이원성(dualidad del mercado de trabajo)에 기여하고, 일자리(puestos de trabajo) 접근에 기여하고, 차별없는 평등한 조건에서의 근로 제공의 실현에 기여하고, 노동에서의 안전과 보건의 권리에 기여하고, 사회보장이라는 공적 체계의 보장과 존속에 기여한다. 게다가 노동 및 사회보장 감독은 노동갈등의 회피와 통합으로 이어지는 조정기능(función mediadora)을 육성해야 하고 노사에 대한 정보 및 기술적 지원 기능을 육성해야 하는데, 이는 노동관계를 조화시키는 공적 서비스로서의 형성을 강화시켜준다. ... ”

스페인 근로감독법의 전체적인 조문 체계는 다음과 같다[이하에서 ‘감독’은 inspección(검사, 수사, 점검, 조사 등 의미)의 번역임].⁴³⁾

⁴²⁾ 해당 번역의 원문은 다음과 같다.

... entre los que sin duda se encuentra el derecho que tiene todo trabajador a recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando considere que sus derechos han sido conculcados.

제1편 노동 및 사회보장 감독(inspección) 시스템(sistema)

제1장 총칙

제1조 노동 및 사회보장 감독 시스템의 정의 및 목표

제2조 노동 및 사회보장 감독 시스템의 규율 원칙

제2장 감독 시스템의 직원

제1절 감독직무를 가진 직원

제3조 구성하는 직원

제4조 법적 체계

제5조 감독직무를 가진 직원의 국가조직(Cuerpos Nacionales)에의 진입과
직위 부여

제6조 감독 직원의 통합 등록

제2절 기술직원 및 행정직원

제7조 기술직원 및 행정직원

제3장 권리와 의무

제8조 권리

제9조 의무 및 행동강령(código de conducta)

제10조 비밀의무 및 겸직금지(incompatibilidades)

제11조 훈련, 승진 및 목표참여

제2편 시스템의 기능

제1장 노동 및 사회보장 감독의 기능에 대하여

제12조 감독기능에 대하여

제13조 권한 행사를 위한 노동 및 사회보장 감독관의 능력(facultades)

제14조 하위 근로감독관(Subinspectores Laborales)의 직무

제15조 감독관 직무행사의 보장

제16조 노동 및 사회보장 감독과의 보조 및 협력

43) 이하의 내용은 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3, 170~172면에서 재인용.

제17조 노동 및 사회보장 감독의 협력

제18조 노동 및 사회보장 감독의 직원과의 협력에 대하여

제2장 노동 및 사회보장 감독의 활동에 대하여

제19조 노동 및 사회보장 감독의 활동 범위

제20조 일반규범, 노동 및 사회보장 감독 활동의 근거 및 이해관계인의 지위(condición)

제21조 감독 활동의 형식 및 문서화

제22조 감독 활동에서 파생되는 조치

제23조 감독 확인의 확실성 추정

제24조 노동 및 사회보장 감독 시스템의 정보

제3편 시스템의 조직

제1장 총칙

제25조 공행정의 공조와 참여

제26조 감독 직무 및 직위의 정의

제2장 노동 및 사회보장 감독의 국가 기관

제27조 노동 및 사회보장 감독의 국가 기관의 창설

제28조 국가 기관의 구조

제29조 통할위원회(Consejo Rector)

제30조 일반위원회

제31조 위원장

제32조 노동 및 사회보장 감독의 국가 기관의 지역적 구조

제3장 자치협력(Cooperación autonómica)

제33조 노동 및 사회보장 감독의 자치당국(Autoridad Autonómica)

제34조 노동 및 사회보장 감독에 관한 자치운영위원회
(Comisión Operativa Autonómica)

제35조 제도적 참여

스페인의 경우 근로감독에 관한 독자적인 근거법률을 제정하여 시행 중이고 권한, 조직체계, 기능 등을 상세히 규정하고 있다. 또한 분리주의에 가까울 정도로 발달된 지방자치의 전통으로 인해 지방자치단체와의 협력적 근거를 두고 있는 점이 특징이다.⁴⁴⁾

나. 주요 조문 예시

스페인의 근로감독법의 규정을 몇 가지 예로 살펴보면 다음과 같다. 스페인 법률의 일반적 특징은 조문 하나하나가 그 내용이 상세하고 분량이 많다는 점이다. 전체적인 체계와 몇 가지 조문의 예시를 통해 우리나라가 향후 근로감독에 관한 개별법률을 제정한다고 할 때 약간의 참조가 될 수 있을 것으로 본다.

제1조. 노동 및 사회보장 감독의 정의 및 목적

1. 노동 및 사회보장 감독 시스템은 이 법에 명시된 바에 따라 맡겨진 임무를 적절히 수행하는 데 기여하는, 일련의 법적 원칙, 규정, 기관, IT자원을 포함한 인적·물적 자원으로 구성된다.
2. 노동 및 사회보장 감독은 사회질서(ordem social) 규범의 준수 여부를 모니터링하고 관련 책임을 요구할 뿐만 아니라 해당 문제에 대한 조언을 제공하고 적절한 경우 알선, 조정 및 중재를 담당하는 공공 서비스로, 스페인 헌법에 명시된 사회민주적 법치국가(Estado social y democrático de Derecho) 원칙과 국제노동기구 협약 제81호(근로감독 협약) 및 제129호(농업 근로감독 협약)에 따라 실행한다.

앞의 문장에서 언급된 사회질서 규범에는 노동 문제, 산업재해 예방, 사회보장 및 사회 보호, 직업 알선, 고용, 고용·실업보호를 위한 직업훈련, 사회적 경제, 이민, 이주 및 외국인의 노동, 고용에서의 평등한 대우와 기회 및 차별 금지, 그리고 노동 및 사회보장 감독에 대한 준수 여부를 감독할 책임이 있는 기타 모든 규정이 포함된다.

⁴⁴⁾ 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3, 172면. 스페인의 분리주의적 전통 및 정치적·역사적 배경에 관해서는 노호창, “실업으로부터 노동자 보호에 관한 스페인의 법제도적 대응에 관한 연구”, 「노동법학」 제85호, 한국노동법학회, 2023. 3, 267~268면 참조.

제2조. 노동 및 사회보장 감독 시스템에 적용되는 원칙

노동 및 사회보장 검사 시스템은 다음 원칙에 따라 구성 및 운영된다.

- a) 시민에 대한 서비스 제공의 효율성과 질.
- b) 다른 공공행정기관의 조정, 협력 및 참여를 통해 응집력있는 운영이 보장되는 단일하고 포괄적인 시스템적 개념.
- c) 기능적 전문화 및 프로그램된 행위(actuación)의 기준을 침해하지 않고, 이 법에 명시된 조건에 따라 사회 질서상의 모든 문제에 대한 기능 및 감독 행위의 통일성.
- d) 감독기능의 행사에 있어서 공정성, 객관성, 처우의 평등 및 비차별.
- e) 이 법에 규정된 바에 따라 노동사회보장 고위 감독단 및 노동사회보장 하위 감독단 공무원에 대한 사회질서상 감독기능의 유보.
- f) 프로그램된 업무 원칙 및 팀워크 원칙에 따라 활동의 조직 및 개발.
- g) 국가적 성격을 가진 단일 선택절차를 통해 노동사회보장 국가단 및 하위 감독단에 있어서 단일한 입직 및 소집.
- h) 감독시스템의 국가단의 공무원들을 위해 일자리 제공 과정에서 공공행정 기관 간의 이동성.
- i) 노동사회보장 감독 시스템에 부여되는 기능과 관련하여 가장 대표 노동조합들 및 사용자단체들의 제도적 참여.

제3조. 감독시스템에 속하는 직원들

1. 이 법에서 언급된 노동사회보장 감독은 전적으로 노동사회보장 고위 감독관단(Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social)에 소속된 높은 기술 수준과 국가 자격을 갖춘 직업 공무원에 의해 수행되어야 하며, 이들의 법적 지위와 복무 조건은 국제노동기구 협약 제81호 및 제129호에 규정된 기술적 독립성, 객관성 및 공정성을 그들에게 보장한다.

... 이하 생략.

제5조. 감독기능을 가진 인원의 국가단으로의 입직 및 직책 부여

1. 노동사회보장 고위 감독단으로의 입직 및 하위 감독단으로의 입직은 법률 및 기타 관련 규정에서 정한 요건을 충족하는 성년 연령의 스페인 국적자가 지원할 수 있는 공무원 입직에 관한 규정에 따라 경쟁시험(sistema de oposición)

을 통해 이루어진다.

... 이하 생략.

제8조. 권리

노동사회보장 감독 시스템의 직원은 공무원에게 일반적으로 설정되는 개인적·집단적 권리가 인정된다.

직무를 수행함에 있어 폭력, 강압, 위협 또는 부당한 영향력으로부터 보호가 보장된다.

제9조. 의무 및 행동강령

1. 감독 시스템의 직원은 일반적으로 공무원에게 설정된 의무들을 적용받는다.
2. 자신에게 부여된 업무를 성실히 수행해야 하며 헌법 및 기타 법률 체계에 따라 그리고 이를 준수하여 일반적 이익을 보호한다.
3. 직무수행에 있어 최대한의 완벽성을 준수해야 하며, 조사 대상자의 권한이나 직무수행에 지장을 주지 않으면서 조사 대상자의 활동을 가장 적게 방해하는 방식으로 노력해야 한다. 또한 자신에게 위임된 문서를 보관할 때 열심히 해야 한다.

제12조. 감독기능에 관하여

이 법에 정해진 바에 따라, 노동사회보장 고위 감독단 및 하위 감독단에 속하는 직원들에 의해 수행되는 감독 기능에는 다음의 것들이 포함된다.

1. 다음 영역에서 법규범, 단체협약 등의 준수에 관한 감시 및 요구에 관하여.
 - a) 노사관계
 - (1) 개별적·집단적 노사관계에 관한 규범
 - (2) 근로자대표에 대한 보호, 권리 및 보장에 관한 규범
 - (3) 처우와 기회에 있어서의 평등과 직장 내 차별금지의 보호 및 증진에 관한 규범
 - (4) 다국적 서비스(servicios transnacional) 제공의 틀에서 근로자 배치에 관한 규범
 - b) 노동위험 예방
 - (1) 노동위험 예방에 관한 규범 뿐만 아니라 이 분야에 있어서 근로조건에

영향을 주는 법적·기술적 규범

(2) 산업재해 조사 및 직업병 조사 기능의 행사

c) 사회보장시스템

(1) 사회보장제도의 적용, 신청, 가입, 등록, 철회, 기여금, 기여금 징수 분야에 관한 규범

(2) 실업급여, 활동중단수당, 사회보장 조치의 개선체계, 단체협약에 의한 보완 등을 포함하여 사회보장제도의 급여를 받고 향유하는 것과 관련된 규범

... 중략 ...

2. 기술적 지원에 관하여

a) 사회질서 규범을 더 잘 준수하도록 하기 위해 감독기능을 수행하는 동안 회사 특히 중소기업에 대해 정보 및 기술지원을 제공하는 것.

b) 근로자 및 그 대표에게 정보 및 기술적 지원을 제공하는 것; 제20조 제4항에 따라 근로자의 신고에 따른 감독 활동의 결과에 대한 통지: 감독활동을 통해 밝혀진 바에 따라 회사의 규정 위반에 의해 근로자의 권리가 영향을 받은 경우 권리 충족을 위해 행정적·사법적 경로를 알려주는 것.

... 중략 ...

3. 조정, 알선 및 중재에 관하여

a) 당사자가 수락한 경우 파업 기타 분쟁에 대한 조정 및 중재.

... 이하 생략.

제19조. 노동사회보장감독의 활동 범위

1. 노동사회보장감독의 활동 범위는 사회질서에 관한 규범의 준수에 대한 의무와 책임이 있는, 자연인, 공사 법인, 재산공동체 기타 법인격 없는 단체에까지 확대되며, 그 활동은 다음과 같이 수행된다:

a) 회사, 작업장 및 일반적으로 노동이 제공되는 장소, 비록 노동이 공공기관 또는 공공기관에 의해 규율되는 규범과 연결되거나 의존되는 고유한 법적 성격을 가진 공법적 단체에 의해 직접 지배되거나 관리하는 경우라고 할지라도 마찬가지이다. 노동감독의 활동은 또한 작업이 수행되는 회사, 작업장 또는 작업장에 위치하지 않더라도 근로자가 거주하거나 휴식하는 동안 머무를 수 있고 법규범, 단체협약 또는 고용계약에 규정된 의

무의 이행으로 사용자가 처분할 수 있는 구내, 주거지 또는 기타 승인된 장소에서도 이루어진다.

... 이하 생략.

4. 검토 및 시사점

대만이나 스페인의 경우 근로감독에 관한 독자적인 법률을 두고 근로감독의 취지와 목표, 근로감독기관의 조직 및 구성, 근로감독의 주요 기능과 권한, 근로감독관의 양성 및 역량 증진, 근로감독의 종류와 내용 등 노동관계법령 전반의 이행상황을 감시·감독할 수 있도록 최소한 입법적으로는 체계적으로 구축하고 있는 것을 볼 수 있다. 일본의 경우에도 독자적인 근로감독 관련 법률을 아직 제정하고 있는 것은 아니지만 노동기준법 기타 법령 등에서 최소한 우리나라보다는 상세히 규율하고 있는 것을 볼 수 있다. 최소한 감독기관의 조직적 구조 및 근로감독관의 지위와 임용에 관한 사항을 상세히 규율함으로써 근로감독의 위상을 높이고 있다.⁴⁵⁾

근로감독에 관하여 그 전반적인 주요 사항을 법률에 규정하는 것은 사업주 및 근로자에 대한 예측가능성과 법적안정성을 제고하여 근로감독이라는 국가행정의 근거를 강화하고 위상을 높여주는 것이다. 우리나라의 근로감독이 한단계 도약하기 위해서는 별도의 입법화가 요구된다고 보이며 이와 관련하여 주변 국가들의 입법적 상황을 참조하는 것은 반드시 필요하다.⁴⁶⁾

45) 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3, 172면.

46) 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 173면.

IV. 근로감독 법제화를 위한 입법이론

1. 규범제정에 관한 일반론

가. 개요⁴⁷⁾

인간에 대한 불신을 근거로 자의적·폭력적 지배를 배제하고 국민의 권익을 보장하기 위해 모든 국가작용은 법에 기하여 행하여져야 한다는 원리를 우리는 ‘법치주의(法治主義)’라 하는바, 이러한 법치주의는 연혁적으로 국가작용에 관한 법인 행정법 성립의 기본적인 전제조건이 되었고, 또한 현대 행정의 기본원리를 이루고 있다.

근대 이전은 ‘법의 지배’가 아니라 ‘인(人)의 지배’시대였다. 그래서 봉건영주 또는 전제군주가 포고·칙령 등의 규범을 통하여 통치할 때에도 이는 그 신민(臣民)만을 구속했을 뿐 영주 또는 군주 자신은 그 구속을 받지 않았다.

그러나 프랑스 혁명 이후의 근대국가에 있어서는 자유주의적인 권력분립원칙이 채택되고, 행정권의 활동도 법에 따라 행해져야 한다는 법치주의 원리가 점차 형성·발전되기에 이르렀다. 이러한 법치주의의 국가 행정 작용면에서의 표현인 법에 의한 행정 또는 법치행정의 원리는 기본적으로는 행정권도 법에 기속되며 위법한 행정작용에 대한 사법심사를 통하여 국민의 권익을 보장하는 것을 그 내용으로 하는 것이다.

이러한 법치행정의 원리는 국가에 따라 그 내용을 달리하면서 형성되고 발전하여 왔는데, 대륙법계 특히 독일에서는 법률에 의한 행정의 원리(Gesetzmäßigkeitsprinzip der Verwaltung)로, 그리고 영미법계 국가에서의 법의 지배원리(rule of law)로 형성·발전하여 왔다.

독일, 일본 등 대륙법계 국가에서 법치주의 또는 법률에 의한 행정의 원리가 주장·성립된 것은 국민의 자유와 권리를 보장하기 위해서였다. 그러나 이와 같은 법치행정의 기본이념과 목적은 입헌군주제와 ‘나치’ 시대를 겪으면서 그 본질적 목적에서 벗어나 행정의 형식만을 문제삼는 형식적 법치주의로 변질되는 과정을 겪

47) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 28~33면; 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2006, 172~174면 등 참조.

기도 하였다. 예를 들자면, 본래 법률에 의한 행정의 원리는 시민적 법치주의 내지 법치행정에 있어서 ‘법률의 법규창조력, 법률의 우위, 법률의 유보’ 등 3개 원칙을 그 내용으로 하고 있었으나, ‘나치’ 시대나 군국주의를 거치면서 법률의 실질적 내용은 문제되지 않고, 다만 행정권의 발동이 형식적으로 법률에 의하기만 하면 된다고 하여 법률의 근거만 있으면 어떠한 권력발동도 정당화되는 식의 형식적 법치주의로 나타났던 것이다.

한편, 영미에서 발달한 법의 지배는 자의적 권력의 지배에 대한 정당한 법의 지배라는 의미에서의 법의 절대적 우위, 법적 평등원칙, 인권에 관한 헌법원칙을 바탕으로 법의 이념을 인권보장에 두고 법의 실질적 내용도 인권보장을 목적으로 하는 실질적 법치주의를 지향하였다.

그리고, 제2차 세계대전 이후에는 독일, 일본 등에서도 종래의 형식적 법치주의에 대한 심각한 비판과 반성이 제기됨에 따라, 제도적으로 헌법에 상당히 포괄적인 기본권이 규정되고, 법률의 합헌성 보장제도로써 헌법재판제도가 도입되었고, 행정재판소를 사법기관화하는 등 실질적 법치주의의 기반이 마련되었다. 따라서 오늘날에는 실질적 법치주의가 일반화되었다고 볼 수 있다.

나. 실질적 법치주의

(1) 법치행정원칙의 일반적 적용

오늘날에는 행정조직이 국민생활에 미치는 영향을 고려하여 이를 법률로써 규정하도록 하는 것이 보통이다. 그래서 우리 헌법도 “행정각부의 설치·조직과 직무범위는 법률로 정한다.”(헌법 제96조)고 규정하고 있다. 한편, 공무원의 근무관계나 영조물이용관계 등과 같이 종래 그 주체에게는 포괄적 지배권이 인정되어 개별적 법률의 근거 없이도 일방적으로 명령·강제할 수 있는 것으로 파악되던 특별권력관계론도 오늘날에는 그 타당성이 부인되어 이 관계도 기본적으로는 법관계로서 원칙적으로 법치행정의 원리가 적용되는 것으로 보고 있다.⁴⁸⁾

48) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 33~34면 참조.

(2) 법률의 법규창조력

법률의 법규창조력이란 국가작용 중 법규(국민의 권리의무에 관한 새로운 규율)을 정립하는 입법은 모두 의회가 행하여야 한다는 원칙을 말한다. 헌법 제40조는 ‘입법권은 국회에 속한다.’고 규정함으로써 국회입법의 원칙을 선언하고 있다. 위임명령이 기술적인 견지에서 인정되고 있지만, 입법의 명령에의 위임은 구체적으로 범위를 정하여 행해져야만 하고, 포괄적 위임은 허용되지 않는다(헌법 제75조). 이런 점에서 법률의 법규창조력은 관철되고 있다고 볼 수 있겠다.⁴⁹⁾ 다만 오늘날에는 법규가 행정권에 의한 명령에 의해 창설되는 등 법률만에 의해 창설되는 것은 아니므로 법률의 법규창조력은 독자적인 법치행정의 원칙으로 인정될 수 없다고 보고, 법률의 법규창조력의 원칙을 법률유보의 원칙에 용해시키는 견해도 있다.⁵⁰⁾

(3) 법률 우위의 원칙

법은 행정에 우월한 것이며 행정이 법에 위반하여서는 안 된다는 원칙이다. 이는 두 가지의 의미를 가진다.

첫째, 행정은 법을 위반하여서는 안 된다. 법적 행위뿐만 아니라 사실행위도 법에 위반하여서는 안 된다. 행정은 법률뿐만 아니라 헌법, 법률, 명령, 자치법규, 법의 일반원칙 등 모든 법을 위반하여서는 안 된다. 또한 오늘날 실질적 법치주의 하에서 행정보다 우위에 있는 법은 헌법에 합치하는 합헌적 법이어야 한다.

둘째, 법의 우위는 법률의 행정입법에 대한 우위를 포함한다. 법규명령이 법률에 위반되는 경우 위법한 명령으로 법원 및 헌법재판소에 의한 직접·간접적 통제의 대상이 된다.

(4) 법률 유보의 원칙

법률유보의 원칙은 중요한 행정권의 발동에는 법령의 근거가 있어야 한다는 것을 의미한다. 법률우위의 원칙은 행정의 모든 분야에서 적용되지만 법률유보의 원칙에 있어서는 법률유보의 원칙이 적용되는 행정의 범위가 문제된다.

법률유보의 원칙에 관한 학설에는 첫째, 국민의 자유와 재산을 침해하는 행정작

49) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 20면 참조.

50) 홍준형, 「행정법총론」, 한울아카데미, 2001, 39면 참조.

용은 법률의 근거가 있어야 한다는 침해유보설, 둘째, 국민에 의한 행정을 실현하기 위해 모든 행정에는 법률의 근거가 필요하다고 보는 전부유보설, 셋째, 국민의 자유와 재산에 대한 침해행정뿐만 아니라 급부행정에 원칙상 법률의 근거가 있어야 한다고 주장하는 급부행정유보설, 넷째, 침해행정이나 수익행정이거나를 막론하고 모든 권력행정은 법률의 근거를 요한다는 권력행정유보설, 다섯째, 공동체나 시민에게 중요한 행정권의 조치는 침해행정뿐만 아니라 급부행정에 있어서도 법률의 근거를 요하고, 그 중요성의 정도에 비례하여 구체적인 규율을 하여야 한다는 중요사항유보설(본질성설)이 있다.⁵¹⁾

이러한 견해들 중 오늘날 가장 유력한 견해는 중요사항유보설이며 이는 우리 헌법재판소도 채택하고 있는 이론이다.⁵²⁾ 이 이론에 따르면 법률유보의 범위와 강도에 여러 단계가 존재하며, 매우 중요한 사항에 대해서는 모든 사항이 법률로만 정하여져야 하고 보다 덜 중요한 사항은 그에 비례하여 행정입법권에게도 입법권이 수권될 수 있고, 중요하지 않은 사항은 법률의 근거를 요하지 않게 된다. 또한 이 이론은 공동체에 매우 중요한 사항은 구체적 위임도 안 되며 법률로 정해야 한다는 점에서 의회유보의 원칙을 포함하고 있다.⁵³⁾

다. 체계정당성의 원리⁵⁴⁾

헌법재판소는 최근 판례에서 법치주의 원리로부터 도출되는 체계정당성의 원리를 인용하고 있다.⁵⁵⁾ ‘체계정당성(Systemgerechtigkeit)’의 원리란 ‘규범 상호간의 구조와 내용 등이 모순됨이 없이 체계와 균형을 유지하도록 입법자를 기속하는 헌법적 원리’를 말한다.

규범 상호간의 체계정당성을 요구하는 이유는 입법자의 자의를 금지하여 규범의 명확성, 예측가능성 및 규범에 대한 신뢰와 법적 안정성을 확보하기 위한 것이다. 다만 체계정당성 위반 자체가 바로 위헌이 되는 것은 아니고 이는 비례의 원칙이나 평등원칙위반 내지 입법의 자의금지위반 등의 위헌성을 시사하는 하나의 징후일 뿐이고, 위헌이 되기 위해서는 결과적으로 비례의 원칙이나 평등의 원칙 등 일

51) 박군성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 21~23면 참조.

52) 헌법재판소 1999. 5. 27.자 98헌바70 결정 참조.

53) 박군성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 23면 참조.

54) 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2006, 174~175면 참조.

55) 헌법재판소 2004. 11. 25.자 2002헌바66 결정 참조.

정한 헌법의 규정이나 원칙을 위반하여야 한다.

라. 법률 제정과 관련된 검토

(1) 개관⁵⁶⁾

입법자는 입법에 관한 권한을 행사함에 있어서 입법의 내용·형식 등 제반사항에 관하여 헌법에 의한 세부적이고 엄격한 구속을 받는 것이 아닌데, 이를 이른바 ‘입법자의 형성의 자유’라 한다. 입법자의 형성의 자유에는 입법자가 어떠한 입법내용을 담고, 어떠한 입법형식을 취하며, 어떠한 경로로 입법에 이르게 하고, 어떤 수단을 통해 입법목적 달성을 것인지 선택하는 것을 포함한다.

입법자는 법률을 제정하는 과정에서 스스로의 판단에 의해 헌법을 해석하고 합헌으로 인식되는 법률을 제정하게 되는데, 이렇게 해서 제정된 법률은 일반적으로 그 합헌성을 추정받게 된다.

그러나 입법자의 형성의 자유가 광범위하게 인정된다고 해서 이것이 무제한으로 인정된다는 것을 의미하지는 않으며, 입법자는 스스로 헌법의 원리·원칙·질서와 기본권을 존중하여야 하고, 이에 구속되어야 한다.

(2) 법률에 규정될 사항

오늘날 행정기능의 변화와 국민의 기본권 보장을 위한 법률유보의 영역확대 필요성과 다른 한편으로는 법률의 과잉화 현상과 행정작용의 보완·조화를 위하여 법률유보의 범위와 강도는 어느 정도여야 하는가라는 논의는 매우 중요한 자리를 매김하고 있다. 이러한 논의는 바로 어떤 사항을 어느 정도로 법률로 규정할 것인가의 문제와 연결된다.

이와 관련하여 법치행정 원리 및 대의민주주의 원리에 따라 본질적인 사항이나 내용의 결정은 행정권이 아닌 의회가 스스로 결정해야 한다는 본질성이론(Wesentlichkeitstheorie)이 제시되었고, 일정한 규율사항은 의회가 직접 형식적 의미의 법률로써 정하여야 하며 명령에 위임하여서는 안 된다는 의회유보의 원칙이 자리잡게 되었다.

⁵⁶⁾ 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 10~11면 참조.

의회유보의 원칙에 내재된 관점에서는 불가피하게 헌법상 법률제정기관인 의회가 직접 법률로써 규율하여야 하는 영역이나 사항과 명령에 위임할 수 있는 사항을 구별해야 할 필요성이 대두된다.

우리 헌법은 다른 법규범보다 법률에 대하여 높은 지위와 가치를 부여하고 있고, 제정절차 또한 복잡하게 구성하고 있다. 법률이 가지는 헌법상 지위의 우월성에 비추어 볼 때, 국가나 국민에게 중대한 영향을 미치는 사항은 의회가 직접 법률로 규율하여야 한다는 논리에 귀결하게 된다.

우리 헌법 또한 일정한 사항을 법률로 정하도록 하고 있는 다수의 개별규정을 두고 있다. 이와 같이 헌법에서 법률로 정하도록 한 사항의 경우 국회가 법률을 제정하여 규율해야 하는 것은 당연하지만, 헌법에 명시적인 규정이 없다고 하여도 다른 법규범보다 법률이 기본권 보호적 결정을 가져오기에 적합하기 때문에 국민의 자유와 권리에 관련된 중요한 규율과 통치조직과 작용에 관한 본질적 사항은 반드시 법률로 정하여야 한다.⁵⁷⁾

법률로 규율해야 할 국민의 자유와 권리에 관한 중요한 사항에 대하여 구체적으로 제시되는 내용으로는 첫째, 국가와 시민이 당사자로서 서로 대립하는 일면적 기본권 규율(개인의 기본권 영역에 대한 국가적 침해로부터의 예방적 기본권 보호할 필요), 둘째, 국가가 기본권 주체 상호간의 기본권 영역을 구획해 주어야 하는 다면적 기본권 규율(기본권 영역상 목적충돌의 필수적 이해조정과 결정을 도모할 필요), 셋째, 위 두 가지 요소가 포괄된 복합적 기본권 규율(상이한 정치적·사회적·세계관적·법적인 이익과 관점을 조정할 필요)은 법률로 정해져야 한다. 따라서 입법자에게는 일면적·다면적·복합적인 기본권 관계에서 현재 발생하고 있거나 미래에 초래될 수 있는 기본권 상충·충돌관계를 조화·조정하는 조정력, 문제해결능력, 중·장기적 안목이 요구된다. 근본적으로는 법률에서 정할 성질의 사항은 반드시 법률로 규율하겠다는 입법자의 입법내용에 대한 의지가 대단히 중요하다.⁵⁸⁾

(3) 법률 입안(立案)의 주요 준칙⁵⁹⁾

법률안의 입안은 그 입안의 결과가 기존 법체계 속에서 기능하면서 법질서를 형

57) 노호창, “기본소득의 법적 고찰”, 사회보장법학 제9권 제1호, 2020. 6, 164~165면.

58) 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 20~21면; 노호창, “기본소득의 법적 고찰”, 사회보장법학 제9권 제1호, 2020. 6, 165면.

59) 임중휘·박수철, 「입법과정론」, 박영사, 2006, 161~167면 참조.

성하는 또 하나의 범규범을 만들기 때문에 기존 법체계와 범형식을 전혀 달리하여 입안한다든지 또는 기존 법질서를 무너뜨리면서 입안되어서는 안 된다. 이런 측면에서 법률안을 입안함에 있어 참고해야 할 준칙이나 적용원리가 필요하다. 즉, 일정한 입법요구에 부응하는 데 필요한 적당한 범형식을 선택하거나 법적 규율에 필요한 법적 사실을 파악하고 선택하여 이를 법률안의 형식을 빌어 구성하는 것은 입법 기술의 문제인 것이다.

법률안의 입안에 있어 유념해야 할 주요 준칙은 크게 실체적 측면과 형식 및 체계적 측면으로 구분해서 살펴볼 수 있다.

실체적 측면의 준칙이란 법률안의 입안에 들어가기에 앞서 판단하여야 할 전제 사항(입법여건 또는 입법환경)이나 입법하고자 하는 내용과 관련된 준칙 내지 원리를 말한다.

첫째, 법률안의 입안에 앞서 입법 그 자체와 입법여건 또는 그 환경과 관련하여 검토하고 분석하는 준칙으로는 입법필요성, 사회적 성숙성, 적시성 등이 대표적이다. 입법필요성이란 과연 입법이 필요한지 하는 문제이다. 현실여건상 필요성이 요구되지 않는 입법을 하게 되면 그 법은 죽은 입법을 양산하는 결과를 초래한다. 사회적 성숙성이란 입법 그 자체에 대한 사회적 공감에 있는지 하는 문제이다. 따라서 사회적 성숙성이 결여된 때에는 입법시도가 좌절될 가능성이 커진다. 적시성이란 입법필요성과 사회적 성숙성이 충족되었다고 하더라도 어느 시점에 입법을 하는 것이 가장 큰 효과를 거둘 수 있는지 하는 문제이다. 적시성을 갖추으로써 입법수요를 충족시킨 적절한 입법조치라는 평가를 받게 되며, 필요한 입법이 늦어지는 경우 오히려 입법부작위로 인해 경제·사회발전을 못하게 발목을 잡는다는 비판을 받게 된다. 또한 법적용과 법해석의 공백을 초래하기도 한다.

둘째, 입법하고자 하는 내용에 대한 평가와 분석의 준칙으로는 합헌성, 실효성과 강제성, 경제성, 소관주의, 적용성, 연계성 등을 들 수 있다.

합헌성이란 입법하고자 하는 목적이나 내용이 명문의 헌법규정은 물론 헌법의 기본원리나 기본질서에 위배되지 않아야 하는 문제이다. 헌법재판소에서 과잉금지 원칙의 내용으로 제시하는 목적의 정당성, 방법의 적절성, 피해의 최소성, 법익의 균형성은 기본권 제한 입법의 합헌성 판단에 있어 중요한 기준이 된다.

실효성이란 입법의 내용이 현실에서 규범력을 발휘하고 본래 의도한 결과를 실현할 수 있는지 하는 문제이다. 따라서 실효성을 갖기 위해서는 입법된 강제적 규범이 사회구성원의 준수기대성을 확보하고 법집행상 일반국민들의 지지와 협조를

끌어 낼 수 있는 내용이어야 한다. 실효성과 밀접한 관련이 있는 것이 강제성이다. 강제성은 작위 또는 부작위의무의 준수를 강제하기 위해 벌칙(형벌, 과태료)을 가하는 직접적인 강제방식이 전형적이다. 그러나 오늘날 국가발전을 위해 국가기관·공공기관, 국민이 나아가야 할 방향과 기준을 제시하는 방침규정·훈시규정·조성법규의 증대는 종래의 강제방식보다 자발적 참여와 협력을 유도하기 위한 행정적·재정적 지원 등을 그 주요내용으로 하는 간접적 강제방식에 큰 관심을 불러일으키고 있다. 따라서 어떤 방식으로 강제성을 담보할지를 판단하는 것이 중요한 심사기준이 된다. 아울러 형벌에 의한 강제에 있어서는 헌법상 죄형법정주의, 즉 형벌은 형식적 의미의 법률에 규정하는 것이 원칙이고 부득이 하위법령에 위임하는 경우에도 모법에서 처벌대상 행위의 구체적 기준과 형벌의 종류 및 최고한도가 규정되어 있는지 반드시 검토하여야 한다.⁶⁰⁾

경제성이란 입법으로 수반되는 비용을 최소화하면서 입법으로 얻을 편익은 극대화하여야 한다는 문제이다. 입법목적 달성을 데 필요한 최소한의 수단을 동원하거나 최대한의 효과를 가져 오는 수단을 선택하여야 한다는 것이다. 법적 내용을 지나치게 상세하게 규정하는 경우 법운영의 탄력성을 저해하고 그 반대의 경우에는 불분명한 입법으로 집행자의 자의에 따라 법이 해석·운용될 수 있으며 이는 결국 법적 분쟁을 초래하게 되므로 입법경제를 감안한 신중한 선택이 요구된다.

소관주의란 헌법-법률-명령-조례-규칙 등 법규범단계에 맞게 내용을 선별하여 규정하여야 한다는 문제이다. 즉, 헌법에 규정할 사항을 법률에서 규정한다든지, 법률에서 규정할 사항을 행정입법으로 위임하는 것은 소관주의에 반하는 것이다. 따라서 소관주의를 벗어나는 경우 입법권의 한계이탈이라든지 포괄위임의 문제가 대두되게 된다.

적용성이란 언제부터 법률을 시행 또는 적용하는 것이 적당한지 하는 문제로서 입안의 실체에 있어서는 부칙과 관련된 사항이다. 입법하는 시점과 그 적용시점은 반드시 같아야 하는 것은 아니며 적용 시점은 현실적 여건을 고려하면서 법률이 집행가능한 시점으로 결정하여야 한다.

연계성이란 다른 법률(안)과의 관계를 어떻게 설정할지에 관한 문제이다. 입법하고자 하는 법률안과 내용상 유관한 다른 법률(안)이 존재하고 있는 경우에는 우선 해당 법률안과 다른 관련법률(안)과의 관계설정, 즉 어느 법률을 우선하여 적용할 것인지, 또는 어느 법률 혹은 조항을 배제할 것인지에 대한 판단이 필요하고, 다음

60) 헌법재판소 1991. 7. 8.자 91헌가4 결정 참조.

으로 법률안 상호간의 시행시점을 조정하여야 하는 것이다.

이와 같은 실체적 측면에 대한 면밀한 검토가 결여된 채 법률안이 입안되는 때에는 입법의도 자체가 무산되거나 비록 입법이 되었다고 하더라도 위헌문제가 대두되고, 때로는 부당한 입법 또는 현실성 없는 입법이라는 비판을 받게 된다.

법률을 입안함에 있어서는 입안하는 법률안이 일반적인 법형식을 갖추면서 그 내용이 기존 법체계와 충돌하거나 모순이 없어야 한다. 이런 측면에서 법률안의 입안시 그 형식 및 체계와 관련된 준칙을 살펴보면 형식적합성, 명확성, 일관성, 통일성 등을 들 수 있다.

형식적합성이란 입법목적에 적합한 입법형식을 채택하여야 한다는 것을 말한다. 즉 새로운 법률의 제정형식으로 할지 아니면 기존 법률의 개정형식으로 할지를 판단하여야 한다. 개정형식으로 하는 때에는 전부개정방식을 취할 것인지 또는 일부개정방식을 취할 것인지에 대하여 판단하여야 한다. 제정법률을 입안하기로 한 때에는 관련법률이 존재하는지 여부를 파악한 후 관계법률을 제정법률안에 흡수할지 여부도 결정하여야 한다.

그리고 법률안 형태를 일반법으로 할지, 특별법으로 할지를 선택하여야 하는데 가급적 특별법 형식은 피하는 것이 법체계 유지 차원에서 바람직하다. 이와 같은 측면이 결여된 경우에는 부적합한 입법이라는 문제를 야기한다.

명확성이란 법규정의 내용이 객관적으로 일의적인 해석이 가능해야 한다는 것이다. 그러나 명확성을 갖추었는지 여부를 판단하는 구체적 기준이 설정되어 있는 것은 아니다. 우리 헌법재판소 결정에서는 법률규정의 구성요건적 내용에 따라 국민이 자신의 행위를 결정지을 수 있는 정도의 명확성⁶¹⁾, 법률규정이 건전한 상식과 통상적인 법감정을 가진 사람에게 그 적용대상자가 누구이며 구체적으로 어떠한 행위가 금지되고 있는지 충분히 알 수 있는 정도의 명확성⁶²⁾, 명확성의 요구 정도는 그 규율대상의 종류와 성격에 따라 달라지지만, 국민의 기본권을 직접 제한하거나 침해할 소지가 있는 법규에는 구체성과 명확성의 요구가 강화된다는⁶³⁾ 등 견해가 제시되었다. 따라서 국민의 기본권 제한이나 기초적인 법률관계를 규정하는 법률안을 입안하는 때에는 명확한 법문표현이 되도록 주의하여야 한다.

일관성이란 하나의 법률안에서 규정하고 있는 내용이 논리적으로 모순이 없어야 한다는 문제이다. 따라서 일관성이 결여된 때에는 법률안의 규정내용 상호간에 충

61) 헌법재판소 1991. 7. 22.자 89헌가106 결정 참조.

62) 헌법재판소 1995. 5. 25.자 93헌바23 결정 참조.

63) 헌법재판소 1995. 11. 30.자 95헌바12·17병합 결정 참조.

돌이 야기된다.

통일성이란 법률안의 내용이 다른 법률의 규정내용과 조화를 유지하여야 한다는 문제이다. 즉, 법률상호 간의 규정내용이 일관성을 유지하여야 하는 것이다. 통일성이 결여되면 법률상호 간에 모순과 저축을 초래하게 된다.

마. 행정입법

(1) 개관

행정입법이란 행정기관이 정립하는 일반적·추상적 법규범이다. 법규범의 단계구조나 법치주의의 원칙상 입법권은 국회에 속하고, 특히 국민의 권리·의무에 관한 법규사항은 법률로 정하여야 할 것이나, 예외적으로 국가행정권에 행정입법권이 부여되어 있다. 예컨대, 대통령령, 총리령, 부령, 고시, 훈령 등이 그러하다.⁶⁴⁾

현대행정의 기본원리로서의 법치주의 또는 법률에 의한 행정의 원리는, 행정권의 발동을 국민의 대표로 구성되는 의회가 제정한 법률에 의하게 하여, 행정을 민의에 부응하게 하려는 것이다. 이러한 법치행정의 취지를 철저하게 실현하려면, 의회가 행정의 내용을 미리 법률로써 가능한 한 상세하게 규정하여 두는 것이 바람직하다.⁶⁵⁾

그럼에도 불구하고 오늘날 모든 국가에서는 행정입법제도가 널리 채택되어 있는바, 그 이유로서는 첫째, 현대 행정이 고도로 복잡하고 전문화·기술화되어 있어서 전문적·기술적 사항에 관한 규율은 행정권이 보다 적절히 할 수 있다는 것, 둘째, 의회의 심의에는 많은 시간이 소요되어 법률로써는 사회·경제·과학기술 등 행정대상의 급속한 변화에 민감하게 대응하기 어렵다는 것, 셋째, 일정 사항은 오히려 정치적으로 중립적인 입장에서 보다 객관적으로 규율할 수 있다는 것 등을 들 수 있다. 이러한 이유들로 인해 오늘날 법률은 행정작용이나 시책의 목적·요건·내용 등에 관하여 그 대강만을 규정하고, 그 세부적인 사항은 행정기관이 규율하도록 행정권에 위임하고 있는 경우가 적지 않다.⁶⁶⁾

이러한 행정입법은 그 성질과 효력에 따라 법규명령과 행정규칙으로 구분할 수 있고, 그 발령주체에 따라서 대통령령, 총리령, 부령으로, 그 성격에 따라서 위임명

64) 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2006, 916면 참조.

65) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 131면 참조.

66) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 132면 참조.

령⁶⁷⁾과 집행명령⁶⁸⁾ 등으로 구분하기도 한다.⁶⁹⁾ 한편, 위임명령과 집행명령을 법규명령의 종류로 보는 견해도 있다.⁷⁰⁾

이러한 구분 중에서 특히 법규명령과 행정규칙으로 구분하는 것이 중요하다. 법규명령은 행정권이 정립하는 일반적·추상적 규범으로서 국민의 권리·의무에 관련된 사항(법규사항)에 관한 일반적 명령을 의미한다. 그리고 행정규칙은 행정기관이 법규사항과 관련이 없는 사항인 행정부 내부의 조직·활동 등을 규율하기 위하여 행정기관의 고유한 권한에 의해서 발하는 명령을 말하는바, 그 내용에 따라서 조직규칙·근무규칙·영조물규칙 등으로, 그 형식에 따라서 고시·훈령·예규·지시 등으로 구분할 수 있다.

한편, 이러한 행정입법은 그 입법과정 면에서 보면 제정주체에 따른 구분이 특히 의미있는데, 대통령령, 총리령, 부령 등이 그러하다. 대통령령은 보통 시행령으로, 총리령·부령은 보통 시행규칙으로 불리는데 각각은 모두 위임명령과 집행명령을 포함하고 있다. 이하에서는 시행령, 시행규칙, 행정규칙으로 나누어 각각의 효력과 대상사항 등을 살펴보기로 하겠다.

(2) 시행령(대통령령)의 입법

대통령령은 법률에서 구체적으로 위임을 받은 사항과 법률의 집행에 필요한 사항을 정하지만(헌법 제75조) 법률은 그 밖에 총리령과 부령에도 위임을 할 수 있기 때문에(헌법 제95조) 어떤 사항을 하위법령에 위임할 때 그것이 대통령령에 위임할 사항인지, 총리령이나 부령에 위임할 사항인지를 구분할 필요가 있다. 대통령령에 위임할 경우 대통령령의 입법절차가 총리령이나 부령의 입법절차보다 훨씬 복잡하기 때문에 당해 법률안의 주무부처에서는 이를 꺼려하는 경향이 있다. 그러나 국정의 통일적 추진·집행을 위한 기본방침에 관한 사항이나 각 부처에 공통된 사항 등은 반드시 대통령령에 위임하여야 할 것이다.

67) 법률보충명령이라고도 할 수 있는 것으로서, 법률 또는 상위명령에 의하여 위임된 사항에 관하여 발하는 명령으로서 위임의 범위 내에서는 국민에 대해 새로이 권리·의무를 설정할 수 있다. 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 133면 참조.

68) 법률의 범위 내에서 그 실시에 관한 구체적·기술적 사항을 규율하기 위하여 발하는 명령이다. 행정은 법집행의 의무와 권한을 가지고 있다는 점에서, 집행명령은 법률의 명시적 규정이 없더라도 발할 수 있으나, 새로운 입법사항에 관하여는 규율할 수 없다. 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 133면 참조.

69) 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2006, 916면 참조.

70) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 133면 참조.

또한 법률안의 입법시 국회제출시한에 쫓겨 서두르다 보면 법률에서 직접 규정 하여야 할 사항까지 포함하여 대통령령에 광범위한 위임을 하는 경향이 있다. 즉, 법률안의 내용에 대한 관계부처 사이의 협의⁷¹⁾가 제대로 이루어지지 않을 경우 시간절약을 위해 대통령령에 위임하고 나중에 다시 논의하기로 하는 사례가 자주 발생하는 것이다. 이러한 경우 국회심의 과정에서 대통령령에 위임한 사항을 법률에 직접 규정하는 등 불필요한 위임이 이루어지지 않도록 면밀한 검토가 있어야 할 것이다.⁷²⁾

(3) 시행규칙(총리령·부령)의 입법

총리령은 국무총리가 소관사무에 관하여 법률의 위임, 대통령령의 위임 또는 직권으로 발령하는 것인데(헌법 제95조), 국무총리의 소관사무는 헌법에서 ‘대통령을 보좌하며 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할’하는 것으로 규정하였으나(헌법 제86조제2항) 이것만 가지고는 소관사무가 무엇인지 명확하지 못하다. 총리령을 행정각부의 통할차원에서 발령한다면 행정각부 소관사항에 대하여서도 발령할 수 있다고 하겠으며, 그렇다면 어떤 법률에서 부령(그 법률의 소관부처인 행정각부의 부령)에 위임하는 외에 총리령에도 위임할 수 있다고 하겠으나, 실제로 있어서는 행정각부 소관사항은 부령에 일임하고 총리령은 행정각부가 아닌 부처(법제처, 국가보훈처 등) 소관의 법률에 한하여 대통령령보다 하위에 있는 법령의 형식으로 부령에 상응하여 발령하는 것으로 하고 있다. 총리령은 이들 국무총리 소속하의 모든 처 소관인 법률의 하위법령으로서 발령하는 것이며, 따라서 부령과의 관계에서는 소관 면에서 서로 배타적이고 효력 면에서 동등한 효력이며, 행정각부의 통괄·조정과 관련된 업무에 한하여 그 업무의 성질상 다소 우월적 효력을 인정할 여지가 있을 뿐이라고 보아야 할 것이다.⁷³⁾

부령의 입법과 관련하여서는 부령의 성격이 헌법상 행정각부에서 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 발령하는 것이라는 점을 살펴볼 필요가 있다. 부령의 경우 그 성안(成案)을 해당 법률의 소관기관에서 담당하고 관계부처 협의·당정협 의·입법예고 및 규제개혁위원회 심사는 총리령의 경우와 동일하며, 법제처에 심사

71) 관계부처 협의는 예컨대, 예산관련사항은 기획재정부, 정부조직·지방자치관련사항은 행정안전부, 회계사항은 감사원이나 기획재정부, 별칙은 법무부 등과 이루어진다.

72) 임종휘·박수철, 「입법과정론」, 박영사, 2006, 325~326면 참조.

73) 임종휘·박수철, 「입법과정론」, 박영사, 2006, 330~331면 참조.

의뢰하면 이를 심사하여 법제처장의 결재를 받아 소관부처에 회신하고 소관부처는 자체에서 공포번호를 붙여 행정안전부에 공포의뢰를 하며, 행정안전부에서는 이를 관보에 게재함으로써 공포하게 된다. 여기에서 생각해볼 점은 부령은 행정각부에서 장관의 책임아래 발령하기 때문에 법제처 심사가 필수적인 것이냐 하는 점이다.

이는 우리와 가장 유사한 입법절차를 가지고 있는 일본의 경우에도 우리의 대통령령에 해당하는 정령(政令)까지만 내각 법제국이 심사하고 부령에 해당하는 성령(省令)은 해당 성(省)에서 자체적으로 발령하고 있기 때문에 제기된 문제라고 할 수 있다. 그러나 일본에서는 성령에 대한 헌법적 근거가 없는 반면 우리는 총리령과 같은 위치에서 부령이 헌법에 명시되어 있고, 그 성격 면에서도 법률의 직접적인 위임 아래 법률을 보충하는 효력을 가지고 있으며 이 점에서 대통령령과 본질적 차이가 없다는 사실을 주목해야 한다. 따라서 부령의 경우에도 입법통제의 측면에서 제3자적 위치에 있는 법제처의 심사가 필수적으로 요구되며, 특히 법률이나 대통령령의 입법절차가 복잡하고 법률이나 대통령령의 입법과정에서 원래의 정책의도를 관철시키기 어렵다는 것을 이유로, 그 절차가 비교적 간단한 부령에서 상위법령과 상충되거나 상위법령의 위임이 없는 내용을 규정하고자 할 경우도 있을 수 있기 때문에 법제처의 심사는 중요하다.

(4) 고시, 훈령, 지침 등 행정규칙의 개념 및 효력

행정규칙이라 함은 행정조직내부에서의 행정의 사무처리기준으로 제정된 일반적·추상적 규범을 말한다. 실무에서는 훈령, 고시, 지침, 예규 등이 행정규칙에 해당한다. 행정규칙은 통상 법적 근거없이 제정되고 법규가 아닌 점에서 법규명령과 구별된다.

행정규칙은 법령보다 구체적인 행정사무의 처리기준을 정하기 때문에 행정공무원은 법령보다도 행정규칙에 따라 행정권을 행사하는 경우가 많다. 그리하여 오늘날의 행정을 법에 의한 행정이 아니라 ‘행정규칙에 의한 행정’이라고 부를 정도로 행정규칙은 행정의 대외적 작용을 규율하는 규범이 되고 있다.⁷⁴⁾

그러나 행정규칙의 이러한 대외적 구속력은 사실상 구속력이며 엄밀한 의미에서의 법적 구속력은 아니다. 행정규칙이 대외적으로 법적 구속력을 갖는가 하는 문

74) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 188면 참조.

제는 별개의 문제이다.

행정규칙은 규율대상이나 내용을 기준으로 구분하면 조직규칙, 영조물규칙, 법령 해석규칙, 재량준칙, 법률대체적 규칙 등으로 구분할 수 있고, 형식상으로 분류하면 고시·훈령·예규·지침 등으로 구분된다.⁷⁵⁾

훈령(訓令)은 상급기관이 하급기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한의 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 발하는 명령을 말하고, 지시(指示)는 상급기관이 직권 또는 하급기관의 문의를 의하여 개별적·구체적으로 발하는 명령을 말한다.

예규(例規)는 법규문서 이외의 문서로서 반복적 행정사무의 기준을 제시하는 것을 말한다.

고시(告示)는 두 가지의 종류가 있는데, 하나는 행정기관이 일정한 사항을 불특정 다수인에게 통지하는 방법으로서의 고시이고, 다른 하나는 행정사무의 처리기준이 되는 일반적·추상적 규범으로서의 고시이다. 그런데 이 중 후자의 경우가 행정규칙에 해당한다.

행정규칙인 고시가 법령의 수권에 의해 법령을 보충하는 사항을 정하는 경우(예컨대, 행정규제기본법 제4조제2항)에는 법령보충적 고시로서 근거법령규정과 결합하여 대외적으로 구속력 있는 법규명령의 효력을 가진다.⁷⁶⁾

행정규칙과 관련해서 특히 쟁점이 되는 것은, 첫째, 형식은 법규명령이지만 그 실질이 행정규칙에 해당하는 ‘법규명령 형식의 행정규칙’과 둘째, 형식은 행정규칙이지만 실질적으로 법규명령과 마찬가지로 이른바 ‘법규적 성질을 가지는 행정규칙’의 효력이다.

법규명령 형식의 행정규칙의 효력에 대해서는 실무적으로 부령(시행규칙) 형식으로 제정된 경우와 대통령령(시행령) 형식으로 제정된 경우를 구분하고 있다. 예컨대, 부령 형식으로 제정된 제재적 처분(영업허가의 취소 또는 정지 등) 기준은 그 규정의 성질과 내용이 행정청 내부의 사무처리기준을 규정한 것에 불과하므로 행정규칙의 성질을 가지고 있고 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 것이 아니라 고 보는 것이 판례의 주된 경향이다.⁷⁷⁾ 다만 최근 부령으로 정한 재량권 행사의 기준을 그 형식에 따라 법규명령으로 본 판례가 있다.⁷⁸⁾ 다음으로 행정청 내부의

75) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 189면 참조.

76) 대법원 1999. 11. 26. 선고 97누13474 판결.

77) 대법원 1990. 1. 25. 선고 89누3564 판결; 1995. 3. 28. 선고 94누6925 판결; 1996. 9. 6. 선고 96누914 판결 등.

78) 대법원 2006. 6. 27. 선고 2003두4355 판결.

사무처리 규정의 하나에 해당하는 제재처분의 기준이 대통령령 형식으로 제정된 경우에는 이를 법규명령으로 보는 것이 대체적인 경향이며,⁷⁹⁾ 이 경우 제재처분의 기준을 정한 대통령령이 법규명령으로서 절대적 구속력을 가진다고 본 판례⁸⁰⁾와 최고한도를 정한 것으로 본 판례⁸¹⁾가 있다.

그리고 법규적 성질의 행정규칙에 대해서는 실무적으로 수권법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령으로서의 효력을 가진다고 본다.⁸²⁾ 다만 당해 행정규칙이 법령의 위임을 받은 것이어도 단순히 행정적 편의를 도모하기 위한 절차적 규정에 불과한 경우에는 법규적 성질을 띠지 않고 단순 행정규칙이라고 본 판례가 있다.⁸³⁾

바. 위임입법의 내용과 한계의 문제

(1) 도입

권력분립의 원칙상 입법권은 국회에 속하고 또 법치주의 원칙상 국민의 권리·의무에 관한 입법사항은 당연히 법률로 정해야 할 것이다(헌법 제37조). 그러나 예외적으로 헌법은 긴급한 필요가 있는 경우(헌법 제76조) 및 법률의 위임에 의하여 또는 법률을 집행하기 위하여 필요한 경우에 한하여 입법사항에 대해서도 행정부가 명령을 발할 수 있게 하였다(헌법 제75조). 즉, 헌법은 제75조에서 “대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다”고 규정하여, 대통령이 대통령령으로써 위임명령과 집행명령을 발할 권한이 있음을 규정하고 있는 바, 이것이 대통령의 명령제정권 또는 행정입법권이다.

그리고 행정입법 속에는 대통령령 이외에도 총리령, 부령, 위원회·독립기관의 규칙, 고시, 훈령, 통첩 등이 포함된다. 일반적으로 국민의 권리의무에 관한 사항을 법규사항이라고 하고, 이들 사항을 규정하고 있는 명령을 법규명령이라고 하는 바, 행정상 입법은 소위 ‘법규성(法規性)’의 유무를 기준으로 하여, 법규성을 가지는 법

79) 대법원 1997. 12. 26. 선고 97누15418 판결; 2001. 3. 9. 선고 99두5207 판결.

80) 대법원 1997. 12. 26. 선고 97누15418 판결.

81) 대법원 2001. 3. 9. 선고 99두5207 판결.

82) 대법원 1987. 9. 29. 선고 86누484 판결, 1992. 1. 21. 선고 91누5334 판결.

83) 대법원 2003. 9. 5. 선고 2001두403 판결.

규명령과 이를 가지지 아니하는 행정규칙으로 구별하는 것이 보통이다.⁸⁴⁾ 또한 행정입법은 그 성질·내용 등을 기준으로 하여 위임명령과 집행명령으로 구분되기도 하는바, 일반적으로 위임명령과 집행명령은 국민과 행정기관을 다 같이 구속하는 법규명령으로서의 성질을 가진다.

이하에서는 다양한 행정입법의 유형 중에서 특히 위임명령과 집행명령 그리고 법규명령과 행정규칙의 구별에 대하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.

(2) 위임명령과 집행명령의 구별

‘위임명령(Übertragene Verordnung)’이라 함은 헌법 및 법률의 위임에 근거하여 제정된 행정권의 명령이다. 헌법 제75조 전단에서는 “대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과에 관하여 대통령령을 발할 수 있다”고 하여 대통령의 위임명령제정권을 명시적으로 규정하고 있다. 위임명령은 법률에서 위임받은 사항에 대하여 사실상 법률을 대신하는 것이고 또, 실질적으로 법률의 내용을 보충하는 것으로 ‘보충명령’이라고도 한다.

위임의 형식에 있어서는, 포괄적·일반적으로 입법권을 위임하는 ‘일반적·포괄적 위임’과 법률이 특정사항에 대하여 개별적·구체적으로 위임의 범위를 정하여 위임하는 ‘개별적·구체적 위임’이 있으나, 민주국가의 헌법에서는 개별적·구체적 위임만이 가능하다(포괄위임입법 금지의 원칙). 왜냐하면 일반적·포괄적 위임은 사실상 국회입법의 원칙을 부인하는 것이 될 뿐만 아니라 행정권의 독재를 초래할 위험이 있기 때문이다. 따라서 헌법 제75조도 “구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항”이라고 규정하여 후자의 형식만을 인정하고 있다.

그리고 ‘집행명령(Ausführungs Verordnung)’이라 함은 법률을 집행하기 위해 필요한 사항에 관하여 행정권이 발하는 명령이다. 법률의 집행이라는 개념은 구체적인 사항에 대하여 법률을 적용하여 법률의 효력을 완성시키는 행위로 볼 수 있다. 헌법 제75조 후단은 “대통령은법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다”고 하여 대통령의 집행명령 제정권을 명시적으로 규정하고 있다. 원래 법률의 집행은 행정권의 고유권한에 속하는 것이기는 하지만, 법률

⁸⁴⁾ 법규(Rechtssatz)라는 용어는 독일에서 유래하였다. 절대군주제 하에서는 왕의 (행정)입법이 원칙적 입법 작용이었는데, 외견적 입헌군주제로 바뀌면서 왕의 (행정)입법 중에서 법률의 근거를 필요로 하는 것을 Rechtssatz라고 하였다. 박정훈, 「행정부의 구조와 기능」, 박영사, 2006, 164면 각주 46 참조.

집행에 있어서의 통일성과 형평성을 기하기 위해 법률의 집행을 위한 일반적 준칙을 정하고 있는 셈이다.

위임명령은 법률의 개별적 위임을 전제로 하는 명령이므로 법률에 대하여 종속성을 가진다. 따라서 상위 법률이 개정되거나 소멸하면 위임명령의 효력도 당연히 소멸하는 것이 원칙이다. 그러나 법률이 위임한 범위 내에서, 법률이 직접 규정하지 아니한 새로운 입법사항을 규정하는 것이 가능하고 이 점에서 집행명령과 구별된다. 집행명령은 특정법률의 집행에 관한 세칙을 정하는 것이므로 근거법령인 모법을 변경하거나 보충할 수는 없으며 모법에 없는 새로운 사항을 규정할 수도 없다. 집행명령도 상위법에 종속하는 점에서는 위임명령과 다를 바 없고, 따라서 상위법이 개정·폐지되어 집행명령과 모순저촉하게 되면 집행명령은 당연히 그 효력을 상실한다.⁸⁵⁾

그러나 집행명령도 위임명령과 마찬가지로 행정기관과 국민을 아울러 구속하는 효력을 가진 법규명령으로서의 성질을 가지고 있는 점에 있어서는 위임명령과 차이가 없다. 위임입법에 대한 한계의 문제로서는 먼저 위임입법의 범위 문제를 비롯하여 위임된 입법권의 재위임이 가능한지의 문제, 또 헌법이 규정하는 입법사항 내지 처벌규정의 위임이 가능한지 등 문제가 제기된다.

첫째, 위임입법의 범위 문제와 관련하여, 헌법 제75조는 “구체적으로” “범위를 정하여” 라고 한정하여 규정하고 있는바, 양자는 중복되는 것으로 보이기도 하지만, 앞의 용어가 뒤의 것을 다시 한정한 것이라 보는 것이 타당할 것이다. 여기서 “구체적”이라는 것이 위임의 종적 한계를 한정한 것이라면, “범위를 정하여”라고 한 것은 위임의 횡적 한계를 한정한 것이라고 할 수도 있을 것이다. 부연하면 포괄적·백지식 위임이 되어서는 안 된다는 것을 의미한다. 헌법재판소 결정례를 다음과 같이 참고할 수 있겠다.

“수산업법 제52조 제1항 제3호는 위임의 목적이 ‘어업단속·위생관리·유통질서 기타 어업조정’에 있음을 분명히 나타내고 있으며, 위임의 내용과 범위를 ‘조업구역, 어업의 시기와 포획·채취할 수 있는 수산동식물의 종류에 관한 제한 또는 금지’라고 구체적으로 확정하고 있으며, 이 사건 법률의 피적용자는 조업구역, 어업

⁸⁵⁾ 대법원 1989. 9. 12. 선고 88누 6962 판결 참조. “상위법령이 개정된 것에 그친 경우에는 개정법령과 성질상 모순·저촉되지 아니하고 개정된 상위법령의 시행에 필요한 사항을 규정하고 있는 이상, 그 집행명령은 상위법령의 개정에도 불구하고 당연히 실효되지 아니하고 개정법령의 시행을 위한 집행명령이 제정·발효될 때까지는 여전히 그 효력을 지속한다.”

시기, 포획·채취할 수 있는 수산동식물에 관한 제한을 대체적으로 예측할 수 있는 어업인들이고, 한편 끊임없이 변화하는 해양생태계를 규율대상으로 하는 수산업법은 다른 법률에 비하여 보다 탄력성을 요구하며, 또한 고도로 전문적이고 기술적이어서 수산자원보호, 어업조정이라는 입법목적을 효율적으로 달성하기 위하여 탄력성 있는 행정입법을 활용할 필요가 크다. 위 수산업법 조항은 위임사항의 내용과 범위를 나름대로 구체적으로 특정한 것이라 볼 것이고, 이로부터 대통령령에 규정될 사항이 어떤 것일지 대체적으로 예측할 수도 있다 할 것이므로 헌법 제75조에 규정된 포괄위임입법금지원칙에 위배되지 아니한다.”⁸⁶⁾

“이 사건 법률조항은 ‘약국관리에 필요한 사항’이라는 처벌법규의 구성요건 부분에 관한 기본사항에 관하여 보다 구체적인 기준이나 범위를 정함이 없이 그 내용을 모두 하위법령인 보건복지부령에 포괄적으로 위임함으로써, 약사로 하여금 광범위한 개념인 ‘약국관리’와 관련하여 준수하여야 할 사항의 내용이나 범위를 구체적으로 예측할 수 없게 하고, 나아가 헌법이 예방하고자 하는 행정부의 자의적인 행정입법을 초래할 여지가 있으므로, 헌법상 포괄위임입법금지 원칙 및 죄형법정주의의 명확성 원칙에 위반된다.”⁸⁷⁾

둘째, 위임명령에 있어서 법률에서 위임받은 사항을 다시 하급기관의 명령에 재위임하는 것이 가능한지가 문제될 수 있다. 법률이 대통령령에 위임한 사항을 아무런 조건 없이 재위임하는 것은 실질적으로 수권법의 내용을 변경하는 결과를 가져오므로 허용될 수 없을 것이다. 이와 관련하여 독일기본법은 제80조 제1항에서 “연방정부, 연방장관 또는 주정부는 법률에 의해서 법규명령을 제정할 권한을 위임받을 수 있다. 이 경우 위임된 권한의 내용, 목적 및 범위는 법률에 확정되어야 한다. 법규명령에는 그 법적 근거가 명시되어야 한다. 위임받은 권한을 다시 위임할 수 있음을 법률이 규정하고 있는 때에는 위임받은 권한의 위임을 위해 법규명령이 필요하다.”고 규정하고 있다. 그러나 우리 헌법 제95조에 의하면 대통령령의 위임에 의해 총리령·부령을 발할 수 있음을 규정하고 있는 것과 같은 취지로, 위임받은 사항에 관한 요강을 규정한 다음, 다시 세부적인 보충을 하위명령에 위임하는 것은 원칙적으로 가능하다고 보아야 할 것이다.

셋째, 헌법이 규정하는 입법사항 및 처벌규정의 위임이 가능한가 하는 점도 쟁점으로 거론될 수 있다. 먼저 헌법은 국적취득요건(제2조 제1항), 죄형법정주의(제

⁸⁶⁾ 헌재 1999. 2. 25.자 97헌바63 결정.

⁸⁷⁾ 헌재 2000. 7. 20.자 99헌가15 결정.

12조), 재산권의 수용 및 보상(제23조 제3항), 조세법률주의(제59조), 행정각부의 설치(제96조), 지방자치단체의 종류(제117조 제2항) 등을 법률로 정하도록 규정하고 있다. 이들 헌법규정은 상기 사항이 입법사항임을 명시한 것으로 볼 수 있고, 따라서 이들 사항에 대해서는 그 기본적인 내용이 반드시 법률로 규정되어야 하는 것은 당연하다. 그러나 전적으로 모든 사항을 법률만으로 규정하는 것은 사실상 불가능하고 따라서 일정한 범위 내에서 행정상 입법에 위임하는 것은 허용된다고 보아야 한다. 그리고 처벌규정의 위임 가능성 문제와 관련하여, 헌법상의 죄형법정주의는 명령에 대한 벌칙의 일반적 위임을 금지하고 있을 뿐만 아니라, 개별적으로 벌칙을 위임하는 경우에도, 법률이 범죄구성요건 및 벌칙의 내용을 구체적으로 규정할 것을 요구한다.⁸⁸⁾ 그러나 수권법률이 범죄구성요건의 구체적 기준을 정하여 위임하는 것, 또는 벌칙의 상한·하한을 정하여 위임하는 것은 일반적으로 허용된다고 볼 수 있다.⁸⁹⁾

한편, 집행명령은 특정법령을 시행하기 위해 필요한 구체적 절차와 형식 등을 규정하는 명령이기 때문에 이와 무관한 새로운 입법사항을 규정할 수는 없다.

(3) 행정입법의 종류와 통제

법규명령(Rechtsverordnung)과 행정규칙(Verwaltungsverordnung 또는 Verwaltungsvorschrift)의 구별의 문제는 종래 행정처분의 기준이 부령의 형식으로 규정된 경우, 이 규정의 법적 성질을 어떻게 파악해야 할 것인가 하는 문제를 통해 나타났다. 이에 대하여는, 종래 법규성을 인정하는 견해와 법규성을 부인하는

⁸⁸⁾ 대법원 1991. 10. 22, 91다1617, 수산자원보호령 제25조 제1항, 제31조 제1호는 모법의 위임 없이 부당하게 형벌의 범위를 확장한 것으로서 죄형법정주의의 원칙에 위배되고 위임입법의 한계도 벗어난 무효의 규정이다.

⁸⁹⁾ 대법원 1972. 9. 12, 72도1137, 수산업법 제48조(어업조정에 관한 명령) 제1항에서 수산동식물의 채포, 어획물 및 그 제품의 양륙, 매매, 처리에 관한 제한 또는 금지, 어구 또는 어선에 관한 제한 또는 금지 등과 사항의 대강을 정한 다음 11개 항목에 달하는 요강을 규정하고 이들에 대한 필요한 사항을 다시 대통령령으로 정할 것을 위임하고, 그 대통령령에는 필요한 벌칙을 둘 수 있는 길을 제2항에서 트고, 제3항에서 벌금형의 상한을 30만원으로 못 박아 규정하고 위 제48조 제1항에 따라 제정된 대통령령인 수산자원보호령은 그 제7조에서 어구사용금지구역과 기간에 관하여 상세하게 규정하고 제25조에서 그 제7조 등을 위반하여 어업을 영위한 자에게 30만원 이하의 벌금 또는 구류로 임하고 있다. 그렇다면 수산자원보호령에 관한 위 규정들은 그 모법인 수산업법 제1·2·3항의 위임범위를 충실히 지킨 규정들이요 또 위 법 제48조 제1항이 규정한 대통령령에의 위임은 특정사항에 관한 특정위임으로서 위임사항에 아무 제한 없는 포괄적 위임 내지는 백지위임이라고 볼 의심은 없다.

견해로 나뉘어져 상당한 논란이 있어 왔던 것이 사실이다. 이 문제와 관련하여, 대법원은 대통령령, 부령, 훈령 등의 형식에 구애받지 아니하고, ‘구속력 유무’에 따라 구속력이 있는 것은 법규명령, 구속력이 없는 것은 행정규칙이라는 식으로 구별해 왔다. 다만 대법원은 종전의 태도와는 달리 행정청의 처분기준을 정한 대통령령(주택건설촉진법 시행령 제10조의 3 제1항 [별표 1])에 대하여, 이 규정은 “규정 형식상 대통령령이므로 그 성질이 부령인 시행규칙이나 또는 지방자치단체의 규칙과 같이 통상적으로 행정조직 내부에 있어서의 행정명령[행정규칙]에 지나지 않는 것이 아니라 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 힘이 있는 법규명령에 해당한다고 할 것이다”고 판시한 때도 있었다.⁹⁰⁾

헌법은 제75조에서 위임명령으로서의 대통령령에 관하여 규정하고 있고, 또 제95조에서 위임명령으로서 총리령·부령에 관하여 규정하고 있다. 다만 이들 위임명령의 효력에 대하여는 헌법상으로는 법적 차이가 규정되어 있지 않다.

이와 관련하여 대법원은 여러 차례에 걸쳐 부령인 자동차운수사업법 시행규칙, 공중위생법 시행규칙, 도로교통법 시행규칙 등이 정하는 제제적 사무처리기준과 관련하여, 이들 규정이 비록 부령의 형식으로 되어 있으나 규정의 성질과 내용은 사업면허의 취소처분 등 사무처리준칙을 규정한 것에 불과하므로 그것은 행정규칙에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 것이 아니라고 판시한 바 있다.⁹¹⁾

오늘날 행정입법은 양적인 팽창과 질적인 중요성을 더해 가면서 국민의 생활관계에 미치는 영향을 점차 증대시키고 있다. 그러나 법규명령 등 행정입법은 법치주의의 예외적인 것에 해당하는 측면이 있기 때문에 자칫 국민의 자유와 권리를 침해할 위험이 존재한다. 따라서 국민의 권리와 자유를 보호하기 위해서는 행정입법에 대한 심사 및 규범통제가 필요하다.

이와 관련해서는 헌법 제107조 제2항에서 명령 또는 규칙에 대하여 대법원을 최종적으로 하는 법원의 심사권을 두고 있고, 법원조직법 제7조 제1항 제1호 및 제2호에서는 명령 또는 규칙이 헌법이나 법률에 위반하는 경우 대법관 전원 2/3이상의 합의체에서 이를 심판할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 이와 관련하여 대법원은 “여기서 말하는 명령 또는 규칙이라 함은 국가와 국민에 대하여 일반적 구속력을 가지는 이른바 법규의 성질을 가지는 명령 또는 규칙을 의미한다”고 판시한 바

⁹⁰⁾ 대법원 1997. 12. 26. 선고 97누15418 판결 참조.

⁹¹⁾ 예컨대, 대법원 1997. 5. 30. 96누5773 판결에서는, 도로교통법 시행규칙인 운전면허행정 처분기준이 외부적 구속력이 없는 단순한 행정규칙이라고 판시하고 있다.

있다.⁹²⁾ 그리고 법원에 의한 이러한 행정입법에 대한 통제는 구체적 규범통제만이 인정되고 있으므로 그 심사의 효력은 당해 사건에 대한 적용의 거부에 그친다.

2. 의무이행확보를 위한 수단의 입법 및 검토

가. 개관

국가가 법을 집행하고 목적을 실현하기 위하여 법규 또는 그에 근거한 국가작용에 의하여 국민에 대하여 일정한 의무를 부과하거나 일정한 행위를 금지하는 것을 내용으로 하는 경우가 적지 않다. 이때 국가작용이 그의 목적을 효율적으로 달성하기 위해서는 이러한 명령·금지 등의 의무위반 내지는 의무불이행을 방지하거나 사후에 준수·이행하게 하는 제도가 마련되어야 한다. 이것이 바로 법의 실효성 확보 또는 의무이행 확보의 문제이다. 이는 근로감독 분야의 규범에서도 마찬가지로 중요한 문제이다.

우리 법상 실효성 확보수단을 전체적인 차원에서 개관하면 우선 직접적 수단과 간접적 수단으로 나누어볼 수 있다. 직접적 수단에는 의무의 존재를 전제로 하는 강제집행과 의무의 존재를 전제로 하지 않는 즉시강제가 있다. 간접적 수단에는 형벌과 과태료가 있다. 강제집행에 속하는 것으로는 대집행, 직접강제, 이행강제금, 강제징수 등이 있다.

그리고 새로운 의무이행 확보수단으로 거론되고 있는 것으로 과징금, 위반사실의 공표, 공급거부, 관허사업의 제한 등이 있다.

이를 그림으로 나타내면 다음과 같다.

⁹²⁾ 대법원 1990. 2. 27. 선고 88재누55 판결. “명령 또는 규칙이 법률에 위반한 경우에는 대법관 전원의 2/3 이상의 합의체에서 심판하도록 규정한 법원조직법 제7조 제1항 제2호에서 말하는 명령 또는 규칙이라 함은 국가와 국민에 대하여 일반적 구속력을 가지는 이른바 법규로서의 성질을 가지는 명령 또는 규칙을 의미한다 할 것인바, 수산업에관한어업면허사무취급규정(수산청훈령 제434호)은 행정기관 내부의 행정사무처리기준을 정한 것에 불과하고 이른바 법규로서의 성질을 가지는 명령 또는 규칙이라 볼 수 없으므로 위 규정을 무효라고 판단한 이 사건 제심대상판결이 대법원 전원합의체에서 이루어진 것이 아니라 하더라도 법률에 의하여 구성되지 아니한 판결이라고 할 수 없다.”

직접적 수단	: 강제집행 - 대집행, 직접강제, 이행강제금, 강제징수 : 즉시강제
간접적 수단	: 형벌 : 과태료
새로운 실효성 확보수단	: 과징금, 위반사실공표, 공급거부, 관허사업제한 등

근로감독에 관한 규범에 있어서 의무이행 확보수단으로는 형벌과 과태료, 기타 수단으로 나누어볼 수 있다. 그런데 현재 선박안전 조업규칙 등에서는 의무이행 확보수단을 직접적으로 규정하고 있지 않고 관계 법령에 따른 조치를 취하도록만 하고 있는 실정이다.

따라서 이하에서는 위의 의무이행 확보수단들을 전반적으로 검토해보고자 한다.

현재 개별 법률들에서 규정되어 있는 형벌로는 징역, 벌금 등이 있고 그 밖의 제재 수단으로는 과태료, 과징금, 강제징수, 대집행, 직접강제, 위반사실의 공표, 관허사업의 제한 등이 있다.

강제징수의 경우는 직접적으로 강제징수라는 명칭으로 도입되어 있는 것은 아니고 각종 과태료 체납이라든가 과징금 체납에 대해 국세체납처분의 예를 따른다고 하여 국세징수법상의 절차를 준용하는 형태로 도입되어 있다. 그리고 관허사업의 제한도 직접적으로 관허사업의 제한이라는 명칭으로 규정되어 있는 것은 아니고 다양한 법률에서 일정한 요건 하에 지정취소, 등록취소, 영업정지, 영업허가 취소의 형태로 도입되어 있다. 위반사실 공표의 경우는 식품위생법 제84조의 규정에서 찾아볼 수 있다.⁹³⁾ 그밖에 대집행이라든가 직접강제, 공급거부의 경우에도 개별 법률에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 즉시강제의 경우는 특히 비상상황 하에서의 근로감독에 관련된 규범에서 다룰 만하다고 본다.

직접강제는 행정상의 의무 불이행이 있는 경우 직접 의무자의 신체나 재산 또는 이 양자에 실력을 가하여 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하는 강제집행의 수단으로서 국민의 기본권을 침해할 가능성이 매우 높다. 그래서 이는 반드시 법적 근거가 있어야 하며 출입국관리법, 식품위생법,⁹⁴⁾ 도로교통법 등에서 극

⁹³⁾ 구 식품위생법 제84조(위반사실 공표) 식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제72조, 제75조, 제76조, 제79조, 제82조 또는 제83조에 따라 행정처분이 확정된 영업자에 대한 처분 내용, 해당 영업소와 식품 등의 명칭 등 처분과 관련한 영업 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공표하여야 한다.

히 제한적으로만 인정되고 있으며, 대집행이나 이행강제금 등의 다른 수단에 의해서 목적을 달성할 수 없는 경우에 한해서만 예외적으로만 이용되어야 한다.⁹⁵⁾

즉시강제는 목전에 급박한 위해를 제거할 필요가 있으나 미리 의무를 명할 시간적 여유가 없을 때, 또는 성질상 의무를 명하여서는 목적달성이 곤란할 때에 즉시국민의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 작용을 말한다. 이는 예컨대, 경찰관직무집행법상의 범죄 제지, 도로교통법상의 주차위반차량 견인, 전염병예방법상의 전염병환자 강제격리, 검역법상의 검역조치 등을 말한다. 즉시강제는 국민의 기본권과 법치국가적 안전에 중대한 침해를 가져올 수 있기 때문에 법적 근거가 있는 것만으로는 부족하고 급박성, 보충성, 비례성, 소극성 등의 엄격한 요건 하에서만 인정될 수 있다.⁹⁶⁾ 군사적 비상상황 하에서의 안전조치 등이 충분히 즉시강제에 해당할 여지가 있다.

공급거부는 행정법상의 의무를 위반하거나 불이행한 자에 대하여 일정한 행정상의 서비스나 재화(예컨대, 전기, 수도, 가스 등)의 공급을 거부하는 행정조치를 말한다. 공급거부는 국민의 권익에 중대한 영향을 미치는 것이므로 개별법상의 법적 근거를 요함은 물론이다. 또한 공급거부는 의무위반 또는 불이행과 공급거부 사이에 실질적인 관련이 있는 경우에만 허용되며(부당결부금지 원칙), 비례성의 원칙에 위배되어서는 안 된다.⁹⁷⁾

94) 식품위생법 제79조(폐쇄조치 등) ① 식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제37조제1항 또는 제4항을 위반하여 허가받지 아니하거나 신고하지 아니하고 영업을 하는 경우 또는 제75조제1항 또는 제2항에 따라 허가가 취소되거나 영업소 폐쇄명령을 받은 후에도 계속하여 영업을 하는 경우에는 해당 영업소를 폐쇄하기 위하여 관계 공무원에게 다음 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.

1. 해당 영업소의 간판 등 영업 표시물의 제거나 삭제
2. 해당 영업소가 적법한 영업소가 아님을 알리는 게시문 등의 부착
3. 해당 영업소의 시설물과 영업에 사용하는 기구 등을 사용할 수 없게 하는 봉인(封印)

② 식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항제3호에 따라 봉인한 후 봉인을 계속할 필요가 없거나 해당 영업을 하는 자 또는 그 대리인이 해당 영업소 폐쇄를 약속하거나 그 밖의 정당한 사유를 들어 봉인의 해제를 요청하는 경우에는 봉인을 해제할 수 있다. 제1항제2호에 따른 게시문 등의 경우에도 또한 같다.

③ 식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 조치를 하려면 해당 영업을 하는 자 또는 그 대리인에게 문서로 미리 알려야 한다. 다만, 급박한 사유가 있으면 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 조치는 그 영업을 할 수 없게 하는 데에 필요한 최소한의 범위에 그쳐야 한다.

⑤ 제1항의 경우에 관계 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

95) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 472~473면 참조.

96) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 480~485면 참조.

97) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 503~504면 참조.

나. 행정처분 규정의 제정

(1) 허가 등

허가(許可)란 법규에 의한 일반적·상대적 금지를 특정한 경우에 해제하여 적법하게 일정한 행위를 할 수 있도록 허용해 주는 행정행위를 말한다.

이러한 명령적 행위로서의 허가는 학문상의 용어이고 사회가 다양화되어 각종 규제의 형태와 내용이 복잡해지면서 현실적으로 실정법에서는 특허·인가·승인·면허·지정·등록·신고 등 여러 가지 표현으로 사용되고 있으며, 그 본래의 이론적인 의미와 성격과는 부합하지 않는 경우가 많다. 따라서 해당 행정행위가 학문상의 허가에 해당하는지의 여부는 관계 법령의 규정이나 취지 등에 따라 구체적으로 판단하여야 한다.⁹⁸⁾

이론상의 허가과 특허의 개념 구분에 대해 통설은 허가는 인간의 자연적 자유를 대상으로 하여 이를 회복시켜 주는 행위로 명령적(命令的) 행위라고 하며, 특허는 특정 상대방을 위하여 새로이 권리를 설정하는 행위(공기업 특허·공물사용권의 특허 등), 능력을 설정하는 행위(공법인의 설립행위 등) 및 법적 지위를 설정하는 행위(공무원 임명·귀화허가 등)로 형성적(形成的) 행위라고 한다.

다만, 최근에 허가는 단순한 자연적 자유의 회복이 아니라 헌법상의 기본권을 적법하게 행사할 수 있게 하여 주는 행위, 즉 법적 지위의 설정행위이므로 형성적 행위로서의 성질을 갖는다고 주장하는 견해가 있다. 이 견해에 의할 경우, 허가는 이미 헌법상 인정되어 있는 자유권을 현실적으로 적법하게 행사할 수 있게 하여 주는 것이고, 특허는 새로운 법률상의 권리·능력 그 밖의 법적 지위를 설정하여 주는 행위라는 점에서 상대적이거나 차이를 구별할 수 있다.⁹⁹⁾

이에 따라 허가는 허가기준에 관한 관계 법률상의 요건이 충족되는 경우에는 행정청은 허가를 하여야 하는 기속(羈束)을 받게 되고, 특허는 국민에게 새로이 권리·능력 등을 설정하여 주는 행위라는 점에서 공익적 관점에서 특허 여부에 관한 행정청의 판단과 선택에 있어 폭넓은 재량이 인정되는 경우가 많다고 볼 것이다. 그러나 이는 특허가 바로 재량행위가 되는 것을 의미하는 것은 아니며 관계 법률의 규정방식에 따라 판단되어야 하므로, 법률안 입안 단계에서 허가기준의 범위 등을 구체적이고 명확히 규정하여 법률규정의 해석에 혼돈의 여지가 없도록 하여

⁹⁸⁾ 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 455면 참조.

⁹⁹⁾ 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 456면 참조.

야 할 것이다.

허가는 심사대상에 따라 대인적·대물적·혼합적 허가로 구분할 수 있다.

허가처분은 수익적 행정행위로서 상대방인 국민에게 이익을 부여하나 공익과 이익형량의 문제, 제3자의 이익침해가능성이 있는 경우 허가여부를 결정함에 있어 행정기관의 자의적인 판단을 방지할 수 있도록 법률에 구체적인 기준과 근거규정을 두고 이에 따르도록 하는 등 법률에 의한 행정의 원칙이 적용될 수 있도록 해야 한다.

그러나 모든 사항을 법률로 규율한다는 것은 불가능하고 행정수요에 탄력적으로 대응하여야 하는 현실상 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 허가기준의 세부요건을 하위법령에 위임하는 것을 인정할 필요가 있다. 이에 따라 허가에 관한 규정을 입안할 때는 허가기준의 일정요건을 명시하여 행정기관에게 허가처분의 판단근거로 삼도록 하고, 법치주의에 어긋나지 않도록 법률의 범위 안에서 필요한 경우 범위를 정하여 위임할 필요성이 있다. 특히 국민의 권리의무와 관계되는 입법사항에 있어서는 위임입법의 범위를 구체적이고 명확하게 규정해 행정기관의 자의적 판단으로 국민의 자유와 권리가 부당하게 침해되는 일이 없도록 하여야 할 것이다.¹⁰⁰⁾

(2) 취소

실정법상 취소는 허가 등의 처분 이후 해당 처분을 그대로 존속시키는 것이 본연의 목적에 반하거나 법률의 규정을 위반하는 사유가 발생한 때에 공공의 이익을 구현하고 적법한 상태를 확보하기 위하여 선행처분의 효력을 박탈하는 것이다.

행정기관은 행정행위의 상대방이 법률의 규정을 위반한 경우 영업정지, 시정명령, 시설폐쇄 등의 행정처분을 통하여 제재를 가하기도 하는데 취소는 다른 제재수단으로는 시정할 방법이 없을 때 행하는 가장 강력하고 최종적인 조치이다.

이러한 취소처분을 함에 있어서 법률에 명문의 규정을 두지 않고 행정기관이 자의로 취소를 할 수 있도록 한다면 허가 등을 받은 국민은 매우 불안한 지위에 놓일 것이므로 취소 처분을 하기 위하여는 법률에 일정한 사유가 있을 때 또는 일정한 요건에 해당하는 때에 허가 등을 취소한다는 명확하고 구체적인 규정을 두어야 한다.¹⁰¹⁾

100) 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 457면 참조.

101) 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008, 532면 참조.

허가 등의 취소를 규정할 때에는 근거규정 및 취소사유를 구체적으로 명시하도록 하고, 취소사유 중 부정한 방법으로 허가를 받은 경우, 결격사유가 발생한 경우, 영업정지기간 중에 영업을 한 경우 등의 중대한 위반행위는 당연취소사유로 하고, 그 밖의 위반행위에 대하여는 임의적 취소사유로 하는 등 탄력적 운용이 필요하다.

한편, 이와 같은 취소는 의무이행의 실효성 확보수단으로 보자면, 관허사업의 제한으로 볼 수 있다.

(3) 관허사업제한

관허사업의 제한은 행정법상의 의무이행을 확보하기 위하여 그 의무자에게 주어진 인·허가를 취소·철회·정지하거나 의무위반과 직접 관련이 없는 인·허가를 제한하는 것을 말한다. 현행법상의 예로는 조세채납자에 대한 관허사업의 제한과 위법건축물의 이용에 대한 관허사업의 제한 등을 들 수 있다. 관허사업의 제한은 의무위반자나 의무불이행자의 사업수행 자체를 위협함으로써 스스로 의무를 이행하도록 하기 위한 간접적인 의무이행확보수단이기 때문에 매우 실효성 있는 강제수단으로 보이기도 하지만, 의무위반과 정지·취소되는 사업과의 실질적인 관련성이 없는 경우 부당결부금지 원칙에 위반될 수 있다는 비판이 있다.¹⁰²⁾

(4) 집행벌(이행강제금)

집행벌은 비대체적 작위의무 또는 부작위의무를 불이행한 경우에 그 의무를 간접적으로 강제이행시키기 위하여 일정한 기간 안에 의무이행이 없을 때에는 일정한 이행강제금을 부과할 것을 계고하고 그 기간 안에 이행이 없는 경우에는 이행강제금을 부과하는 것을 말한다.¹⁰³⁾

이행강제금은 행정상 강제집행의 수단이므로 당연히 법적 근거가 있어야 한다.¹⁰⁴⁾ 다만 이행강제금에 대한 일반법은 존재하지 않고, 필요에 따라 개별법에서 극히 한정적으로 인정되고 있다.¹⁰⁵⁾

102) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 506~507면 참조.

103) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 462면 참조.

104) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 471면 참조.

105) 구 건축법 제80조, 구 농지법 제62조, 구 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제6조

(5) 과징금

과징금이란 원칙적으로 행정법규의 위반이나 행정법상의 의무 위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우에 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금을 말한다.¹⁰⁶⁾

과징금은 1980년 말 독점규제및공정거래에관한법률을 통해 처음으로 도입된 이래, 현재 석유사업법·도시가스사업법, 주차장법 등 40여 개의 법률에 규정되어 있으며 그의 법적 성격을 일률적으로 말하기는 어렵다.¹⁰⁷⁾

과징금은 금전적 불이익을 부과한다는 점에서는 벌금이나 과태료와 내용적으로 동일하지만, 의무위반행위로 인한 ‘경제적 이익의 환수’에 초점이 맞춰진 금전적 부담이라는 점에서는 벌금이나 과태료와 다르다. 그리고 행정적 제재라는 점에서 벌금과 다르다.¹⁰⁸⁾

과징금은 당사자에 대하여 금전적 부담이 되는 것이므로 법상 근거가 있어야 하며, 과징금에 대한 일반법은 존재하지 않고 필요에 따라 개별법에서 극히 한정적으로 인정되고 있다.¹⁰⁹⁾

한편 현재 노동관계에 관한 법령에서는 산업안전보건법에서 업무정지처분을 대신하여 부과하는 과징금(법 제160조), 의무위반에 대한 과징금(법 제161조) 등을 규정하고 있는바 근로감독에 관련하여서도 참고할 필요가 있겠다.

(6) 강제징수

강제징수는 일반적으로 행정법상의 금전급부义务的 불이행이 있는 경우에 의무자의 재산에 실력을 가하여 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하는 작용을 말한다. 이는 금전급부의 불이행에 대한 강제수단이며 국세징수법이 일반법의 위치를 차지하고 있다.¹¹⁰⁾ 그 밖에 개별법의 차원에서 강제징수가 규정되어 있고¹¹¹⁾ 과태료를 제재수단으로 규정하고 있는 법에서 과태료 체납에 대해 국세체납

및 제10조 등.

106) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 489면 참조.

107) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 499면 참조.

108) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 499면 참조.

109) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 500면 참조.

110) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 473~479면 참조.

111) 예컨대, 구 지방세법 제28조가 그러하다.

처분의 예에 따른다고 하고 있기 때문에 강제징수는 일반적으로 널리 이용되고 있다.

다만, 강제징수는 금전급부 의무의 위반에 대해 발해지는 제재수단이기 때문에 국가가 국민에게 명칭에 관계없이 금전급부 의무를 부과하는 모든 법률에서 이용될 수 있는 제재수단이다.

(7) 대집행

대집행은 행정상 강제집행의 한 가지로서 대체적 작위의무가 이행되지 않은 경우에 당해 행정청이 의무자가 할 일을 스스로 행하거나 또는 제3자로 하여금 이를 행하게 함으로써 의무의 이행이 있었던 것과 동일한 상태를 실현시킨 후, 그에 관한 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다(행정대집행법 제2조).

대집행은 대체적 작위의무의 불이행이 있는 경우 가능한 수단이지만, 그러한 불이행이 있다고 해서 곧바로 대집행을 할 수 있는 것은 아니다. 왜냐하면 다른 수단으로는 그 이행확보가 곤란해야 하며 당사자의 불이익을 최소화하기 위한 최소침해의 원칙이 적용되어야 하기 때문이다. 다만 이때의 다른 수단에는 형벌·과태료·민사상 강제집행은 포함되지 않는다.¹¹²⁾

(8) 위반사실공표

공표란 법상의 의무위반 또는 의무불이행이 있는 경우에 그의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용의 침해를 위협함으로써 법상의 의무이행을 간접적으로 강제하는 수단이다. 고액조세체납자 명단공개라든가 환경오염물질배출업소 명단공개가 그 예다.¹¹³⁾

공표는 일정한 사실을 국민에게 알리는 사실행위에 지나지 않으며 그 자체로서는 아무런 법적 효과를 발생시키지 않는다. 그러나 오늘날 의무위반자의 명단공개는 그들의 명예와 신용에 유형·무형의 불이익을 가져다줌으로써 상당히 실효성 있는 의무이행확보수단으로 기능할 수 있을 것이다.¹¹⁴⁾

공표는 비록 아무런 법적 효과도 발생시키지 않는 사실행위에 불과하지만 현실

112) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 465면 참조.

113) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 504-506면 참조.

114) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 504-506면 참조.

적으로 의무이행확보수단으로서 중요한 기능을 수행할 수 있으며 나아가 인격권이 라든가 사생활의 비밀과 자유에 대한 침해가 문제될 수 있다는 점에서 원칙적으로 법적인 근거를 필요로 하며, 공표가 경우에 따라서는 관련법상 비밀유지의무 위반 죄 또는 형법상 피의사실공표죄·비밀누설죄 등을 구성할 수 있다는 점에서 법적 제약을 받을 수 있다.¹¹⁵⁾

다. 벌칙(행정벌) 규정의 제정

국가는 행정목적 달성을 위하여 국민에게 각종 행정의무를 부과하고 그 실효성을 확보하기 위하여 위반이 있는 경우 벌칙(행정벌)을 과하기도 한다. 이는 근로감독에 관한 법률안에서도 예외는 아닐 것이다. 벌칙에는 크게 형벌(행정형벌)과 과태료(행정질서벌)의 두 가지가 있다.

벌칙은 과거의 의무 위반에 대한 제재를 직접적인 목적으로 하지만 간접적으로는 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 행정법상의 의무이행을 확보하는 기능을 가진다.

행정벌도 처벌이라는 점에서 형사벌과 다르지 않다. 따라서 죄형법정주의에 따라 행정벌에도 반드시 법률상 근거가 있어야 한다. 그리고 법률은 행정벌의 벌칙을 명령에 위임할 수 있으나, 일반적 위임은 허용되지 않고 ‘구체적으로 범위를 정하여’ 위임하여야 한다(헌법 제75조). 즉, 범죄구성요건 해당행위의 기준 및 행정벌의 최고한도는 반드시 법률에서 규정하여야 한다. 그 밖에 지방자치법에서는 조례로서 조례위반행위에 대해 과태료를 부과할 수 있도록 규정하고 있기도 하다.¹¹⁶⁾

(1) 형벌

행정상의 질서유지를 위하여 과하는 행정질서벌(과태료)과 대비되며, 행정벌의 대부분을 차지한다. 행정형벌도 형벌이므로 죄형법정주의에 따르며, 원칙적으로 형법총칙의 규정이 적용되고, 그 과형절차도 형사소송법의 절차에 의하는 것이 원칙이다.

그러나 행정벌의 특수성에 의하여 예외를 인정하는 경우가 많다. 예컨대, 고의, 범죄능력, 영업주의 책임 및 타인의 행위에 대한 책임(양벌규정), 공범, 누범, 경합

115) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 504~506면 참조.

116) 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003, 449면 참조.

법, 양형(量刑) 등과 관련하여 형법총칙을 배제하는 특례를 인정하는 경우가 있다. 특히 위법성 인식과 관련해서는, 행정법은 본래 반사회적·반도덕적인 것이 아니라 법률의 제정에 의하여 반사회적·반도덕적 행위가 되고 범죄로 되는 것이므로 위법성 인식가능성은 당해 형벌법규의 인식가능성에 의해 판단한다. 따라서 행정법에서는 형사법에 비하여 위법성 인식가능성이 없는 경우가 넓게 인정될 수 있다.¹¹⁷⁾ 그리고 과실행위와 관련해서 판례는 행정법에서 과실행위를 처벌한다는 명문의 규정이 있는 경우뿐만 아니라 관련 행정형벌법규의 해석에 의하여 과실행위도 처벌한다는 뜻이 도출되는 경우에는 과실행위도 처벌할 수 있다고 한다.¹¹⁸⁾ 그 밖에 행정법에서는 범죄행위자 이외에 사업주 개인이나 법인을 처벌하는 규정을 두고 있기도 하다.

그리고 과형절차에 있어서 정식재판의 전단계로서 통고처분(通告處分)을 과하는 경우가 있다. 현행법상 조세법·관세법·출입국관리사법·교통사법 등에 대하여는 통고처분이 인정되고 있다. 판례는 통고처분의 경우 행정법상 처분으로 보지 않는다. 왜냐하면 통고처분은 당사자의 임의의 승복을 발효요건으로 하고 있고 통고처분을 따르지 않는 경우 곧바로 법원의 심판으로 이행되기 때문이다.¹¹⁹⁾ 또한 즉결심판으로 형벌을 과하거나 보호처분을 하는 경우가 있고, 조세법·관세법 등에는 관계 공무원의 고발을 요하는 경우가 있다.

(2) 과태료

과태료는 행정법규 위반에 대해 가해지는 제재로서 그 본질은 행정질서벌(行政秩序罰)이다. 과태료는 형벌과 마찬가지로 법상 의무위반에 대한 제재를 통해 간접적으로 의무이행을 강제한다는 점에서는 공통점을 가지지만, 그 취지나 성질, 절차 등은 형벌과 다르다.¹²⁰⁾ 즉 형벌이 형사적 제재라면, 과태료는 행정적 제재이다. 그리고 법적 부대효과, 절차적 보호, 실현과정이 상이하며, 형벌의 경우 전과기록이 남는 반면, 과태료의 경우 전과기록이 남지는 않는다는 차이점이 있다.

한편, 종래 판례는 “과태료는 행정법규 위반이라는 객관적 사실에 대하여 과하여지는 제재이므로 반드시 현실적인 행위자가 아니라도 법령상 책임자로 규정된 자

117) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 478면 참조.

118) 대법원 1993. 9. 10. 선고 92도1136 판결.

119) 대법원 1995. 6. 29. 선고 95누4674판결; 헌법재판소 2003. 10. 30.자 2002헌마275 결정.

120) 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004, 488면 참조.

에게 부과되고 특별한 규정이 없는 한 원칙적으로 위반자의 고의·과실을 요하지 않는다”¹²¹⁾고 하면서 “다만, 위반자가 그 의무를 알지 못하는 것이 무리가 아니었다고 할 수 있어 그것을 정당시할 수 있는 사정이 있을 때 또는 그 의무의 이행을 그 당사자에게 기대하는 것이 무리라고 하는 사정이 있을 때 등 그 의무 해태를 탓할 수 없는 정당한 사유가 있는 때에는 이를 부과할 수 없다”¹²²⁾고 하였으나, 최근 질서위반행위규제법이 제정되어 법률상 의무의 효율적인 이행을 확보하고 국민의 권리와 이익을 보호하기 위하여 질서위반행위의 성립요건과 과태료의 부과·징수 및 재판 등에 관한 사항을 일반법적인 차원에서 규정하면서 동법 제7조에서 “고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다”고 책임주의를 명시하여 위의 판례의 태도가 합리적인 차원에서 입법으로 반영되었다.

질서위반행위규제법이 제정되기 이전에는 해당 분야의 개별법에서 당사자는 이의제기를 할 수 있고 이의제기가 있는 경우 부과행정청이 이의제기의 이유가 있다고 판단하면 과태료부과처분을 직권취소할 수 있고 이유가 없다고 판단하는 경우 관할법원에 통보하여 관할법원이 비송사건절차법에 따라 과태료 재판을 통해 처리하도록 하고 있었고¹²³⁾, 과태료에 대해서 이의제기 기간 내에 이의를 제기하지도 않고 또한 과태료를 납부하지도 않으면 국세채납처분의 예에 따라 징수되도록 개별법에서 규정하고 있다.

그런데 질서위반행위규제법이 제정되어 동법 제5조에서 “과태료의 부과·징수, 재판 및 집행 등의 절차에 관해서 다른 법률의 규정 중 이 법의 규정에 저촉되는 것은 이 법으로 정하는 바에 따르는 것”으로 규정하면서, 개별법에서 규정하고 있는 과태료 징수 및 채납절차 규정들은 현재 더 이상 적용되지 않게 되었고 과태료 부과·징수, 재판, 집행 등의 절차적인 부분들은 모두 질서위반행위규제법이 정하는 바에 따르게 되었다. 따라서 현재 개별법에 규정되어 있는 과태료 규정들은 그 의무위반 행위 규정만 효력이 있고 그 외 절차적인 부분들은 규정은 존재할지라도 효력은 없게 되었다.

라. 절차적 정의의 확보

국가권력이 국민의 권익을 제한하는 경우에는 적절한 절차를 가져야 하는데, 이

121) 대법원 1994. 8. 26. 선고 94누6949 판결.

122) 대법원 2000. 5. 26. 선고 98두5972 판결.

123) 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007, 488면 참조.

와 관련하여 우리 행정절차법은 처분절차, 신고절차, 입법예고절차, 행정예고절차, 행정지도절차 등을 규율하고 있다. 이러한 일반적인 절차 외에도 각 개별법령은 그 목적과 취지에 맞게 개별적인 절차들을 운용하고 있기도 한다.

근로감독 분야와 관련해서 침해적 처분이나 수익적 처분이 있는 경우 어떠한 절차들이 필요한지 문제가 되는데, 수익적 처분의 경우 처분기준 및 이유의 제시, 처분의 정정절차 등에 관한 내용이 중요하고, 침해적 처분의 경우 수익적 처분에서 언급한 것과 함께 처분의 사전통지, 의견제출, 청문, 공청회 등 절차가 중요할 것으로 본다.

그 밖에 형벌이나 과태료로 규율할 경우 타 법령에서 규정하고 있는 행정형벌 및 행정질서벌을 준거로 삼아 합리적으로 규율되어야 할 것이다.

V. 근로감독 법제화 관련 현행 규범의 검토

1. 현행 법령상 근로감독의 법적 근거 및 근거 규정의 특징

현재 우리나라에서 근로감독에 관한 법적 근거는 근로기준법이 근로감독관의 권한을 규정하는 방식으로 근거를 두고 있고 최저임금법에서도 그러한 방식을 채택하고 있음.

근로기준법 제102조(근로감독관의 권한) ① 근로감독관은 사업장, 기숙사, 그 밖의 부속 건물을 현장조사하고 장부와 서류의 제출을 요구할 수 있으며 사용자와 근로자에 대하여 심문(尋問)할 수 있다. <개정 2017. 11. 28.>

② 의사인 근로감독관이나 근로감독관의 위촉을 받은 의사는 취업을 금지하여야 할 질병에 걸릴 의심이 있는 근로자에 대하여 검진할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우에 근로감독관이나 그 위촉을 받은 의사는 그 신분증명서와 고용노동부장관의 현장조사 또는 검진지령서(檢診指令書)를 제시하여야 한다. <개정 2010. 6. 4., 2017. 11. 28.>

④ 제3항의 현장조사 또는 검진지령서에는 그 일시, 장소 및 범위를 분명하게 적어야 한다. <개정 2017. 11. 28.>

⑤ 근로감독관은 이 법이나 그 밖의 노동 관계 법령 위반의 죄에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 사법경찰관의 직무를 수행한다.

근로기준법 제105조(사법경찰관 행사자의 제한) 이 법이나 그 밖의 노동 관계 법령에 따른 현장조사, 서류의 제출, 심문 등의 수사는 검사와 근로감독관이 전담하여 수행한다. 다만, 근로감독관의 직무에 관한 범죄의 수사는 그러하지 아니하다.

최저임금법 제26조(근로감독관의 권한) ① 고용노동부장관은 「근로기준법」 제 101조에 따른 근로감독관에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 시행에 관한 사무를 관장하도록 한다.

② 근로감독관은 제1항에 따른 권한을 행사하기 위하여 사업장에 출입하여 장부와 서류의 제출을 요구할 수 있으며 그 밖의 물건을 검사하거나 관계인에게 질문할 수 있다.

③ 제2항에 따라 출입·검사를 하는 근로감독관은 그 신분을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

④ 근로감독관은 이 법 위반의 죄에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」로 정하는 바에 따라 사법경찰관의 직무를 행한다.

근로감독에 관하여 규정하고 있는 근로기준법이나 최저임금법에서는 근로감독의 근거, 권한, 내용 등을 직접 규정하고 있는 것이 아니라 근로감독관의 권한을 규정하는 방식으로 이를 대신하고 있다(이하 근로기준법 중심으로 봄).

근로감독의 개념이나 성격이 (일반)행정권한에 그치는 것인지 수사권한을 포함하는 것인지 법률 조문만으로는 불분명한 상태이다.

그런데 실제 근로감독의 개념, 근로감독의 종류, 근로감독의 내용 등에 대해서는 고용노동부훈령에 해당하는 ‘근로감독관집무규정’에 담겨있고 근로감독의 종류나 내용의 확장이 필요한 경우 ‘근로감독관집무규정’을 개정하는 방식으로 진행해 왔다.

‘근로감독관집무규정’상으로는 근로감독은 행정권한 및 사법경찰권(수사권한)까지 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 다만 이는 고용노동부를 구성하는 행정청 내부에서 상하 행정기관 간의 권한행사의 질서에 관한 규정에 불과하여 사법부나 다른 행정기관을 구속하는 효력은 없다.

근로감독관집무규정 제11조(사업장 근로감독의 정의) 이 훈령에서 사업장 근로감독(이하 "사업장감독"이라 한다)이란 감독관이 근로조건의 기준을 확보하기 위하여 사업장, 기숙사 그 밖의 부속건물을 현장조사하여 노동관계법령 위반 여부를 점검하고 법 위반사항을 시정하도록 하거나 행정처분 또는 사법처리하는 일련의 과정을 말한다.

근로감독관집무규정 제12조(사업장감독의 종류) 사업장감독의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정기감독: 제13조의 사업장근로감독종합(세부)시행계획에 따라 실시하는 근로감독 <개정 2013.10.15>

2. 수시감독: 사업장근로감독종합(세부)시행계획이 확정된 이후 정기감독계획에 반영하지 못한 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업장 또는 업종을 대상으로 별도의 계획을 수립하여 실시하는 근로감독 <개정 2019.8.30>

가. 동향, 제보, 언론보도 등을 통하여 노동관계법령 위반 가능성이 있다고 판단되는 사업장

나. 근로감독 청원 등이 접수되어 사업장 감독이 필요하다고 인정되는 사업장다. 제3장에 따른 신고사건을 처리하는 과정에서 해당 사업장의 다수의 근로자에 대한 노동관계법령 위반의 가능성이 있다고 판단되는 사업장

라. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 있는 사업장 또는 업종에 대하여 지방관서에서 자체 계획을 수립하거나, 본부에서 수시감독 계획을 시달한 경우 <개정 2023.7.24.>

3. 특별감독: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업장에 대하여 노동관계법령 위반사실을 수사하기 위해 실시하는 근로감독 <개정 2013.10.15>

가. 노동관계법령·단체협약·취업규칙 및 근로계약 등을 위반하는 중대한 행위로 인하여 노사분규가 발생하였거나 발생 우려가 큰 사업장 <개정 2016.3.8>

나. 상습·고의적 체불, 불법파견, 비정규직에 대한 차별적 처우, 폭언·폭행 및 직장 내 성희롱·괴롭힘 등 노동관계법령을 위반하는 중대한 행위로 다수의 피해자가 발생하거나 발생 우려가 있어 언론에 보도되는 등 감독 필요성이 상당한 사업장 <개정 2023.7.24.>

다. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 발생할 우려가 있는 사업장에 대하여 본부에서 특별감독계획을 시달한 경우 <개정 2023.7.24.>

근로기준법 등 법률상 근로감독관의 권한으로는 현장조사, 제출요구, 심문, 검진, 사법경찰관의 직무 등을 규정하고 있으나 이러한 업무들은 결국 위법 사유가 있을 시 행정절차 및/또는 형사절차로 이행하기 위한 전단계이기도 하다.

각 규정의 특징을 분석해보면, 근로기준법 제102조 제1~4항은 현장조사, 제출요구, 심문, 검진의 근거를 규정한 것으로서 이는 행정권한 행사로서 권력적·비권력적 사실행위, 하명 등의 근거들을 명시한 것이다. 특히 근로기준법 제102조 제1항의 심문(尋問)은 사람을 찾아서 질문하고 진술을 구한다는 뜻으로 형사소송절차에서 말하는 심문(審問)과는 구별되는 개념이다.¹²⁴⁾ 근로기준법 제102조 제1항, 제2항의 근로감독관의 권한사항은 ‘수사’가 아니라 ‘행정작용’의 성질을 갖는 것이므로 상대방이 현장조사 등을 거부하였을 때 근로감독관이 실력으로 상대방의 저항을 배제하고 필요한 조사를 할 수는 없다.¹²⁵⁾

그런데 노동관계법령들을 보면, 고용노동부장관의 권한으로서 자료제출, 보고, 질문 등에 관한 권한을 두고 있는 경우들이 많은데, 이에 따라 고용노동부 공무원은 관련 권한을 위임받아 행사할 수 있겠으나 이를 근로감독으로 보아도 좋은지 의문이 있다. 왜냐하면 근로기준법에서 ‘근로감독관의 권한’이라는 표현을 하고 있고 하위규범이긴 하나 훈령에서 근로감독의 개념에서 그 주체를 ‘감독관’으로 명시하고 있기 때문이다. 물론 구체적인 분쟁사례가 있는 경우, 사법부가 훈령에 구속되지는 않으므로 근로감독의 개념을 반드시 근로감독관의 권한 행사에 한정해야 한다는 해석으로 귀결되지는 않을 수도 있다.

근로기준법 제102조 제5항은 사법경찰관으로서의 근로감독관의 권한 소재를 명시한 것이다. 즉 근로감독관에게 사법경찰관으로서의 직무를 수행할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 이와 관련하여 근로기준법 제105조는 “노동 관계 법령에 따른 현장조사, 서류의 제출, 심문 등의 수사”라고 규정함으로써 근로감독관의 수사권을 다시 한번 더 확인해주고 있다.

2. 근로감독의 구체적 행위별 법적 성격

가. 행정지도

근로감독이라고 해서 권력적 작용만 존재하는 것은 아닐 것이다. 보다 건전한 노사관계 구축을 위하여 노사에 대해 지도를 하거나 법령 기타 제도에 대한 안내

¹²⁴⁾ 대검찰청, 「노동법 별칙해설 I」, 2019, 41면.

¹²⁵⁾ 대검찰청, 「노동법 별칙해설 I」, 2019, 41면.

를 할 수도 있을 것이다. 대체로는 비권력적 사실행위이고 법령상 근거가 필요하지 않은 경우가 일반적일 것이다.

행정지도라 하더라도 일정한 행위의 억제를 내용으로 하는 규제적 성격이 있거나 이해관계자 사이의 분쟁이나 경쟁의 조정을 내용으로 하는 조정적 성격이 있다면 반드시 법적 근거가 있어야 할 것이다. 예컨대, 노조법 제53조부터 제61조에 걸쳐 규정되어 있는 노동쟁의 조정¹²⁶⁾ 등을 예로 들 수 있다.

나. 시정명령

시정명령은 위법사항에 대해 그 시정을 요구하는 하명(下命)으로서 행정처분에 해당한다. 산업안전보건법의 경우 사전적·예방적 위험 방지 조치로서 다양한 시정 조치의 근거를 마련해 두고 있다. 그러나 근로기준법에서는 법령 위반에 대한 조치로서 일반적인 의미의 시정명령의 근거가 없고 따라서 근로감독관은 시정명령의 권한은 없다고 볼 수 있다.¹²⁷⁾

노조법에서는 노조규약, 노조결의, 노조처분, 단협외 위법 등에 대해 시정명령 근거를 마련해 두고 있으나 그 주체를 행정관청이라고만 규정하고 있을 뿐이다. 다만 하위규범에 의해 노조법상 행정관청에 근로감독관이 포함되는 것으로 보이긴 한다.¹²⁸⁾

현행 법령상으로도 보면, 근로감독관은 고용노동부 공무원에 속하고 고용노동부 공무원은 고용노동부장관의 권한을 위임받아 행사하는 것이어서 어떤 권한이 감독관만의 권한이나 아니냐 이런 문제들이 사실 현장에서는 명쾌하게 구분이 되기 어려울 것 같다.

다. 시정지시

근로감독관이 기업 현장에서 행사하는 권한 중 한 가지로 시정지시가 있다. 시

¹²⁶⁾ 노조법 제53조(조정외 개시) ① 노동위원회는 관계 당사자의 일방이 노동쟁의의 조정을 신청한 때에는 지체없이 조정을 개시하여야 하며 관계 당사자 쌍방은 이에 성실히 임하여야 한다.

② 노동위원회는 제1항의 규정에 따른 조정신청 전이라도 원활한 조정을 위하여 교섭을 주선하는 등 관계 당사자의 자주적인 분쟁 해결을 지원할 수 있다.

¹²⁷⁾ 단 고용노동부장관의 시정명령 권한은 있다. 근로기준법 제53조 제5항, 제96조 제2항 참조.

¹²⁸⁾ 일단 근로감독관집무규정 상으로는 근로감독관이 관여하는 것으로 되어 있다. 근로감독관집무규정 제21조 제1항 및 동 별표 4 참조.

정지시는 근로기준법상 근거는 없는 것이지만, 일반적으로 법령 위반에 대해 지도 감독권한이 있는 행정청 입장에서 시정지시를 내릴 수 있는 것으로 이해되는 것 같다.

이와 관련하여 고용노동부 훈령인 ‘근로감독관집무규정’은 시정지시의 근거와 관련 절차 사항들을 두고 있다.

시정지시에 대해서는 권력적 사실행위인지 비권력적 사실행위인지 논란이 있는데, 왜냐하면 근로감독관의 시정지시에 대해 사용자가 불응하면 사용자에게 수사가 개시되기 때문이다.¹²⁹⁾ 시정지시가 권력적 사실행위로서 처분성이 인정되는지 문제된 바가 있으나 하급심에서 시정지시는 행정지도 중 비권력적 사실행위에 불과한 것으로서 처분성이 인정되지 않는다고 판단된 바 있다.¹³⁰⁾ 시정지시는 불이행하게 되면 고발되어 수사가 개시되므로 수사절차에서 다투면 충분하다고 보는 취지인 것 같다.¹³¹⁾

라. 수사

수사는 권력적 사실행위로서 근로기준법에서 근로감독관의 권한사항으로 사법경찰관의 직무를 수행하도록 하고 있고 ‘사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률’(약칭 ‘사법경찰직무법’)에서 상세히 규정하고 있다.

사법경찰관의 직무는 결국 사법경찰관을 대신하여 관련 공무원이 노동관련 범죄 수사 및 관련 형사절차 진행에 협력하는 것인데, 이 과정에서는 형사법적 전문지

¹²⁹⁾ 근로감독관집무규정 제21조(감독결과 조치) ① 감독관은 사업장감독 결과 확인된 위법사항에 대하여는 별표3 및 별표4의 위반사항 조치기준에 따라 처리하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 범죄인지 또는 과태료 부과 조치를 하여야 한다. 다만, 본부에서 위반사항과 조치해야 할 내용 등을 고려하여 별도의 조치기준이 시달된 경우에는 이에 따른다.

... 하략 ...

¹³⁰⁾ 서울행정법원 2017. 11. 28.자 2017아12787 결정; 서울행정법원 2018. 3. 30 선고 2017구합83805 판결: “근로감독관집무규정 제21조 제1항 본문, [별표 3]에 의하여 이루어진 이 사건 각 시정지시는 행정청이 일정한 행정목적을 실현하기 위해서 사인 등 상대방에게 지도·권고·조언 등의 방법으로 일정한 행위를 하거나 하지 않도록 유도하는 비권력적 사실행위로서 그 자체로 일정한 법적 효과의 발생을 목적으로 하지 않고 다만 상대방의 임의적인 협력을 통하여 사실상의 효과를 발생시키는 것을 목적으로 하는 행정지도(행정절차법 제2조 제3호)에 해당한다. ... 행정청 내부에서의 행위나 알선, 권유, 사실상의 통지 등과 같이 상대방 또는 기타 관계자들의 법률상 지위에 직접적인 법률적 변동을 일으키지 아니하는 행위는 항고소송의 대상이 아니다(대법원 2015. 3. 12. 선고 2014두43974 판결 등 참조). 이 사건 각 시정지시는 항고소송의 대상인 처분에 해당하지 않는다.”

¹³¹⁾ 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 129면.

식과 수사역량이 요구되는 지점들이 존재한다.

마. 고발

근로감독관의 권한으로 고발 조치 또한 인정될 수 있을 것이다. 고발은 그 자체로 표시된 효과가 발생하는 것이 아니라 고발에 대해 규정한 법률 예컨대, 형사소송법상 고발에 관해 규정된 내용에 따라 효력이 발생하는 소위 준법률행위적 행정행위에 해당한다.¹³²⁾

근로감독관이 사법경찰관으로서 행할 수 있는 사항 소위 직접 수사대상이라든가 법령에서 고발사항으로 정한 것 외에도 근로감독관이 기업현장에서 어떤 위법 사항을 발견하였고 그것이 형사범죄로 취급할 수 있는 것이라면 경찰 및 검찰 등에 고발조치가 필요하고 또 가능하다고 본다.

3. 권한의 근거 간에 있어서 법치행정 관점의 문제점

법치행정의 원리상 행정권한의 행사나 수사권한의 행사는 국민의 법적 지위라든가 권리·의무에 영향을 주기 때문에 원칙적으로 법률에 그 근거를 둘 것을 요청하고 있고(법률유보의 원칙) 하위 규범에 관련 내용을 위임하는 경우에도 위임의 근거가 필요하고 또 위임을 하는 경우에도 포괄적으로 위임하지 못하도록(포괄위임입법의 금지) 하고 있다.

@ 헌법재판소 1999. 5. 27. 98헌바70 결정: “헌법은 법치주의를 그 기본원리의 하나로 하고 있으며, 법치주의는 행정작용에 국회가 제정한 형식적 법률의 근거가 요청된다는 법률유보를 그 핵심적 내용의 하나로 하고 있다. 그런데 오늘날 법률유보원칙은 단순히 행정작용이 법률에 근거를 두기만 하면 충분한 것이 아니라, 국가공동체와 그 구성원에게 기본적으로 중요한 의미를 갖는 영역, 특히 국민의 기본권 실현에 관련된 영역에 있어서는 행정에 맡길 것이 아니라 국민의 대표자인 입법자 스스로 그 본질적 사항에 대하여 결정하여야

¹³²⁾ 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 129면.

한다는 요구까지 내포하는 것으로 이해하여야 한다(이른바 의회유보원칙). 그리고 행정작용이 미치는 범위가 광범위하게 확산되고 있으며, 그 내용도 복잡·다양하게 전개되는 것이 현대 행정의 양상임을 고려할 때, 형식상 법률상의 근거를 갖출 것을 요구하는 것만으로는 국가작용과 국민생활의 기본적이고도 중요한 요소마저 행정에 의하여 결정되는 결과를 초래하게 될 것인바, 이러한 결과는 국가의사의 근본적 결정권한이 국민의 대표기관인 의회에 있다고 하는 의회민주주의의 원리에 배치되는 것이라 할 것이다. 입법자가 형식적 법률로 스스로 규율하여야 하는 그러한 사항이 어떤 것인가는 일률적으로 확정할 수 없고, 구체적 사례에서 관련된 이익 내지 가치의 중요성, 규제 내지 침해의 정도와 방법 등을 고려하여 개별적으로 결정할 수 있을 뿐이나, 적어도 헌법상 보장된 국민의 자유나 권리를 제한할 때에는 그 제한의 본질적인 사항에 관한 한 입법자가 법률로써 스스로 규율하여야 할 것이다. 헌법 제37조 제2항은 “국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있다”고 규정하고 있는바, 여기서 “법률로써”라고 한 것은 국민의 자유나 권리를 제한하는 행정작용의 경우 적어도 그 제한의 본질적인 사항에 관한 한 국회가 제정하는 법률에 근거를 두는 것만으로 충분한 것이 아니라 국회가 직접 결정함으로써 실질에 있어서도 법률에 의한 규율이 되도록 요구하고 있는 것으로 이해하여야 한다.”

그런데 근로감독관의 행정권한이나 수사권한에 있어서 관련 권한의 근거를 명시한 법률의 내용은 제한적인데 반하여, 근로감독에 관하여 대통령령에 위임된 바도 없고, 그 와중에 하위규범인 ‘훈령’에서 매우 넓게 행정권한 및 수사권한의 근거를 두고 있는 것은 법치행정의 원리상 문제가 있다고 보인다.

근로감독관집무규정 제2조(근로감독관의 직무) ① 근로감독관(이하 "감독관"이라 한다)은 다음 각 호의 직무를 수행한다. <개정 2009.3.20>

1. 노동관계법령과 그 하위규정의 집행을 위한 다음 각 목의 업무

- 가. 제11조에 따른 사업장 근로감독
- 나. 제33조에 따른 신고사건의 접수 및 처리
- 다. 각종 인·허가 및 승인

- 라. 취업규칙 등 각종 신고의 접수·심사 및 처리
 마. 과태료 부과
2. 노동관계법령 위반의 죄에 대한 수사 등 사법경찰관의 직무
 3. 노동조합의 설립·운영 등과 관련한 업무
 4. 노사협의회의 설치·운영 등과 관련한 업무
 5. 노동동향의 파악, 노사분규 및 집단체불의 예방과 그 수습지도에 관한 업무
 6. 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합의 설립·운영 및 사내·공동근로복지기금의 설립·운영 등과 관련한 업무 <개정 2023.7.24.>
 7. <삭제 2011.12.23>
 8. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자퇴직공제사업의 운영 등과 관련한 업무
 9. 「파견근로자보호 등에 관한 법률」(이하 ‘파견법’이라 한다)에 따른 파견사업의 적정한 운영과 파견근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무 <개정 2012.7.31>
 10. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 관한 업무
 11. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무 <신설 2019.8.30>
 12. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 "기간제법"이라 한다)에 따른 기간제 및 단시간근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무 <개정 2012.7.31>
 13. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제1장의2(고용상연령차별금지)의 적용과 위반사항 조치에 관한 업무
 14. 「임금채권보장법」에 따른 근로자의 임금채권보장에 관한 업무 <개정 2016.3.8.>
 15. 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 사업의 적정한 운영과 가사근로자의 근로조건 보호 등과 관련한 업무 <신설 2023.7.24.>
 16. 그 밖에 노동관계법령의 운영과 관련하여 고용노동부장관(이하 "장관"이라 한다)이 지시하는 업무
- ② 이 훈령에서 "노동관계법령"이란 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제6조의2제1항에서 정한 법률(「고용상 연령차별금지 및

고령자고용촉진에 관한 법률」은 제1장의2의 적용과 위반사항 조치에 관한 업무에 한정한다)과 그 하위법령을 말한다.

고용노동부 소관에 해당하는 여러 노동관계법령들의 경우 근로감독관집무규정에도 명시되어 있지는 않은 법령들이 다수 있을 것이다. 이러한 법령들의 경우 개별 법령에 근로감독 대상으로 규정된 바 없고 근로감독관집무규정상 근로감독의 개념이나 근로감독관 직무범위 등을 보아도 근로감독 대상으로 해석되기는 어려운 상황에 있다. 이런 경우 고용노동부 소관 법령이므로 일반적인 행정감독의 대상이 될 것이라 생각을 할 수는 있으나 이것이 근로감독과 어떻게 다른 것인지, 구별이 될 수 있는 것인지 의문이 없지 않다. 단순히 근로감독관 아닌 고용노동부 공무원이 수행하는 감독기능이면 근로감독이 아닌 것으로 보면 되는 것인지 단정이 쉽지 않다. 행정을 받아들이는 국민 즉 사업주나 근로자 입장에서 근로감독에 해당하는 행정과 그렇지 않은 행정을 구별할 수 있을리는 만무하기 때문이다.

4. 근로감독관의 수사권한에 속하는 법규범의 종류에 관한 법률상 규정

근로기준법은 제102조 제5항 및 제105조에서 “노동관계 법령”에 따른 수사권한을 규정하고 있지만 그 노동관계법령이 무엇인지는 근로기준법 기타 노동관계법에서 규정되어 있지는 않다. 노동관계법령이 무엇인지는 형사소송법과 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」(이하 ‘사법경찰직무법’)을 통해서 구체적으로 드러난다.

또한 형사소송법 제245조의10에서는 소위 특별사법경찰관리(이하 ‘특사경’)을 규정하고 있고 그 권한 행사의 관계를 규정하고 있다.

형사소송법 제245조의10(특별사법경찰관리) ① 삼림, 해사, 전매, 세무, 군수사기관, 그 밖에 특별한 사항에 관하여 사법경찰관리의 직무를 행할 특별사법경찰관리와 그 직무의 범위는 법률로 정한다.
② 특별사법경찰관은 모든 수사에 관하여 검사의 지휘를 받는다.

- ③ 특별사법경찰관은 범죄의 혐의가 있다고 인식하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거에 관하여 수사를 개시·진행하여야 한다.
- ④ 특별사법경찰관리는 검사의 지휘가 있는 때에는 이에 따라야 한다. 검사의 지휘에 관한 구체적 사항은 법무부령으로 정한다.
- ⑤ 특별사법경찰관은 범죄를 수사한 때에는 지체 없이 검사에게 사건을 송치하고, 관계 서류와 증거물을 송부하여야 한다.
- ⑥ 특별사법경찰관리에 대하여는 제197조의2부터 제197조의4까지, 제221조의5, 제245조의5부터 제245조의8까지의 규정을 적용하지 아니한다.

특사경은 소위 특수하고 전문적인 분야의 수사를 담당하는 사법경찰관리인데, 특사경의 직무 수행자와 직무범위 등에 대해서는 ‘사법경찰직무법’ 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 의해 규율되고 있다.

노동 분야의 근로감독관 역시 특사경에 속한다. 다만 근로감독관 이외에도 ‘사법경찰직무법’은 고용노동부 공무원 중에서 노동 분야의 특사경을 별도로 임명할 수 있도록 근거를 두고 있다. 사법경찰직무법은 근로감독관을 포함하여 특사경이 사법경찰관의 직무를 수행하는 직무범위를 규정하고 있다.

사법경찰직무법 제5조(검사장의 지명에 의한 사법경찰관리) 다음 각 호에 규정된 자로서 그 소속 관서의 장의 제청에 의하여 그 근무지를 관할하는 지방검찰청검사장이 지명한 자 중 7급 이상의 국가공무원 또는 지방공무원 및 소방위 이상의 소방공무원은 사법경찰관의 직무를, 8급·9급의 국가공무원 또는 지방공무원 및 소방장 이하의 소방공무원은 사법경찰관의 직무를 수행한다.

51. 고용노동부와 그 소속 기관에 근무하며 「고용보험법」에 따른 실업급여, 육아휴직 급여, 출산전후휴가 급여등의 부정수급에 관한 사무에 종사하거나 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발 훈련비용·훈련수당 등의 부정수급에 관한 사무에 종사하는 4급부터 9급까지의 국가공무원

사법경찰법 제6조의2(근로감독관 등) ① 「근로기준법」에 따른 근로감독관은 그의 관할 구역에서 발생하는 다음 각 호의 법률에 규정된 범죄에 관하여 사법경찰관의 직무를 수행한다. <개정 2010. 5. 4., 2010. 6. 8., 2019. 4. 30., 2021. 6. 15., 2022. 1. 4.>

1. 「근로기준법」
2. 「최저임금법」
3. 「남녀고용평등법」
4. 「임금채권보장법」
5. 「산업안전보건법」
6. 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」
7. 「노동조합 및 노동관계조정법」
8. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」
9. 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」
10. 「근로복지기본법」
11. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」
12. 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」
13. 「근로자퇴직급여 보장법」
14. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」
15. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」
16. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」
17. 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」
18. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(제6조 및 제7조만 해당한다)¹³³⁾
19. 「산업재해보상보험법」(제127조제3항제3호만 해당한다)¹³⁴⁾

② 지방고용노동청, 지방고용노동청 지청 및 그 출장소에 근무하며 근로감독, 노사협력, 산업안전, 근로여성 보호 등의 업무에 종사하는 8급·9급의 국가공무원 중 그 소속 관서의 장의 추천에 의하여 그 근무지를 관할하는 지방검찰청검사장이 지명한 자는 제1항의 범죄에 관하여 사법경찰관의 직무를 수행한다. <개정 2010. 6. 4.>

③ 「선원법」에 따른 선원근로감독관은 그의 관할 구역에서 발생하는 선박소유자와 선원의 「선원법」 또는 「근로기준법」에서 규정한 범죄에 관하여 사법경찰관의 직무를 수행한다.

사법경찰직무법에 의해 근로감독관의 수사 권한은 현재 19가지 법률에 미친다는 것을 확인할 수 있다. 본래 근로감독관의 수사 권한은 지금처럼 19가지 법률에 이르지 않는했으나 노동관계법령이 제·개정되면서 근로감독관이 담당해야 하는 법률이 점점 증가해왔다.

범죄수사라는 것은 일반적인 행정감독보다 그 범위가 훨씬 좁고 또 엄격한 행정작용인 것이기 때문에 근로감독관이 처음부터 범죄를 인지하고 수사를 하는 것은 아니라는 점, 즉 행정감독을 하던 중에 범죄정황을 발견하거나 아니면 진정이나 고소·고발 등을 통해 수사에 착수한다는 점 등을 생각해보면, 사법경찰직무법상 규정된 19가지 법률에 대해서는 근로감독관의 행정감독 권한도 미치는 것으로 보는 것이 맞는 것 같다.

다만 국가의 행정권한이 국민에게 미치기 위해서는 원칙적으로 법치행정의 원리에 따라서 이루어져야 한다는 측면에서 보면 법률에서 명시적 근거가 없는 상황인데 행정권한의 행사를 해도 되느냐라는 관점에서 보면 의심의 여지가 없는 것은 아니다. 특히 ‘근로감독관집무규정’이라는 하위규범에서 매우 넓게 근로감독관의 행정권한 행사의 근거를 두고 있는 것은 법치행정의 원리상 위법의 소지가 있는 것이 아닌가 한다.

근로감독의 대상 법률이 19가지나 되는데도 근로감독의 관련 근거가 근로기준법 및 최저임금법에만 단편적으로 적시되어 있다는 것은 법률 체계상으로도 맞지 않고 법치행정의 원리라는 관점에서 보았을 때 우리 근로감독은 법치행정의 원리가

133) 중대재해처벌법 제6조(중대산업재해 사업주와 경영책임자등의 처벌) ① 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

② 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호나목 또는 다목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제1항 또는 제2항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항 또는 제2항의 죄를 저지른 자는 각 항에서 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

중대재해처벌법 제7조(중대산업재해의 양벌규정) 법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제6조에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제6조제1항의 경우: 50억원 이하의 벌금

2. 제6조제2항의 경우: 10억원 이하의 벌금

134) 산업재해보상보험법 제127조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016.12.27, 2018.6.12, 2021.1.26>

3. 제111조의2를 위반하여 근로자를 해고하거나 그 밖에 근로자에게 불이익한 처우를 한 사업주

제대로 구현되어 있지 못한 것으로 보이고 법체계의 정합성에도 맞지 않는다고 판단된다.¹³⁵⁾

물론 소관 행정청은 소관 법률의 존재로 인해 당연히 소관 법률의 준수 여부에 대한 행정권한 및 감독권한을 가진다는 것에 대해서는 의문의 여지가 없을 것이고 이러한 관점에서 보면 지금처럼 근로감독에 관한 근거가 근로기준법에만 규정되어 있어도 아무런 문제가 없지 않느냐는 반론이 제기될 수도 있겠지만, 근로감독은 고용노동부의 다양한 권한 중에서 특별한 성격을 가지고 있다는 점, 근로감독에 관한 일반법이 없는 상태에서 근로감독에 관하여 근로기준법·최저임금법에서만 명시되어 있는 와중에 근로기준법 제정 이후 지금까지 많은 노동관련 법령들이 지속적으로 제정·시행되어 왔다는 점 등을 고려했을 때, 현재의 규범 상태는 타당하지 않다.

5. 근로감독관의 수사 관련하여 형사법적 역량의 필요성과 중요성

19가지나 되는 노동관계 법률에 대해 근로감독관이 행정감독권한과 수사권한을 함께 행사할 수 있고 또 행사해야 한다는 의미는, 근로감독관이 그 19가지 노동관계 법률 그 자체의 개별적인 지식과 법리를 익혀야 된다는 의미에 그치는 것이 아니라 행정기관으로서의 권한행사에 있어서 전문성과 역량을 갖추어야 한다는 의미에다가 수사기관으로서 권한행사에 있어서 고도의 형사법적 지식과 역량까지 요구된다는 것을 의미한다.

법적 근거 측면에서 의문점이 없지 않으나, 현행 규범상 실무적으로 근로감독관이 노동관계 법령의 위반 여부에 대해 폭넓은 행정감독 권한을 가지고 있는데 행정감독의 특성상 범죄 인지 및 수사로 이어질 수 있다는 점을 염두에 두지 않을 수 없고 그렇다면 결국 근로감독관의 역량 내지 전문성의 문제는 수사와 관련해서 특히 주목된다.

특정 지역, 특정 시설, 특정 분야에 대해서는 일반 사법경찰관리의 수사역량이나 수사활동이 미치기 어렵고 또 관련 전문지식이 부족하기 때문에 특정 영역에 있어서는 그 전문적 직무에 종사하는 자인 특사경에게 조사 내지 수사를 담당하도록 하고 검사의 지휘를 받도록 하는 것이 수사의 효율성과 적절성을 제고시킬 수 있

¹³⁵⁾ 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 146면.

다는 점에서 근로감독관이 특사경으로서 수사를 하는데 있어서 분명히 장점이 존재할 것으로 보인다.

다만, 특사경은 본래 일반 행정관리이므로 수사에만 전념하는 일반 사법경찰관리에 비해서 수사 자체에 관한 경험이나 수사 기법이 부족할 수도 있고 수사를 부담스러워 하거나 때로는 의욕이 넘쳐 과잉수사로 인한 수사권 남용이 우려될 수도 있으며, 또한 범죄 여부의 판단과 관련하여 형사법적 지식이 부족하여 판단을 그르치거나 그러한 형사법적 지식의 부족으로 인해 수사절차에서 미숙함이 드러날 수도 있다고 본다. 이런 점은 근로감독관의 경우에도 고려되어야 할 부분일 것이다.

특히 근로현장에서의 노동관계 법령 위반의 문제는 노동관계 법령 위반만의 문제로 그치는 경우도 있으나 일반 형사법적 쟁점과 연결되는 지점들이 존재하기 때문에 필연적으로 일반 형사법과의 연결 가능성을 외면하기 어려울 것이다.

일반적으로 형사절차는 어떤 사건이 발생했을 때 사람의 행위인지 아닌지 밝힌 후, 사람의 행위라고 판단이 되면 수사를 통해 그 범죄 유무를 판단하여 범죄 혐의가 인정되면 기소를 하여 법원의 판단을 통해 유무죄를 가리게 되는데, 즉 ‘범죄가 성립되느냐 아니냐’라는 실체적 판단과 이를 증명하고 판단하기 위한 절차적 과정이 전체적으로 하나의 통합된 그림을 그리게 되는 것이다. 범죄 유무의 판단은 행위자가 1인이면 수사를 통해 그에 대해 범죄성립요건의 구비 여부를 판단 및 기수인지 미수인지 등을 판단하여 기소를 하게 되고 행위자가 2인 이상이면 그 행위자 간의 관계(공동정범, 교사범, 중범)를 판단하는 과정이 추가된다.

범죄 성립 여부를 결정하기 위해서는, 어떤 범죄에 대해 행위만으로 성립될 수 있는 범죄인지 아니면 결과발생까지 필요한 범죄인지 범죄의 종류에 대한 지식이 필요하고, 범죄의 구성요건해당성이 있는지(객관적 요건으로서 행위, 결과, 인과관계와 객관적 귀속, 미수인지 기수인지 / 주관적 요건으로서 고의·과실, 피해자의 양해는 없었는지 / 행위자의 수 / 행위자가 자연인인지 법인인지 등등), 위법성이 조각될 수 있는지(정당방위, 긴급피난, 피해자의 승낙, 자구행위, 정당행위 등 존부), 책임이 조각될 수 있는지(고의나 과실에 대한 비난가능성 존부, 형사미성년자,心神장애 유무, 기대가능성, 법률의 착오 등 여부) 등 범죄 성립여부에 있어서 필요한 요건들을 분석하고 판단할 수 있어야 한다.

노동관계법령 위반의 죄도 이와 다르지 않기에 기본적으로는 이러한 형법적 체계의 틀을 가지고 접근해야 하므로 노동사건 수사를 위해 형법적 지식이 필요하고

근로감독관이 행정권한 행사의 결과 범죄 혐의를 포착하게 되면 수사절차로 이행되어야 하는 것이기 때문이다.

수사 단계에서는 수사의 조건(필요성, 상당성) 구비 여부, 임의수사(피의자신문, 참고인조사, 감정·통역·번역의 위촉, 공무소 등에의 사실조회 등)와 강제수사(압수, 수색, 체포, 구속, 검중, 통신조회, 통신사실확인조회, 통신제한조치, 사진촬영 등)에 대한 기본지식, 수사기법에 대한 기본지식 등 형사소송법의 양대 축인 수사와 공판 중 특히 수사에 관한 법령상 내용에 대해 잘 알고 있어야 인권을 침해하지 않고 적법절차에 따라 효율적이고 적절한 수사를 진행할 수 있다.

근로감독관이 종래 처리하던 노동관계법령 사건의 대부분은 임금(퇴직금 포함)채불 사건인데, 임금채불은 형사적으로는 근로기준법 위반의 죄에 해당하지만 그 본질은 민사상 채무불이행에 해당하고, 그렇다 보니 전형적인 형사범죄와는 그 구조가 다르고 전형적인 형사범죄의 처리와는 그 판단구조가 차이가 났던 것이 사실이다.

근로감독관이 주로 담당하는 사건과 검경이 주로 담당하는 사건의 종류와 성격이 다르기 때문에 수사 기법 등이 동일할 수는 없었겠지만 종래 문제되던 전형적인 다수의 사건인 임금채불 등과 같은 민사적 성격을 가진 사건들과는 달리, 최근 법제도 변화로 많이 문제되는 직장 내 괴롭힘 사건, 성희롱 사건 등과 같이 가해자·피해자가 존재하고 고의·과실·인과관계 등이 증거를 통해 입증되어야 하는 사건이라든가 비정규직 차별 사건과 같이 차별 여부 판단을 위해 관련된 사실관계의 정확한 조사가 필요한 사건, 파견법 위반이나 부당노동행위 사건과 같이 고의성 입증이 중요한 사건, 산업재해와 같이 인과관계의 사실적 규명이 중요한 사건 등의 경우 근로감독관의 수사는 검경의 수사에 근접해가고 있다고 보이고, 따라서 형사법 법리나 검경의 수사기법에서 도움을 받아야 하는 부분도 점점 커져가고 있다. 이를 위해 근로감독관의 역량 강화의 근거나 그 지원 근거 등이 법률상 요구될 수밖에 없다.

6. 경찰의 수사권과 근로감독관의 수사권의 경합 문제

일반적인 형사사건에서는 형사소송법 개정으로 검찰과 경찰 간의 수사권 조정이 이루어져 경찰이 우선적으로 수사권을 행사하게 되어 있다. 그러나 특사경 분야의

경우 여전히 검찰과의 관계에서 상하관계 및 지휘관계가 존재하고 처음부터 근로감독관이 수사를 시작하는 경우 종래대로 검찰과의 관계에서 사건이 처리되면 된다.

검찰청법 제4조 ① 검사는 공익의 대표자로서 다음 각 호의 직무와 권한이 있다.

2. 범죄수사에 관한 특별사법경찰관리 지휘·감독

그런데, 문제는 노동관련 사건인데도 당사자가 경찰로 진정하거나 일반 형사 문제와의 접점이 존재하는 등 어떤 사유로 인하여 경찰이 먼저 수사를 시작하거나 경찰도 함께 수사에 참여하게 되는 경우 무조건 근로감독관에게 이첩해야 하는지 문제될 수 있다. 이 과정에서 경찰과 근로감독관 간의 수사권 경합시의 해결은 어떻게 할 것인가 문제가 등장할 수 있다.

일단 노동관련 사건에서 경찰이 먼저 수사를 시작한 경우 해당 사건을 근로감독관에게 이첩해야 한다는 근거 규정은 없다. 실제로 경찰의 수사에 관한 실무적 지침을 규정하고 있는 「범죄수사규칙」(시행 2023. 8. 18., 경찰청훈령 제1094호, 2023. 8. 18., 일부개정)은 특사경의 직무범위에 속하는 범죄를 먼저 알게 된 경우 직접 수사할 수 있다는 내용과 해당 특사경과의 협조의무를 규정하고 있는데 그치고 있을 뿐이다. 그러니까 경찰의 기본적인 입장은 특사경 직무범위에 속하는 범죄도 기본적으로는 자신들이 모두 수사할 수 있는 것이라는 점을 드러내고 있는 것이다. 노동사건도 마찬가지라고 볼 수 있겠다.

범죄수사규칙 제3조(특별사법경찰관리 직무범위 사건을 직접 수사하는 경우) 경찰관은 특별사법경찰관리의 직무범위에 속하는 범죄를 먼저 알게 되어 직접 수사하고자 할 때에는 경찰관이 소속된 경찰관서의 장(이하 "소속 경찰관서장"이라 한다)의 지휘를 받아 수사하여야 한다. 이 경우 해당 특별사법경찰관리와 긴밀히 협조하여야 한다.

다만 근로기준법 제105조에서는 노동관계법령에 근거한 수사는 검사와 근로감독관이 “전담하여 수행한다”고 규정하고 있어서 일견 경찰의 수사권은 배제하는 것

으로 이해될 소지도 있다. 이런 관점에서 검찰은 노동관계법령 위반 범죄에 대해서는 경찰 즉, 일반사법경찰관은 수사권이 없다고 단정적으로 보고 있기도 하고¹³⁶⁾ 그런 취지에서 일반사법경찰관이나 다른 특사경이 노동관계법령 위반 범죄를 접수하면 관할 근로감독관이 속한 노동청으로 사건을 이송하여야 한다는 것이 검찰의 입장이기도 하다.¹³⁷⁾

그런데 이러한 검찰의 입장에 대해서는 의문이 있다. 근로기준법상의 ‘전담’ 규정은 어디까지나 노동분야의 전문가인 근로감독관에게도 수사권을 인정한다는 근거로 보아야 하는 것이지 경찰의 수사권 배제로 단정하는 식으로 해석하는 것은 타당하지 않다고 보인다. 왜냐하면, 근로현장에서, 예컨대, 사람의 사상(死傷)이 발생하거나 발견된 경우, 이것이 산업재해 내지 중대재해의 문제에만 해당하는 것이 아니라 일반 형사범인 업무상과실치사상의 문제에도 해당할 수 있는데, 전자의 경우 근로감독관의 영역이지만 후자의 경우 경찰의 영역에 속하기도 하기 때문이다. 실제로 근로현장에서의 어떤 사상이 근로와 무관한 단순한 업무상과실치사상인지 아니면 산업재해 또는 중대재해인지는 일단 수사를 해봐야 알 수 있는 것이고, 특히나 어떤 사상이 산업재해나 중대재해에 속하는 경우 이는 고의범일 수도 있고 과실범일 수도 있고 결과적 가중범일 수도 있는 것이어서 그 범위가 넓은데 그 사상이 과실범인 경우 형법상 업무상과실치사상죄에도 해당하기 때문이다.

특히 동일한 사고로 인한 업무상과실치사상 사건과 산업안전보건법 위반 사건은 사고 원인이 동일하고 산업안전보건법상의 조치의무 위반은 대부분 업무상 주의의무의 내용이 되며 동일한 피의자의 업무상과실치사 사건과 산업안전보건법 위반 사건은 상상적 경합관계에 있으므로 오히려 검사가 직접 현장을 검증하면서 초기부터 적극적으로 경찰과 근로감독관에 대한 일관되고 적극적인 수사지휘가 필요한 상황인 것이다.¹³⁸⁾ 그러나 검경 수사권 조정 이후 검찰의 경찰에 대한 수사지휘가 어렵게 되어 근로현장에서의 근로자의 사상(死傷) 사건에 대해 근로감독관이 수사하고 있다는 이유로 경찰이 입건없이 내사종결하는 경우가 발생할 수도 있는데 이에 대해 검사가 통제하기 쉽지 않을 수 있다.¹³⁹⁾

일단 검경 수사권 조정의 취지는 경찰의 수사권에 대한 존중으로서 경찰에 1차적 수사권을 부여하는 것이어서 기본적으로 경찰은 모든 범죄에 대한 수사권을 갖

136) 대검찰청, 「노동법 별칙해설 I」, 2019, 42면.

137) 대검찰청, 「노동법 별칙해설 I」, 2019, 43면.

138) 대검찰청, 「산업안전보건법 별칙해설」, 2020, 150면.

139) 대검찰청, 「산업안전보건법 별칙해설」, 2020, 151면.

는 것이며, 검찰의 직접 수사권은 부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사의 6대 중요범죄로 제한되었다가 현재 부패·경제 등 몇 가지 범죄로 축소되어 있는 상태이다.¹⁴⁰⁾

검찰청법 제4조(검사의 직무) ① 검사는 공익의 대표자로서 다음 각 호의 직무와 권한이 있다. <개정 2020. 2. 4., 2022. 5. 9.>

1. 범죄수사, 공소의 제기 및 그 유지에 필요한 사항. 다만, 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄의 범위는 다음 각 목과 같다.

가. 부패범죄, 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄

나. 경찰공무원(다른 법률에 따라 사법경찰관리의 직무를 행하는 자를 포함한다) 및 고위공직자범죄수사처 소속 공무원(「고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 파견공무원을 포함한다)이 범한 범죄

다. 가목·나목의 범죄 및 사법경찰관이 송치한 범죄와 관련하여 인지한 각 해당 범죄와 직접 관련성이 있는 범죄

경찰에 대한 수사지휘는 폐지되고 근로감독관에 대한 수사지휘는 잔존하는 상태에서 산업재해나 중대재해의 경우 경찰과 근로감독관 모두가 수사를 진행할 수 있는 상황에서, 검사가 경찰에 대한 수사지휘는 못 하지만 근로감독관에 대한 수사지휘는 할 수 있다는 것은, 경찰의 부당한 내사종결이 발생하지 않도록 검사가 근로감독관을 지휘하여 근로감독관이 경찰로 하여금 내사종결을 하지 않고 계속 수사를 하도록 요청해야 하는 상황의 발생을 낳게 되어 불협화음으로 이어질 가능성이 크다고도 보인다. 이는, 근로감독관은 검사의 지휘가 있으면 경찰과 공조수사를 해야 할 의무가 있다는 점에서¹⁴¹⁾ 단순한 기우(杞憂)에 그치지 않을 수 있을 것이다.

한편, 근로감독관이 근로감독 직무수행 중에 범죄(ex. 위법 사업주를 봐주거나 사업주로부터 금품 수수 등)를 저지르면 이런 경우 근로감독관이 개입할 여지가 없고 오로지 경찰의 수사대상이 된다. 근로감독관에게 수사권을 부여한 것은 노동

¹⁴⁰⁾ 검경 수사권 조정시 사법경찰직무법 개정을 하지 않은 것은 의문이다.

¹⁴¹⁾ 근로감독관집무규정(산업안전보건)[고용노동부훈령 제445호, 2023. 3. 17., 일부개정] 제35조(수사공조) 감독관은 재해조사결과 위법행위가 있으면 수사 및 송치를 신속히 진행하여 법령 위반의 죄가 「형법」등 다른 법 위반의 죄와 병합되어 공소가 제기되도록 하되, 검사의 지휘가 있으면 집무규정 제50조를 준용하여 경찰과 공조수사를 하여야 한다.

사건에 한정해서는 행정전문성을 존중하는 취지에서 인정해주는 것으로 보는 것이 타당하고 이것을 노동사건에 대한 경찰의 수사권 배제로 이해하면 곤란하다고 보이고 오히려 경찰과 근로감독관이 노동사건에 있어서 수사권 경합이 생기는 경우 수사의 효율성과 전문적 처리 등을 위하여 법률 제·개정 등 여러 수단을 통해 합리적인 방향으로 조정하는 것이 필요한 문제라고 생각한다.

사법경찰직무법이나 근로감독관집무규정상 근로감독관의 수사 대상으로 명시된 바 없는 고용노동부 소관 법령의 경우 그 위반에 관한 죄는 기본적으로 경찰의 수사 대상이 될 것으로 볼 수밖에 없다.

행정권한 행사의 결과 위법 발견은 결국 수사로 이어질 수 있는 것이라는 점에서 고용노동부 소관 법령 모두가 현행 법령상 근로감독관의 수사 범위에 속하는 것으로 규정된 것은 아니라는 점은 결국 기관 간의 권한 충돌 및 불협화음을 가져오는 요인이 될 수 있으므로, 향후 근로감독에 관한 별도의 근거 법률을 제정할 때 반드시 경찰, 검찰과의 관계에서 권한 조정 및 협조에 관한 명시적인 근거를 요구하는 지점이 된다.

7. 특별사법경찰관리 법제와 비교·검토

「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률(이하 ‘사법경찰직무법’이라 함)」은 근로감독관 이외에도 다양한 형태의 특별사법경찰관리를 규정하고 있다. 따라서 근로감독관의 법제화에 관한 논의에 있어서 근로감독관 외의 특별사법경찰관리에 대해서는 어떻게 규율을 하고 있는지를 비교·분석하여 시사점을 얻을 필요가 있다.

이를 위해 우선 사법경찰관리에 관한 일반규정이라고 할 수 있는 사법경찰직무법 및 관련 규정을 검토할 필요가 있다. 일반규정 외에 개별 특별사법경찰관에 적용되는 개별법 등에서 특별사법경찰관의 직무 등에 관한 규정을 두고 있는 경우가 있다. 이와 같은 법률 규정의 검토를 통해 근로감독의 법제화 방안에 대한 시사점을 얻을 수 있을 것이다. 특히 특별사법경찰관리는 특별사법경찰관리로서의 수사권한 외에도 행정조사 권한 등을 함께 가지고 있는 경우가 많은데, 이 점에서 근로감독관과 유사성이 있는 것으로 볼 수 있는 선원근로감독관과 세관공무원에 관한 규정을 검토하고, 사법경찰직무법이 규정하고 있는 특별사법경찰관은 아니지만

특별사법경찰관과 유사한 성격을 가지고 있는 세무공무원에 관한 규정도 함께 검토한다.

8. 특별사법경찰관리에 관한 규정 비교

가. 특별사법경찰관리에 관한 일반규정

특별사법경찰관에 관한 일반적인 근거규정은 「형사소송법」 제245조의10 제1항과 위 규정의 위임을 받아 제정 「사법경찰직무법」이다. 형사소송법 제245조의10 제1항은 “삼림, 해사, 전매, 세무, 군수사기관, 그 밖에 특별한 사항에 관하여 사법경찰관리의 직무를 행할 특별사법경찰관리의 직무를 행할 특별사법경찰관리와 그 직무의 범위는 법률로 정한다.”고 규정하고 있다.

사법경찰직무법은 제3조 내지 제10조에서 특별사법경찰관의 종류와 직무범위 및 관할 등을 규정하고 있으며, 제11조는 사법경찰관리등의 지명, 적격 여부 확인 등을 위한 범죄경력조회 및 수사경력조회를, 제12조는 사법경찰 직무 전담 부서 설치의 근거를 규정하고 있으나, 특별사법경찰관리의 지명이나 직무집행 등에 관한 사항은 규정하고 있지 않다.

특별사법경찰관리에 관한 구체적인 사항은 법무부예규 「특별사법경찰관리 지명 절차 등에 관한 지침」에서 규정하고 있는데, 위 지침은 지방검찰청 검사장이 사법경찰관리를 지명하는데 있어 지명 절차, 지명의 철회, 규약 등에 관한 사항을 규정하고 있으며, 조세범처벌절차법 시행령상 세무공무원, 지방세기본법 시행령상 범죄사건조사공무원, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제378조의 규정에 의한 조사공무원에 대하여 준용되도록 규정하고 있다.

특별사법경찰관리의 직무 집행에 관한 사항은 법무부령 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에서 정하고 있다. 위 규칙은 수사의 기본 원칙, 변호인의 조력, 수사의 개시와 내사, 수사사무의 보고 및 수사지휘, 임의수사와 강제수사의 절차, 고소·고발 사건의 처리, 사건의 송치 등에 관한 사항을 구체적으로 규정하고 있다.

나. 선원근로감독관에 관한 규정

사법경찰직무법 제6조의2 제3항은 선원법에 따른 선원근로감독관은 그의 관할 구역에서 발생하는 선박소유자와 선원의 선원법 또는 근로기준법에서 규정한 범죄에 관하여 사법경찰관의 직무를 수행한다고 하여 선원근로감독관을 특별사법경찰관으로 규정하고 있다. 선원법은 선원근로감독관의 근거(제125조), 선원근로감독관의 조사, 출입·검사 등에 관한 권한(제126조), 사법경찰관으로서의 권한과 경찰권의 제한(제127조), 비밀유지 등 업무수행에서의 기본원칙 등을 규정하고 있다.

선원법 제125조(선원근로감독관) ① 제123조에 따른 검사와 선원의 근로감독을 위하여 해양수산부에 선원근로감독관을 둔다.
② 선원근로감독관의 자격·임면 및 직무 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

선원법 제126조(선원근로감독관의 권한) ① ① 선원근로감독관은 이 법에 따른 선원근로감독을 위하여 선박소유자, 선원 또는 그 밖의 관계인에게 출석을 요구하거나 장부나 서류의 제출을 명할 수 있으며, 선박이나 그 밖의 사업장을 출입하여 검사하거나 질문할 수 있다.
② 제1항에 따라 출입·검사를 하는 경우에는 검사 개시 7일 전까지 검사 일시, 검사 이유 및 검사 내용 등에 대한 검사계획을 조사대상자에게 알려야 한다. 다만, 긴급히 검사하여야 하거나 사전에 통지하면 증거인멸 등으로 검사 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
③ 제1항에 따라 출입·검사를 하는 선원근로감독관은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 하며, 출입 시 성명·출입 시간·출입 목적 등이 표시된 문서를 관계인에게 내주어야 한다.
④ 선원근로감독관은 승무를 금지하여야 할 질병에 걸렸다고 인정하는 선원의 진찰을 의사에게 위촉할 수 있다.
⑤ 제4항에 따라 위촉받은 의사는 해양수산부장관의 진찰명령서를 선원에게 보여주어야 한다.

선원법 제127조(사법경찰권) ① 선원근로감독관은 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 사법경찰관의 직무를 수행한다.

② 이 법, 「근로기준법」 및 그 밖의 선원근로관계 법령에 따른 서류의 제출, 심문이나 신문(訊問) 등 수사는 오로지 검사(檢事)와 선원근로감독관이 수행한다. 다만, 선원근로감독관의 직무에 관한 범죄의 수사에 대하여는 그러하지 아니하다.

선원법 제128조(비밀유지 의무등) ① 선원근로감독관이거나 선원근로감독관이었던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

② 선원근로감독관은 직무를 공정하고 독립적으로 수행하여야 한다.

③ 선원근로감독관은 선원근로감독과 관련하여 직접적 또는 간접적인 이해관계가 있는 업무를 수행하여서는 아니 된다.

선원법 제125조 제2항의 위임에 따라 제정된 선원근로감독관규정은 선원근로감독관의 자격 및 임명(제2조), 배치(제3조), 직무(제4조), 직무교육(제5조), 증표(제6조), 활동비 지급(제7조)을 규정하고 있다.

선원근로감독관규정 제2조(자격 및 임명) 감독관은 해양수산부장관 또는 지방해양항만청장이 그 소속공무원으로서 다음 각호의 1에 해당하는 자중에서 임명한다.

1. 5급 이상의 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 6월 이상 해양수산부와 그 소속기관에서 근무한 자
2. 행정직·선박직 또는 수산직의 6급 또는 7급 공무원으로 2년 이상 해양수산관서(해양수산부·지방해양항만청 및 해양사무소를 말한다. 이하 같다)에서 근무한 자
3. 행정직·선박직 또는 수산직의 6급 또는 7급 공무원으로 1년 이상 해양수산관서에서 선원에 관한 업무를 담당할 경력에 있는 자
4. 해양수산관서에서 선원에 관한 업무를 2년 이상 담당할 경력에 있는 행정직·선박직 또는 수산직의 6급 또는 7급 공무원

5. 해양수산관서에서 5년 이상 근무한 행정직·선박직 또는 수산직의 6급 또는 7급 공무원

선원근로감독관규정 제3조(배치) ① 감독관은 해양수산부 및 지방해양항만청(지방해양항만청해양사무소를 포함한다)에 배치한다.

② 제1항의 규정에 의한 감독관의 배치에 관하여 필요한 사항은 해양수산부장관이 정한다.

선원근로감독관규정 제4조(직무등) 감독관의 직무, 감독요령등에 관하여 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

선원근로감독관규정 제5조(직무교육) ① 해양수산부장관은 매년 정기적으로 감독관에 대하여 직무교육을 실시하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 직무교육의 내용·실시시기 및 실시방법등 필요한 사항은 해양수산부장관이 정한다.

선원근로감독관규정 제6조(증표) ① 해양수산부장관 및 지방해양항만청장은 감독관의 신분을 표시하는 증표를 발급한다.

② 제1항의 규정에 의한 증표의 발급에 관하여 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

선원근로감독관규정 제72조(활동비 지급) 감독관의 직무를 행하는 자에 대하여는 예산의 범위안에서 활동비를 지급한다.

선원근로감독관규정 제4조는 감독관의 직무, 감독요령등에 관하여 필요한 사항을, 제5조는 직무교육의 내용·실시시기 및 실시시기 등을 해양수산부장관이 정하도록 위임하고 있다. 위와 같은 위임에 따라 제정된 선원근로감독관직무규칙은 감독관의 직무(제2조), 감독관의 관할(제3조), 감독관에 대한 확인·지도(제4조), 감독요령(제5조), 출입검사 계획에 관한 사항(제6조), 출입검사 결과 등의 보고(제7조), 피의자구속 또는 관계서류와 증거물을 검사에게 송부한 때의 보고(제8조), 재해의 보고(제9조), 증표 발급(제11조)을 규정하고 있으며, 제2조 제2항은 감독관이 선원법 제127조에 따라 사법경찰관의 직무를 행할 때에는 특별사법경찰관리 직무규칙

에 따른다고 규정하고 있다.¹⁴²⁾

선원근로감독관직무규칙 제2조(직무) ① 감독관은 「선원법」(이하 “법”이라 한다) 제126조 및 제127조에 따른 직무를 행하는 외에 해양수산부장관 또는 지방해양항만청장의 명에 의하여 선원의 근로조건개선과 노무관리에 관한 지도를 행한다.

② 감독관이 법 제127조에 따라 사법경찰관의 직무를 행할 때에는 「특별사법경찰관리 직무규칙」에 따른다.

선원근로감독관직무규칙 제3조(감독관의 관할) ① 해양수산부에 배치된 감독관(이하 “본부감독관”이라 한다)은 전국의 선박소유자 및 선원에 대하여 제2조의 규정에 의한 직무를 행한다.

② 지방해양항만에 배치된 감독관(이하 “지방청감독관”이라 한다)은 당해지방해양항만의 관할구역내에 주된 사무소를 둔 선박소유자 및 그 선원에 대하여 제2조의 규정에 의한 직무를 행한다. 다만, 해양수산부장관은 선박소유자 및 선원에 대한 감독관의 효율적인 직무집행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 그 관할을 변경할 수 있다.

③ 제2항 단서의 규정에 의하여 해양수산부장관이 감독관의 관할을 변경한 때에는 이를 관계지방해양항만청장에게 통보하여야 한다.

선원근로감독관직무규칙 제4조(확인·지도) 해양수산부장관은 본부감독관으로 하여금 지방청감독관의 근무상태와 직무수행상황을 확인·지도하게 할 수 있다.

선원근로감독관직무규칙 제5조(감독요령) ① 감독관은 법 제129조제1항에 따라 선원으로부터 선박소유자가 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 사실을 신고 받은 때에는 지체없이 그 사실을 확인·조사하여야 한다.

② 감독관이 제1항의 규정에 의하여 확인·조사를 행할 때에는 그 신고 받은 내용에 관하여 선박소유자 및 선원의 진술을 들어야 한다. 이 경우 선박소유자는 그가 지정하는 자로 하여금 진술하게 할 수 있다.

¹⁴²⁾ 특별사법경찰관리 직무규칙은 특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙이 제정되면서 2021. 1. 1. 폐지되었는데, 선원근로감독관 직무규칙은 이에 관한 사항이 반영되지 않고 있는 것으로 보인다.

③ 감독관이 법 제126조제1항에 따라 선박 기타 사업장에 출입검사할 때에는 선박소유자 또는 선원의 정상적인 업무 수행에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.

④ 감독관은 제1항 및 제3항의 규정에 의한 확인·조사 또는 출입검사 결과 선박소유자나 선원이 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 사실을 발견한 때에는 그에 관한 서류를 작성하여 당해 선박소유자 또는 선원으로부터 그 위반사실에 대한 확인을 받아야 한다. 다만, 그 선박소유자 또는 선원이 확인을 거부할 때에는 감독관은 당해서류에 확인거부 사실을 기재하여야 한다.

선원근로감독관직무규칙 제6조(출입검사 계획 등) ① 제5조에 따른 출입검사는 출입검사 계획에 따라 행하여야 한다.

② 본부감독관의 출입검사 계획은 해양수산부장관이 작성하고, 지방청감독관의 출입검사 계획은 지방해양항만청장이 작성하여 그 실시 15일전까지 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

③ 해양수산부장관은 필요하다고 인정할 때에는 제2항의 규정에 의한 지방청감독관의 출입검사 계획을 변경하게 하거나 본부감독관과 지방청감독관이 합동으로 출입검사를 하게 할 수 있다.

선원근로감독관직무규칙 제7조(출입검사 결과 등의 보고) ① 감독관이 제5조의 규정에 의하여 확인·조사 또는 출입검사를 행한 때에는 그 결과를 별지 제1호서식에 의하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

② 지방해양항만청장이 제1항의 규정에 의한 보고를 받은 때에는 내용을 종합하여 분기마다 그 분기종료후 10일내에 해양수산부장관에게 별지 제2호서식에 의하여 보고하여야 한다.

선원근로감독관직무규칙 제8조(피의자구속등의 보고) ① 감독관이 형사소송법 제201조제1항의 규정에 의하여 피의자를 구속한 때 또는 동법 제238조의 규정에 의하여 관계서류와 증거물을 검사에게 송부한 때에는 즉시 관계서류의 사본을 첨부하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

② 지방해양항만청장이 제1항의 규정에 의한 보고를 받은 때에는 지체없이 이를 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

선원근로감독관직무규칙 제9조(재해보고) ① 감독관은 다음 각호의 1에 해당하는 재해가 발생한 때에는 즉시 이를 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 해양사고등으로 인하여 선원이 사망 또는 실종된 때
 2. 해양사고등으로 인하여 3월이상의 치료를 요하는 부상을 입은 선원이 5명 이상 발생한 때
- ② 지방해양항만청장이 제1항의 규정에 의한 보고를 받은 때에는 지체없이 이를 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

선원근로감독관직무규칙 제11조(증표발급) ① 선원근로감독관규정 제6조제1항의 규정에 의한 감독관의 신분을 표시하는 증표(이하 “감독관증”이라 한다)는 별지 제4호서식에 의한다.

- ② 해양수산부장관 또는 지방해양항만청장이 제1항의 규정에 의한 감독관증을 발급하는 때에는 별지 제5호서식의 감독관증발급대장에 이를 등록하여야 한다.
- ③ 감독관이 그 직을 그만두게 된 때에는 해양수산부장관 또는 지방해양항만청장에게 감독관증을 반납하여야 한다.

다. 세관공무원에 관한 규정

사법경찰직무법 제5조 제17호는 관세법에 따라 관세법의 조사 업무에 종사하는 세관공무원을 특별사법경찰관리로 규정하고 있다. 관세법은 제12장에서 관세법에 따라 처벌되는 관세법에 관한 조사와 처분에 관하여 구체적인 규정을 두고 있는데, 관세법의 정의 및 조사·처분권(제283조), 공소의 요건으로서 고발(제284조), 관세법적조사심의위원회에 관한 규정(제284조의2), 관세법에 관한 서류 등에 관한 규정(제285조 내지 제289조), 관세법의 조사 의무(제290조), 피의자·증인 또는 참고인에 대한 조사(제291조), 조서의 작성 방법(제292조), 현행범인에 대한 조서의 대응(제293조), 출석요구(제294조), 특별사법경찰관리로서의 사법경찰권(제295조), 수색·압수와 현행범에 관한 규정(제296조 내지 제308조), 조사·검증·수색 시 경찰관의 원조(제309조), 통고처분 및 고발 등 조사 결과의 보고(제310조), 조사 종료시 처분에 관한 규정(제311조 내지 제318조, 형사소송법의 준용(제319) 등을 세관공무원의 직무에 관한 구체적인 규정을 법률에서 별도로 규정하고 있다.

관세법 제283조(관세범) ① 이 법에서 “관세범”이란 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하는 행위로서 이 법에 따라 형사처벌되거나 통고처분되는 것을 말한다.

② 관세범에 관한 조사·처분은 세관공무원이 한다.

관세법 제284조(공소의 요건) ① 관세범에 관한 사건에 대하여는 관세청장이나 세관장의 고발이 없으면 검사는 공소를 제기할 수 없다.

② 다른 기관이 관세범에 관한 사건을 발견하거나 피의자를 체포하였을 때에는 즉시 관세청이나 세관에 인계하여야 한다.

관세법 제284조의2(관세범칙조사심의위원회) ① 범칙사건에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 관세청 또는 대통령령으로 정하는 세관에 관세범칙조사심의위원회를 둘 수 있다.

1. 제290조 및 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제6조제14호에 해당하는 사건에 대한 조사의 시작 여부에 관한 사항
2. 제1호에 따라 조사한 사건의 고발, 송치, 통고처분(제311조제8항에 따른 통고처분의 면제를 포함한다) 및 종결 등에 관한 사항
3. 그 밖에 범칙사건과 관련하여 관세청장 또는 세관장이 관세범칙조사심의위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 관세범칙조사심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.

③ 제2항에서 규정한 사항 외에 관세범칙조사심의위원회의 관할, 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

관세법 제235조(관세범에 관한 서류) 관세범에 관한 서류에는 연월일을 적고 서명날인하여야 한다.

제286조(조사처분에 관한 서류) ① 관세범의 조사와 처분에 관한 서류에는 장마다 간인(間印)하여야 한다.

② 문자를 추가하거나 삭제할 때와 난의 바깥에 기입할 때에는 날인(捺印)하여야 한다.

③ 문자를 삭제할 때에는 그 문자 자체를 그대로 두고 그 글자수를 적어야 한다.

제287조(조서의 서명) ① 관세법에 관한 서류에 서명날인하는 경우 본인이 서명할 수 없을 때에는 다른 사람에게 대리서명하게 하고 도장을 찍어야 한다. 이 경우 도장을 지니지 아니하였을 때에는 손도장을 찍어야 한다.

② 다른 사람에게 대리서명하게 한 경우에는 대리서명자가 그 사유를 적고 서명날인하여야 한다.

제288조(서류의 송달) 관세법에 관한 서류는 인편이나 등기우편으로 송달한다.

관세법 제289조(서류송달 시의 수령증) 관세법에 관한 서류를 송달하였을 때에는 수령증을 받아야 한다.

관세법 제290조(관세법의 조사) 세관공무원은 관세법이 있다고 인정할 때에는 범인, 범죄사실 및 증거를 조사하여야 한다.

제291조(조사) 세관공무원은 관세법 조사에 필요하다고 인정할 때에는 피의자·증인 또는 참고인을 조사할 수 있다.

관세법 제292조(조서 작성) ① 세관공무원이 피의자·증인 또는 참고인을 조사하였을 때에는 조서를 작성하여야 한다.

② 조서는 세관공무원이 진술자에게 읽어 주거나 열람하게 하여 기재 사실에 서로 다른 점이 있는지 물어보아야 한다.

③ 진술자가 조서 내용의 증감 변경을 청구한 경우에는 그 진술을 조서에 적어야 한다.

④ 조서에는 연월일과 장소를 적고 다음 각 호의 사람이 함께 서명날인하여야 한다.

1. 조사를 한 사람
2. 진술자
3. 참여자

제293조(조서의 대응) ① 현행범인에 대한 조사로서 긴급히 처리할 필요가 있을 때에는 그 주요 내용을 적은 서면으로 조서를 대신할 수 있다.

② 제1항에 따른 서면에는 연월일시와 장소를 적고 조사를 한 사람과 피의자가 이에 서명날인하여야 한다.

관세법 제294조(출석 요구) ① 세관공무원이 관세법 조사에 필요하다고 인정할 때에는 피의자·증인 또는 참고인의 출석을 요구할 수 있다.

② 세관공무원이 관세법 조사에 필요하다고 인정할 때에는 지정한 장소에 피의자·증인 또는 참고인의 출석이나 동행을 명할 수 있다.

③ 피의자·증인 또는 참고인에게 출석 요구를 할 때에는 출석요구서를 발급하여야 한다.

관세법 제295조(사법경찰권) 세관공무원은 관세법에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 사법경찰관리의 직무를 수행한다.

관세법 제296조(수색·압수영장) ① 이 법에 따라 수색·압수를 할 때에는 관할 지방법원 판사의 영장을 받아야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 사후에 영장을 발급받아야 한다.

② 소유자·점유자 또는 보관자가 임의로 제출한 물품이나 남겨 둔 물품은 영장 없이 압수할 수 있다.

제297조(현행범의 체포) 세관공무원이 관세법의 현행범인을 발견하였을 때에는 즉시 체포하여야 한다.

제298조(현행범의 인도) ① 관세법의 현행범인이 그 장소에 있을 때에는 누구든지 체포할 수 있다.

② 제1항에 따라 범인을 체포한 자는 지체 없이 세관공무원에게 범인을 인도하여야 한다.

제299조(압수물품의 국고귀속) ① 세관장은 제269조, 제270조제1항부터 제3항까지 및 제272조부터 제274조까지의 규정에 해당되어 압수된 물품에 대하여 그 압수일부터 6개월 이내에 해당 물품의 소유자 및 범인을 알 수 없는 경우에는 해당 물품을 유실물로 간주하여 유실물 공고를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 공고일부터 1년이 지나도 소유자 및 범인을 알 수 없는 경우에는 해당 물품은 국고에 귀속된다.

제300조(검증수색) 세관공무원은 관세법 조사에 필요하다고 인정할 때에는 선박·차량·항공기·창고 또는 그 밖의 장소를 검증하거나 수색할 수 있다.

제301조(신변 수색 등) ① 세관공무원은 범죄사실을 증명하기에 충분한 물품

을 피의자가 신변(身邊)에 은닉하였다고 인정될 때에는 이를 내보이도록 요구하고, 이에 따르지 아니하는 경우에는 신변을 수색할 수 있다.

② 여성의 신변을 수색할 때에는 성년의 여성을 참여시켜야 한다.

제302조(참여) ① 세관공무원이 수색을 할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 참여시켜야 한다. 다만, 이들이 모두 부재중일 때에는 공무원 을 참여시켜야 한다.

1. 선박·차량·항공기·창고 또는 그 밖의 장소의 소지인·관리인
2. 동거하는 친척이나 고용된 사람
3. 이웃에 거주하는 사람

② 제1항제2호 및 제3호에 따른 사람은 성년자이어야 한다.

제303조(압수와 보관) ① 세관공무원은 관세범 조사에 의하여 발견한 물품이 범죄의 사실을 증명하기에 충분하거나 몰수하여야 하는 것으로 인정될 때에는 이를 압수할 수 있다.

② 압수물품은 편의에 따라 소지자나 시·군·읍·면사무소에 보관시킬 수 있다.

③ 관세청장이나 세관장은 압수물품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 피의자나 관계인에게 통고한 후 매각하여 그 대금을 보관하거나 공탁할 수 있다. 다만, 통고할 여유가 없을 때에는 매각한 후 통고하여야 한다.

1. 부패 또는 손상되거나 그 밖에 사용할 수 있는 기간이 지날 우려가 있는 경우
2. 보관하기가 극히 불편하다고 인정되는 경우
3. 처분이 지연되면 상품가치가 크게 떨어질 우려가 있는 경우
4. 피의자나 관계인이 매각을 요청하는 경우

④ 제3항에 따른 통고 및 매각에 관하여는 제160조제5항 및 제326조를 준용한다.

제304조(압수물품의 폐기) ① 관세청장이나 세관장은 압수물품 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 피의자나 관계인에게 통고한 후 폐기할 수 있다. 다만, 통고할 여유가 없을 때에는 폐기한 후 즉시 통고하여야 한다.

1. 사람의 생명이나 재산을 해칠 우려가 있는 것
2. 부패하거나 변질된 것
3. 유효기간이 지난 것
4. 상품가치가 없어진 것

② 제1항에 따른 통고에 관하여는 제160조제5항을 준용한다.

제305조(압수조서 등의 작성) ① 검증·수색 또는 압수를 하였을 때에는 조서를 작성하여야 한다.

② 제1항에 따른 검증·수색 또는 압수조서에 관하여는 제292조제2항 및 제3항을 준용한다.

③ 현행범인에 대한 수색이나 압수로서 긴급한 경우의 조서작성에 관하여는 제293조를 준용한다.

제306조(야간집행의 제한) ① 해 진 후부터 해 뜨기 전까지는 검증·수색 또는 압수를 할 수 없다. 다만, 현행범인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 이미 시작한 검증·수색 또는 압수는 제1항에도 불구하고 계속할 수 있다.

제307조(조사 중 출입금지) 세관공무원은 피의자·증인 또는 참고인에 대한 조사·검증·수색 또는 압수 중에는 누구를 막론하고 그 장소에의 출입을 금할 수 있다.

제308조(신분 증명) ① 세관공무원은 조사·검증·수색 또는 압수를 할 때에는 제복을 착용하거나 그 신분을 증명할 증표를 지니고 그 처분을 받을 자가 요구하면 이를 보여 주어야 한다.

② 제1항에 따른 세관공무원이 제복을 착용하지 아니한 경우로서 그 신분을 증명하는 증표제시 요구를 따르지 아니하는 경우에는 처분을 받을 자는 그 처분을 거부할 수 있다.

제309조(경찰관의 원조) 세관공무원은 조사·검증·수색 또는 압수를 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 경찰공무원의 원조를 요구할 수 있다.

관세법 제310조(조사 결과의 보고) ① 세관공무원은 조사를 종료하였을 때에는 관세청장이나 세관장에게 서면으로 그 결과를 보고하여야 한다.

② 세관공무원은 제1항에 따른 보고를 할 때에는 관계 서류를 함께 제출하여야 한다.

관세법 제311조(통고처분) ① 관세청장이나 세관장은 관세법을 조사한 결과 범죄의 확증을 얻었을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 대상이 되는 자에게 그 이유를 구체적으로 밝히고 다음 각 호에 해당하는 금액이나 물품을 납부할 것을 통고할 수 있다.

1. 벌금에 상당하는 금액

2. 몰수에 해당하는 물품

3. 추징금에 해당하는 금액

② 관세청장이나 세관장은 제1항에 따른 통고처분을 받는 자가 벌금이나 추징금에 상당한 금액을 예납(豫納)하려는 경우에는 이를 예납시킬 수 있다.

③ 제1항에 따른 통고가 있는 때에는 공소의 시효는 정지된다.

④ 제1항에 따른 벌금에 상당하는 금액의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

⑤ 제1항에 따라 통고처분을 받은 자는 납부하여야 할 금액을 대통령령으로 정하는 통고처분납부대행기관을 통하여 신용카드, 직불카드 등(이하 이 조에서 “신용카드등”이라 한다)으로 납부할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 신용카드등으로 납부하는 경우에는 통고처분납부대행기관의 승인일을 납부일로 본다.

⑦ 제5항 및 제6항에서 정한 사항 외에 통고처분납부대행기관의 지정 및 운영, 납부대행 수수료 등 통고처분에 따른 금액을 신용카드등으로 납부하는 경우에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

⑧ 관세청장이나 세관장은 통고처분 대상자의 연령과 환경, 법 위반의 동기와 결과, 범칙금 부담능력과 그 밖에 정상을 고려하여 제284조의2에 따른 관세범칙조사심의위원회의 심의·의결을 거쳐 제1항에 따른 통고처분을 면제할 수 있다. 이 경우 관세청장이나 세관장은 관세범칙조사심의위원회의 심의·의결 결과를 따라야 한다.

⑨ 제8항에 따른 통고처분 면제는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 관세범을 대상으로 한다.

1. 제1항제1호의 금액이 30만원 이하일 것

2. 제1항제2호의 물품의 가액과 같은 항 제3호의 금액을 합한 금액이 100만원 이하일 것

제312조(즉시 고발) 관세청장이나 세관장은 범죄의 정상이 징역형에 처해질 것으로 인정될 때에는 제311조제1항에도 불구하고 즉시 고발하여야 한다.

제313조(압수물품의 반환) ① 관세청장이나 세관장은 압수물품을 몰수하지 아니할 때에는 그 압수물품이나 그 물품의 환가대금(換價代金)을 반환하여야 한다.

② 제1항의 물품이나 그 환가대금을 반환받을 자의 주소 및 거소가 분명하지 아니하거나 그 밖의 사유로 반환할 수 없을 때에는 그 요지를 공고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 공고를 한 날부터 6개월이 지날 때까지 반환의 청구가 없는

경우에는 그 물품이나 그 환가대금을 국고에 귀속시킬 수 있다.

④ 제1항의 물품에 대하여 관세가 미납된 경우에는 반환받을 자로부터 해당 관세를 징수한 후 그 물품이나 그 환가대금을 반환하여야 한다.

제314조(통고서의 작성) ① 통고처분을 할 때에는 통고서를 작성하여야 한다.

② 제1항에 따른 통고서에는 다음 각 호의 사항을 적고 처분을 한 자가 서명날인하여야 한다.

1. 처분을 받을 자의 성명, 나이, 성별, 직업 및 주소
2. 벌금에 상당한 금액, 몰수에 해당하는 물품 또는 추징금에 상당한 금액
3. 범죄사실
4. 적용 법조문
5. 이행 장소
6. 통고처분 연월일

제315조(통고서의 송달) 통고처분의 고지는 통고서를 송달하는 방법으로 하여야 한다.

제316조(통고의 불이행과 고발) 관세범인이 통고서의 송달을 받았을 때에는 그 날부터 15일 이내에 이를 이행하여야 하며, 이 기간 내에 이행하지 아니하였을 때에는 관세청장이나 세관장은 즉시 고발하여야 한다. 다만, 15일이 지난 후 고발이 되기 전에 관세범인이 통고처분을 이행한 경우에는 그러하지 아니하다.

제317조(일사부재리) 관세범인이 통고의 요지를 이행하였을 때에는 동일사건에 대하여 다시 처벌을 받지 아니한다.

제318조(무자력 고발) 관세청장이나 세관장은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 제311조제1항에도 불구하고 즉시 고발하여야 한다.

1. 관세범인이 통고를 이행할 수 있는 자금능력이 없다고 인정되는 경우
2. 관세범인의 주소 및 거소가 분명하지 아니하거나 그 밖의 사유로 통고를 하기 곤란하다고 인정되는 경우

관세법 제319조(준용) 관세법에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「형사소송법」을 준용한다.

또한 관세청 훈령인 세관공무원의 범칙조사에 관한 훈령을 통해 조사의 기준과 절차를 구체적으로 규정하고 있는데, 기본 원칙에 관한 규정(제3조 내지 제7조),

관할(제8조), 사건의 이첩(제9조), 언론보도를 위한 절차(제10조), 사건의 처리기한(제11조), 범칙조사의 전산처리 원칙(제12조), 범칙사건의 처리에 관한 규정(제13조 내지 제18조), 내사 및 수사에 관한 규정(제19조 내지 제58조), 지명수배·통보와 출국제한에 관한 규정(제59조 내지 제69조), 범칙조사위원회에 관한 규정(제70조 내지 제72조), 보고와 서식 등에 관한 규정(제73조 내지 제77조) 등 세관공무원의 업무를 위한 구체적인 규정을 두고 있다.

라. 세무공무원에 관한 규정

형사소송법 제245조의10 제1항은 세무에 관한 사항을 특별사법경찰관의 직무 범위로 열거하고 있으나, 사법경찰관직무법은 세무공무원을 특별사법경찰관으로 규정하고 있지는 않다. 그런데 조세범 처벌법 제21조는 “이 법에 따른 범칙행위에 대해서는 국세청장, 지방국세청장 또는 세무서장의 고발이 없으면 검사는 공소를 제기할 수 없다.”고 규정하고 있고, 조세범 처벌절차법은 조세범칙사건의 조사 후 통고처분을 할 수 있도록 규정하고 있는데, 이 점에서 세무공무원은 특별사법경찰관인 세관공무원과 유사하다.

따라서 세무공무원의 조사는 사실상 수사에 준하는 성격을 가지는 것으로 볼 수 있을 것이다. 특별사법경찰관리 지명절차 등에 관한 지침 제10조는 위 지침의 규정을 세무공무원에 대하여 준용하도록 규정하고 있는데, 이는 세무공무원의 조사가 특별사법경찰관리의 업무와 유사하다는 점을 보여주는 것이라 생각된다.

특별사법경찰관리 지명절차 등에 관한 지침 제10조(세무공무원 등에의 준용) ① 제2조, 제3조, 제5조, 제5조의2, 제6조, 제7조, 제8조, 제8조의2 의 규정은 「조세범처벌절차법 시행령」 제7조 의 규정에 의한 세무공무원 또는 「지방세기본법 시행령」 제102조 의 2의 규정에 의한 범칙사건조사공무원의 지명에 준용한다. 다만, 세무공무원의 지명에 있어서 "특별사법경찰관리"는 "세무공무원"으로, "지방검찰청 검사장 또는 지청장"은 "검찰총장 또는 지방검찰청 검사장"으로, "지방검찰청"은 "대검찰청 또는 지방검찰청"으로, "당해 지방검찰청 소속 부장검사"는 "대검찰청 과장 또는 당해 지방검찰청 소속 부장검사"로, "소속 관서장"은 "국세청장 또는 지방국세청장"으로 한다. ② 제2조, 제3조, 제5조, 제5조의2, 제6조, 제7조, 제8조, 제8조의2 의 규정은 「

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제378조 의 규정에 의한 조사공무원의 지명에 준용한다. 이 경우 "특별사법경찰관리"는 "조사공무원"으로, "지방검찰청 검사장 또는 지청장"은 "검찰총장"으로, "지방검찰청"은 "대검찰청"으로, "당해 지방검찰청 소속 부장검사"는 "대검찰청 과장"으로, "소속 관서장"은 "증권선물위원회 위원장"으로 한다.

조세범 처벌절차법은 조세범칙사건의 관할(제3조), 조세범칙사건의 국세청장 등으로의 인계(제4조), 조세범칙조사심의위원회에 관한 규정(제5조), 조세범칙조사를 위한 다른 국가기관에 대한 협조 요청(제6조), 조세범칙조사 대상의 선정 기준(제7조), 조세범칙행위 혐의자 등에 대한 심문, 압수·수색에 관한 규정(제8조 내지 제11조), 조세범칙조사 종료에 따른 보고(제12조), 조세범칙처분의 종류(제13조), 조세범칙처분에 대한 위원회 심의에 관한 규정(제14조), 통고처분에 관한 규정(제15조), 통고처분에 따른 공소시효의 정지(제16조), 고발의 요건(제17조), 고발에 따른 압수물건의 인계(제18조), 무혐의 통지 및 압수의 해제에 관한 규정(제19조)를 규정하고 있다.

조세범 처벌절차법 제3조(조세범칙사건의 관할) ① 조세범칙사건은 해당 조세범칙사건의 납세지를 관할하는 세무서장의 관할로 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 중요한 사건의 경우에는 지방국세청장의 관할로 할 수 있다.
② 제1항에서 규정한 사항 외에 조세범칙사건의 관할에 필요한 사항은 국세청장이 정한다.

조세범 처벌절차법 제4조(조세범칙사건의 인계) 지방국세청 또는 세무서 외의 행정기관과 그 소속 공무원이 입수한 조세범칙사건에 관한 증거 등은 국세청장이나 관할 지방국세청장 또는 세무서장에게 지체 없이 인계하여야 한다.

조세범 처벌절차법 제5조(조세범칙조사심의위원회) ① 조세범칙사건에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 지방국세청에 조세범칙조사심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
1. 「조세범 처벌법」 제3조에 해당하는 조세범칙사건에 대한 조세범칙조사의 실시

1의2. 제13조에 따른 조세범칙처분 없이 조세범칙조사를 종결하려는 경우 그 종결에 관한 사항 2. 제14조제1항에 따른 조세범칙처분의 결정 3. 조세범칙조사의 기간 연장 및 조사범위 확대 4. 「조세범 처벌법」 제18조에 따른 양벌규정의 적용 5. 그 밖에 조세범칙조사와 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 ② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다. ③ 제2항에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람은 「형법」이나 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.
--

조세범 처벌절차법 제6조(국가기관에 대한 협조 요청) ① 국세청장·지방국세청장 또는 세무서장은 조세범칙조사를 실시하기 위하여 필요한 경우에는 다른 국가기관에 협조를 요청할 수 있다. ② 제1항에 따라 협조 요청을 받은 국가기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

조세범 처벌절차법 제7조(조세범칙조사 대상의 선정) ① 지방국세청장 또는 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조세범칙조사를 실시하여야 한다. 1. 조세범칙행위의 혐의가 있는 자(이하 “조세범칙행위 혐의자”라 한다)를 처벌하기 위하여 증거수집 등이 필요한 경우 2. 연간 조세포탈 혐의금액 등이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우 ② 지방국세청장 또는 세무서장은 「조세범 처벌법」 제3조에 해당하는 조세범칙사건에 대하여 조세범칙조사를 실시하려는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지방국세청장은 국세청장의 승인을, 세무서장은 관할 지방국세청장의 승인을 받아 위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.
--

조세범 처벌절차법 제8조(조세범칙행위 혐의자 등에 대한 심문·압수·수색) 세무공무원은 조세범칙조사를 하기 위하여 필요한 경우에는 조세범칙행위 혐의자 또는 참고인을 심문하거나 압수 또는 수색할 수 있다. 이 경우 압수 또는 수색을 할 때에는 대통령령으로 정하는 사람을 참여하게 하여야 한다.

제9조(압수·수색영장) ① 세무공무원이 제8조에 따라 압수 또는 수색을 할 때에는 근무지 관할 검사에게 신청하여 검사의 청구를 받은 관할 지방법원판사가 발부한 압수·수색영장이 있어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 조세범칙행위 혐의자 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에게 그 사유를 알리고 영장 없이 압수 또는 수색할 수 있다.

1. 조세범칙행위가 진행 중인 경우
 2. 장기 3년 이상의 형에 해당하는 조세범칙행위 혐의자가 도주하거나 증거를 인멸할 우려가 있어 압수·수색영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우
- ② 제1항 단서에 따라 영장 없이 압수 또는 수색한 경우에는 압수 또는 수색한 때부터 48시간 이내에 관할 지방법원판사에게 압수·수색영장을 청구하여야 한다.
- ③ 세무공무원은 압수·수색영장을 발부받지 못한 경우에는 즉시 압수한 물건을 압수당한 자에게 반환하여야 한다.
- ④ 세무공무원은 압수한 물건의 운반 또는 보관이 곤란한 경우에는 압수한 물건을 소유자, 소지자 또는 관공서(이하 “소유자등”이라 한다)로 하여금 보관하게 할 수 있다. 이 경우 소유자등으로부터 보관증을 받고 봉인(封印)이나 그 밖의 방법으로 압수한 물건임을 명백히 하여야 한다.

제10조(「형사소송법」의 준용) 이 법에서 규정한 사항 외에 압수 또는 수색과 압수·수색영장에 관하여는 「형사소송법」 중 압수 또는 수색과 압수·수색영장에 관한 규정을 준용한다.

제11조(심문조서 등의 작성) 세무공무원은 심문하거나 압수 또는 수색을 하였을 때에는 조서에 그 경위(經緯)를 기록하여 심문을 받은 사람 또는 제8조 후단에 따른 참여자에게 확인하게 한 후 그와 함께 서명날인을 하여야 한다. 이 경우 서명날인을 하지 아니하거나 할 수 없을 때에는 그 사유를 조서에 기록하여야 한다.

조세법 처벌절차법 제12조(보고) 세무공무원은 조세범칙조사를 마쳤을 때에는 국세청장·지방국세청장 또는 세무서장에게 보고하여야 한다.

조세법 처벌절차법 제13조(조세범칙처분의 종류) 조세범칙사건에 대한 처분의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 통고처분
2. 고발
3. 무혐의

조세법 처벌절차법 제14조(조세범칙처분에 대한 위원회 심의) ① 지방국세청장 또는 세무서장은 제7조제2항에 따라 위원회의 심의를 거치거나 국세청장 또는 관할 지방국세청장의 승인을 받아 조세범칙조사를 실시한 조세범칙사건에 대하여 조세범칙처분을 하려는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 제9조제1항제2호의 사유가 있는 경우에는 지방국세청장은 국세청장의 승인을, 세무서장은 관할 지방국세청장의 승인을 받아 위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다. ② 지방국세청장 또는 세무서장은 제1항에 따라 위원회에 심의를 요청한 때에는 즉시 그 사실을 제13조 각 호에 따른 처분의 대상 자에게 통지하여야 한다. ③ 제2항에 따른 통지를 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회에 의견을 제출할 수 있다.

조세법 처벌절차법 제15조(통고처분) ① 지방국세청장 또는 세무서장은 조세범칙행위의 확증을 얻었을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 대상이 되는 자에게 그 이유를 구체적으로 밝히고 다음 각 호에 해당하는 금액이나 물품을 납부할 것을 통고하여야 한다. 다만, 몰수 또는 몰취(沒取)에 해당하는 물품에 대해서는 그 물품을 납부하겠다는 의사표시(이하 “납부신청”이라 한다)를 하도록 통고할 수 있다.

1. 벌금에 해당하는 금액(이하 “벌금상당액”이라 한다)
2. 몰수 또는 몰취에 해당하는 물품
3. 추징금에 해당하는 금액

② 제1항 단서에 따른 통고를 받은 자가 그 통고에 따라 납부신청을 하고 몰수 또는 몰취에 해당하는 물품을 가지고 있는 경우에는 공매나 그 밖에 필요한 처분을 할 때까지 그 물품을 보관하여야 한다.

- ③ 제1항에 따른 통고처분을 받은 자가 통고대로 이행하였을 때에는 동일한 사건에 대하여 다시 조세범칙조사를 받거나 처벌받지 아니한다.
- ④ 제1항에 따른 벌금상당액의 부과기준은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 제1항에 따른 벌금상당액은 「국세징수법」 제12조제1항 각 호의 방법으로 납부한다.

조세범 처벌절차법 제16조(공소시효의 정지) 제15조제1항에 따른 통고처분이 있는 경우에는 통고일부터 고발일까지의 기간 동안 공소시효는 정지된다.

조세범 처벌절차법 제17조(고발) ① 지방국세청장 또는 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통고처분을 거치지 아니하고 그 대상자를 즉시 고발하여야 한다.

1. 정상(情狀)에 따라 징역형에 처할 것으로 판단되는 경우
2. 제15조제1항에 따른 통고대로 이행할 자금이나 납부 능력이 없다고 인정되는 경우
3. 거소가 분명하지 아니하거나 서류의 수령을 거부하여 통고처분을 할 수 없는 경우
4. 도주하거나 증거를 인멸할 우려가 있는 경우

② 지방국세청장 또는 세무서장은 제15조제1항에 따라 통고처분을 받은 자가 통고서를 송달받은 날부터 15일 이내에 통고대로 이행하지 아니한 경우에는 고발하여야 한다. 다만, 15일이 지났더라도 고발되기 전에 통고대로 이행하였을 때에는 그러하지 아니 하다.

조세범 처벌절차법 제18조(압수물건의 인계) ① 지방국세청장 또는 세무서장은 제17조에 따라 고발한 경우 압수물건이 있을 때에는 압수목록을 첨부하여 검사에게 인계하여야 한다.

② 지방국세청장 또는 세무서장은 제1항의 압수물건으로서 제9조제4항에 따라 소유자등이 보관하는 것에 대해서는 검사에게 보관증을 인계하고, 소유자등에게 압수물건을 검사에게 인계하였다는 사실을 통지하여야 한다.

제19조(무혐의 통지 및 압수의 해제) 지방국세청장 또는 세무서장은 조세범칙조사를 하여 조세범칙행위의 확증을 갖지 못하였을 때에는 그 뜻을 조세범칙행위 혐의자에게 통지하고 물건을 압수하였을 때에는 그 해제를 명하여야 한다.

9. 검토 및 시사점

가. 사법경찰집무법

특별사법경찰관리에 관하여 형사소송법과 사법경찰직무법은 특별사법경찰관의 지명과 직무에 관한 구체적인 내용을 규정하고 있지 않으며, 구체적인 내용은 법무예규와 법무부령으로 규정하고 있을 뿐이다. 이 점에서 근로감독관의 직무에 관한 대부분의 사항에 관하여 법률에 직접적인 근거를 두지 않은 채 고용노동부 훈령인 근로감독관집무규정을 통해 규율하고 있는 것과 유사하다.

그런데 특별사법경찰관리 지명절차 등에 관한 지침과 특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙은 명시적인 법률의 근거 없이 제정된 것이다. 상위법령의 위임 없이 규정된 부령 등은 일반 국민에 대하여 구속력을 가지는 법규명령으로서의 효력은 없으며,¹⁴³⁾ 이는 행정청 내부의 사무처리 기준 등을 정한 것으로서 행정조직 내에서 적용되는 행정명령의 성격을 지닐 뿐이고, 어떤 행정처분이 법규성이 없는 시행규칙 등의 규정에 위배된다고 하더라도 그 이유만으로 처분이 위법하게 되는 것은 아니며, 그 규칙 등에서 정한 요건에 부합한다고 하여 반드시 그 처분이 적법한 것이라고 할 수도 없다.¹⁴⁴⁾

이러한 규정 형식에 대하여 특별사법경찰관리직무집행법을 제정하여 특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙의 내용을 반영하거나 개별 법률의 제정이 곤란한 경우에는 형사소송법 제245조의10에 규정할 필요가 있고, 특히 수갑 등 경찰장구 사용의 법률적 근거를 규정할 필요가 있다는 지적이 있다.¹⁴⁵⁾ 예규 등의 변경을 통해 특별사법경찰관에 관한 중요한 내용이 쉽게 변경될 수 있으므로, 특별사법경찰관의 임명, 교육, 기관 간 협조, 직무 집행에 필요한 사항 등 중요한 사항은 법률로 규정할 필요가 있다는 지적도 제기된다.¹⁴⁶⁾ 경찰장구 사용의 법률적 근거가 필요하다는 점은 근로감독관의 직무 집행에 있어서도 마찬가지이므로, 근로감독관집무규정 제53조의 규정은 법률에서 직접 규정하거나, 적어도 법률에 경찰장구 사용의 근거를 둘 필요가 있다.

143) 대법원 2015. 6. 25. 선고 2007두4995 전원합의체 판결.

144) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2011두10584 판결.

145) 박준희 외, 「특별사법경찰에 관한 연구(I)」, 한국형사·법무정책연구원, 2022. 12, 624면.

146) 정병하·임정호, 「특별사법경찰 조직의 전문화 방안에 관한 연구」, 한국형사정책연구원, 2009. 9, 217-218면.

특별사법경찰관의 직무에 관한 사항을 법률에서 규정할 필요가 있다는 점은 근로감독관에 있어서도 마찬가지이다. 형사소송법과 사법경찰관직무법의 규정만으로 근로감독관에 관한 사항을 모두 규율하는 것은 불가능하다. 이에 따라 근로감독관 직무규정을 제정하고 있으나 이에 관한 법률의 근거는 두고 있지 않다. 근로기준법이 근로감독관에 관한 별도의 규정을 두고 있다는 점을 고려하면, 근로감독관의 직무에 관해서는 일반적인 특별사법경찰관리의 직무에 관한 법률 규정 외에 근로감독관에 관한 규정을 법률에 근거하여 둘 필요가 있다.

나. 선원법

선원법은 선원근로감독관에 관하여 근로기준법의 근로감독관에 관한 규정과 유사하게 규정하고 있으나, 근로감독관에 관한 위임규정에서 차이가 있다. 근로기준법 제101조 제2항은 “근로감독관의 자격, 임면, 직무 배치에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.”고 하여 위임 대상을 열거하고 있는데, 선원법 제125조 제2항은 “선원근로감독관의 자격·임면 및 직무 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”고 하여 위임의 대상에 선원근로감독관의 직무를 포함하고 위임의 대상도 예시적인 형태로 규정하고 있다.

위와 같은 위임규정의 차이에 따라 근로감독관규정과 선원근로감독관규정은 근로감독관규정이 규정하고 있는 근로감독관의 임명에 관한 사항 외에 선원근로감독관의 직무와 감독, 직무교육에 관한 사항까지 규정하고 있다. 선원근로감독관규정은 선원법이 위임하고 있는 사항을 규정하면서, 구체적인 사항을 선원근로감독관 직무규칙에 위임을 하고 있으므로 선원근로감독관의 직무와 교육에 관한 사항은 법률에 근거를 두고 있다. 이 점에서 법률에 직접적인 근거를 두고 있지 않은 고용노동부훈령인 근로감독관직무규정을 통해 근로감독관의 직무 집행에 필요한 사항을 규정하고 있는 근로감독관의 경우와는 차이가 있다.

근로감독관의 직무에 관한 개별 법률 제정이 어렵다면, 선원법과 같이 적어도 근로감독관의 직무에 관한 사항에 대해서도 법률에 위임의 근거를 두는 방식을 고려할 수 있다. 다만 선원법의 위임 규정은 ‘자격·임면 및 직무 등에 필요한 사항’이라고만 규정한 채 구체적인 내용을 모두 선원근로감독관규정에 위임하고 있고, 선원근로감독관규정 제4조는 “감독관의 직무, 감독요령등에 관하여 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.”고 하여 역시 구체적인 내용을 규정하지 않은 채 선원

근로감독관직무규칙에 위임하고 있다. 이와 같은 규정 형식은 포괄위임금지원칙 위반의 소지가 있다. 적어도 근로감독관의 직무와 교육 등에 관한 기본적인 사항은 법률에서 직접 규율하고 구체적인 내용을 하위 규정으로 위임할 필요가 있다.

다. 관세법

관세법은 관세범칙사건의 조사와 처분에 관한 사항을 규정하고 있는데, 특히 조서의 작성이나 압수·수색 등을 구체적으로 규정하고 있다. 조서의 작성은 적법절차와 관련이 있으며, 출석요구나 압수·수색 등은 당사자의 기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 법률에 명확한 근거 규정을 두는 것이 바람직하다.

관세법은 조사 종료시 처분의 기준과 절차 등에 관해서도 규정을 두고 있다. 조사에 따른 처분은 국민의 기본권에 영향을 미치는 처분이고, 이에 관한 규정이 국민에 대하여 구속력을 가지기 위해서는 법률에서 직접 규정하거나, 법률에 근거를 둔 법규명령의 형식으로 규정할 필요가 있다는 점에서, 근로감독관의 신고사건 처리 기준 및 절차 역시 관세법과 같이 법률에 근거를 둘 필요가 있다.

관세법 제309조는 “세관공무원은 조사·검증·수색 또는 압수를 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 경찰공무원의 원조를 요구할 수 있다.”고 하여 경찰관의 원조에 대한 근거를 규정하고 있다. 이는 세관공무원의 업무 특성상 압수·수색 등의 필요성이 크다는 점과, 이에 대하여 특별한 규율이 필요하다는 점 때문으로 보인다. 근로감독관의 경우에도 필요한 경우 강제수사에 관한 특별한 규정을 두거나, 경찰관이나 다른 국가기관의 협조가 필요한 경우 협조를 요구할 수 있도록 법률에 근거를 두는 것을 고려할 필요가 있다.

라. 조세법 처벌절차법

조세법 처벌절차법은 조세범칙사건의 조사와 처분에 관한 구체적인 사항을 규정하고 있는데, 세무공무원의 직무를 개별법률을 통해 규율하고 있다는 점이 특징적이다. 이와 같이 개별법을 새롭게 제정하는 것은 근로감독관에 관한 법적 규율을 함에 있어서도 적극적으로 고려할 필요가 있다. 특히 근로기준법 제정 이후 노동에 관한 여러 법률이 제정되어 왔는데 사법경찰직무법 제6조의2 제1항은 근로감독관의 직무범위로 근로기준법 외에도 총 19개 법률에 규정된 범죄를 규정하고 있다는 점에서 근로기준법에서 근로감독관의 직무에 관한 규정을 두는 것은 문제가 될

수 있다는 점을 고려면, 근로감독관의 직무를 규율하는 개별 법률을 제정하는 것이 보다 적절한 방안이라 할 수 있다.¹⁴⁷⁾

조세범 처벌절차법 제6조 제1항은 “국세청장·지방국세청장 또는 세무서장은 조세범칙조사를 실시하기 위하여 필요한 경우에는 다른 국가기관에 협조를 요청할 수 있다.”고 하면서, 제2항에서 “제1항에 따라 협조 요청을 받은 국가기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.”고 규정하여 국가기관에 대한 협조 요청 및 협조 의무를 규정하고 있다. 조세범 처벌절차법의 협조의무는 관세법 제309조에 따른 경찰관의 원조 규정과 비교했을 때, 협조 요청의 사유를 포괄적으로 규정하면서 협조 요청에 따를 의무를 함께 규정하여 협조 요청의 실효성을 도모하고 있다. 이 점에서 법률에 근로감독관의 업무에 관한 협조의 근거를 둔다면 조세범 처벌절차법과 같은 형태의 규정이 더 바람직해 보인다.

조세범 처벌절차법이 심문, 조서의 작성이나 압수·수색에 관한 규정을 두고 있는 것은 관세법과 유사한데, 이에 대하여 제7조는 조세범칙조사 대상의 선정 기준과 절차에 대해서도 규정하고 있다. 조사의 개시는 그 자체로 국민의 기본권에 영향을 미칠 수 있는 행위라는 점에서 그 기준과 절차에 관한 법률의 근거가 있어야 할 것이다. 이러한 점을 고려하면 근로감독관집무규정 제44조가 규정하는 범죄의 내사 및 범죄인지 기준의 내용은 법률에서 직접 규정할 필요가 있다.

조세범 처벌절차법 제16조는 “통고처분이 있는 경우에는 통고일부터 고발일까지의 기간 동안 공소시효는 정지된다.”고 규정하고 있는데, 통고처분이 없는 근로감독관의 업무에서는 그와 같은 규정을 둘 필요는 없을 것이다.

10. 소결

특별사법경찰관리에 관한 일반규정이라고 할 수 있는 사법경찰직무법은 특별사법경찰관리의 업무에 관하여 구체적인 규정을 두고 있지 않은데, 이에 대한 문제 제기는 근로감독관에 관한 규정에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 근로기준법은 선원근로감독관의 직무 등에 관하여 포괄적이거나 위임의 근거를 두고 있는 선원법과 비교하더라도 법치주의의 측면에서 문제가 있다. 따라서 근로감독관의 직무에

¹⁴⁷⁾ 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 『노동법연구』 제54호, 서울대노동법연구회, 2023. 145-146면.

관해서도 법률 차원의 규율이 필요하다.

관세법은 세관공무원의 직무에 관하여 구체적인 규정을 두고 있으며, 조세법 처벌절차법은 개별 법률을 통해 세무공무원의 직무를 규정하고 있다. 근로감독관에 관해서도 근로기준법 개정을 통해 근로감독관의 직무에 관한 규정을 두는 방안과 근로감독에 관한 개별 법률을 새롭게 제정하는 방안이 가능하다. 그런데 근로감독관에 관한 법률 체계와 근로감독관 직무의 중요성 등을 고려하면 근로감독관에 관한 개별 법률을 제정하는 방안이 좀 더 타당한 것으로 보인다.

근로감독관 외의 특별사법경찰관리에 관한 법률의 내용들을 참고하였을 때, 근로감독관집무규정의 내용 중 근로감독관의 교육, 신고사건의 처리 기준 및 절차, 범죄의 내사 및 범죄인지 기준, 수사공조, 구속 및 출국금지, 지명수배 등에 관한 규정, 경찰장구의 사용, 사건의 송치에 관한 규정 등은 법률에서 직접 규정하거나, 법률에 근거를 둔 법규명령 형식으로 규정할 필요가 있다.

근로감독관은 조사 결과에 따라 시정지시를 하고, 기한 내에 시정조치가 이루어지지 않은 경우 수사에 착수하게 된다. 법원은 시정지시를 비권력적 사실행위인 행정지도에 불과하다고 보아 시정지시에 대한 항고소송이 제기되는 경우 각하판결을 하고 있다.¹⁴⁸⁾ 그러나 시정지시를 받은 사업주의 입장에서는 시정지시가 사실상 강제력을 가지는 것으로 인식하고 시정지시에 대한 행정소송을 제기하는 경우가 많다. 이와 같은 현실을 고려하면 근로감독관의 내사 단계에서의 업무에 관한 사항과 조사 결과에 대한 처리 기준 및 시정지시에 관하여 명확한 법률의 근거가 필요하다.

강제수사의 경우 기본적으로는 형사소송법의 규정이 적용될 것이지만, 근로관의 업무 수행과 관련하여 형사소송법과 달리 규정할 필요가 있는 사항이 있다면 근로감독관에 관한 법률에서 이를 규정하는 것을 고려할 필요가 있다.

¹⁴⁸⁾ 서울행정법원 2018. 3. 30. 선고 2017구합83805 판결 등.

VI. 근로감독에 관한 근거 법률안 제시

1. 근로감독에 관한 법률안의 구체적 내용

근로감독관에 관한 법률안은 기본적으로 현행 「근로기준법」 제11장의 규정을 기본구성으로 하면서, 「근로감독관집무규정」의 내용 중 법률의 차원에서 규율이 필요한 부분을 「근로기준법」에서 규정하고, 구체적인 절차나 내부적인 처리 기간 등에 대해서는 하위 법령에서 규정하도록 하는 방식이 될 것이다. 또한 근로감독에 관한 지원이나 정보시스템 구축·운영 등 「근로감독관집무규정」에서 규정하고 있지 않은 사항에 대해서도 필요한 사항은 추가적으로 검토한다.

가. 근로감독에 관한 지원과 정보시스템 구축·운영 등

근로감독의 효율화 기타 근로감독관 역량 강화 등을 위하여 현재 시급하게 요청되는 것은 재정적·행정적 지원 및 정보시스템 구축·운영 등이라고 볼 수 있다. 또한 근로감독관의 효율적인 업무 수행을 위해서는 다른 국가기관으로부터 정보를 제공받을 필요가 있다. 그런데 개인정보에 해당하는 정보는 개인정보보호법에 따라 수집·이용이 제한되고 있으므로, 정보의 제공에 있어 개인정보 보호의 관점을 고려하여야 한다. 개인정보보호법 제15조 제1항 제2호는 “법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우”에는 개인정보를 수집하고 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있도록 하고 있으며, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률, 행정심판법, 병역법 등에서 자료의 제출 요구 등에 관한 규정을 두고 있다. 근로감독관의 경우에도 근로감독을 위한 사업장 정보 등을 요구할 수 있는 법률상 근거를 규정할 필요가 있다.

근로감독관의 업무를 보조하기 위해 근로감독관과는 별도로 권리구제지원관을 두어 임금체불 등 신고사건의 사실관계 확인, 심층상담 및 조정 등 업무를 수행하도록 하는 등 민간지원제도를 운영하고 있는데, 현재 이에 관한 법률의 근거는 두고 있지 않다. 근로감독관이 수행하는 업무와 일부 유사한 업무를 수행하고 있다는 점에서 권리구제지원관의 근거 및 직무에 대해서도 법률에서 기본적인 사항을

규정할 필요가 있다.

위와 같은 내용을 위한 법적 근거를 다음 같이 성안해볼 수 있다.

제00조(근로감독에 관한 지원) 국가는 근로감독행정의 효율화 기타 근로감독관의 역량강화 등을 위하여 필요한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다.

제00조(자료의 제출 요구 등) ① 고용노동부장관은 관계 중앙행정기관, 지방자치단체 및 관련 기관·단체에 근로감독행정 정보시스템의 운영에 필요한 정보의 제공이나 관련 전산망 이용을 요청하고 제공받은 목적의 범위에서 보유·이용할 수 있다. 이 경우 자료의 제공을 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 감독관은 사업장감독 또는 신고사건의 처리와 관련하여 필요한 경우 관계 기관이 보관 중인 자료의 제공이나 관련 전산망 이용을 요청할 수 있다.

② 관계 기관의 장 등 제1항에 따른 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다.

제00조(권리구제지원관) ① 지방관서에 노동관계법령 관련 분쟁과 관련하여 사실관계 확인 및 조사, 임금체불의 청산업무 등 권리구제 지원 등을 위하여 권리구제지원관을 둘 수 있다.

② 권리구제지원관의 자격, 임면, 직무 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제00조(근로감독행정 정보시스템 구축·운영) ① 고용노동부장관은 근로감독관의 직무가 효율적으로 집행될 수 있도록 근로감독행정 정보시스템을 구축·운영한다.

② 고용노동부장관은 근로감독행정 정보시스템 구축·운영의 전 과정에서 개인정보 보호를 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.

③ 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 제2항의 근로감독행정 정보와 관련하여 근로감독행정 정보시스템의 활용이 필요한 경우 사전에 고용노동부장관과 협의하여야 한다. 이 경우 고용노동부장관은 관련 업무에 필요한 범위에서 정보를 제공할 수 있고 정보를 제공받은 관계 중앙행정기관 및 지방

자치단체의 장은 제공받은 목적의 범위에서 보유·이용할 수 있다.

- ④ 고용노동부장관은 근로감독행정 정보시스템의 운영·지원을 위하여 전담기구를 설치할 수 있다.

제00조(노동행정포털 구축·운영) ① 국민이 노동 관련 민원을 신청하고, 노동 행정 정보에 쉽고 신속하게 접근할 수 있도록 근로감독행정 정보시스템과 연계하여 노동행정 서비스 포털을 구축·운영한다.

- ② 민원인에게 민원 처리 결과를 통지할 때에는 「민원 처리에 관한 법률」 제27조제2항 규정에 따라 노동행정포털을 통한 전자문서로 통지할 수 있다.

나. 근로감독관의 직무에 관한 규정

근로감독관의 직무는 근로감독관에 관한 가장 기본적인 사항임에도 현행 「근로기준법」에서는 근로감독관의 직무에 관한 규정을 두고 있지 않으며 직무에 관한 사항을 하위 법령에 위임하는 근거규정을 두고 있지 않다. 따라서 법률의 차원에서 근로감독관의 직무를 규정하여 근로감독관의 직무 범위를 명확히 할 필요가 있다.

제00조(근로감독관의 직무) ① 근로감독관(이하 "감독관"이라 한다)은 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 노동관계법령과 그 하위규정의 집행을 위한 다음 각 목의 업무

가. 사업장 근로감독

나. 신고사건의 접수 및 처리

다. 각종 인·허가 및 승인

라. 취업규칙 등 각종 신고의 접수·심사 및 처리

마. 과태료 부과

2. 노동관계법령 위반의 죄에 대한 수사 등 사법경찰관의 직무

3. 노동조합의 설립·운영 등과 관련한 업무

4. 노사협의회의 설치·운영 등과 관련한 업무

5. 노동동향의 파악, 노사분규 및 집단체불의 예방과 그 수습지도에 관한 업무

6. 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합의 설립·운영 및 사내·공동근로복지기금의 설립·운영 등과 관련한 업무
 7. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자퇴직공제사업의 운영 등과 관련한 업무
 8. 「파견근로자보호 등에 관한 법률」(이하 ‘파견법’이라 한다)에 따른 파견사업의 적정한 운영과 파견근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무
 9. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 관한 업무
 10. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무
 11. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 "기간제법"이라 한다)에 따른 기간제 및 단시간근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무 <개정 2012.7.31>
 12. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제1장의2(고용상연령차별금지)의 적용과 위반사항 조치에 관한 업무
 13. 「임금채권보장법」에 따른 근로자의 임금채권보장에 관한 업무 <개정 2016.3.8.>
 14. 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 사업의 적정한 운영과 가사근로자의 근로조건 보호 등과 관련한 업무 <신설 2023.7.24.>
 15. 그 밖에 노동관계법령의 운영과 관련하여 고용노동부장관(이하 "장관"이라 한다)이 지시하는 업무
- ② 본 장에서 "노동관계법령"이란 「사범경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제6조의2제1항에서 정한 법률(「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」은 제1장의2의 적용과 위반사항 조치에 관한 업무에 한정한다)과 그 하위법령을 말한다.

다. 출석요구 및 보고요구에 관한 규정

출석요구나 보고요구는 그와 같은 요구를 받은 사람에게 출석 또는 보고 의무를

부과하게 된다는 점에서 법률에 근거를 두어야 하고, 기본적인 절차 등에 대해서도 법률에서 규정할 필요가 있다. 이를 통해 출석 및 보고요구의 실효성도 제고할 수 있을 것이다.

제00조(출석요구) ① 감독관은 직무와 관련하여 피의자·참고인 등 관계인의 출석을 요구할 수 있다.

② 출석요구서는 그 내용이 공개되지 않도록 봉합하여 발부하여야 한다. 다만, 관계인의 사생활이 침해되거나 명예가 손상되지 않는 범위 내에서 전화·모사전송 그 밖의 방법으로 할 수 있다.

③ 고소·고발·범죄인지 사건의 피의자신문 등 당사자의 출석이 불가피한 경우를 제외하고는 대리인의 출석을 허용하여야 하며, 대리인으로부터 반드시 위임장을 제출받아 관계 사건기록에 첨부하여야 한다.

④ 감독관은 출석요구를 받은 사람이 「초·중등교육법」에 따른 중학교·고등학교에 재학 중인 18세 미만의 근로자인 경우 방과 후 시간 또는 휴일 등 학교 수업에 지장이 없는 시간대에 출석하여 조사를 받게 할 수 있다.

제00조(보고요구) ① 감독관은 제2조제1항의 직무와 관련하여 사업장 또는 관계인에 대하여 보고를 요구할 때에는 담당감독관 명의의 보고요구서를 발부하여야 한다.

② 보고요구에 관하여는 제00조의 출석요구에 관한 규정을 준용한다.

라. 사업장감독에 관한 규정

사업장감독은 근로감독관의 본질적인 업무이므로 이에 관한 기본적인 사항은 법률에서 규정하여야 할 것이다. 또한 감독결과에 따른 시정지시는 그 자체로 행정처분이라고 보기는 어렵다고 하더라도 사업주에 대한 사실상 구속력을 가진다고 할 수 있으며, 범죄인지와 과태료 부과 등 공권력의 행사에 해당한다는 점에서 감독결과의 조치 기준 역시 법률에서 명확히 규정하는 것이 필요하다.

제00조(사업장감독) ① 사업장 근로감독(이하 "사업장감독"이라 한다)이란 감독

관이 근로조건의 기준을 확보하기 위하여 사업장, 기숙사 그 밖의 부속건물을 현장조사하여 노동관계법령 위반 여부를 점검하고 법 위반사항을 시정하도록 하거나 행정처분 또는 사법처리하는 일련의 과정을 말한다.

② 사업장감독의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정기감독: 고용노동부장관이 수립한 사업장근로감독종합(세부)시행계획에 따라 실시하는 근로감독
2. 수시감독: 사업장근로감독종합(세부)시행계획이 확정된 이후 정기감독계획에 반영하지 못한 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업장 또는 업종을 대상으로 별도의 계획을 수립하여 실시하는 근로감독
가. 동향, 제보, 언론보도 등을 통하여 노동관계법령 위반 가능성이 있다고 판단되는 사업장
나. 근로감독 청원 등이 접수되어 사업장 감독이 필요하다고 인정되는 사업장
다. 제3장에 따른 신고사건을 처리하는 과정에서 해당 사업장의 다수의 근로자에 대한 노동관계법령 위반의 가능성이 있다고 판단되는 사업장
라. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 있는 사업장 또는 업종에 대하여 지방관서에서 자체 계획을 수립하거나, 본부에서 수시감독 계획을 시달한 경우
3. 특별감독: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업장에 대하여 노동관계법령 위반사실을 수사하기 위해 실시하는 근로감독
가. 노동관계법령·단체협약·취업규칙 및 근로계약 등을 위반하는 중대한 행위로 인하여 노사분규가 발생하였거나 발생 우려가 큰 사업장
나. 상습·고의적 체불, 불법파견, 비정규직에 대한 차별적 처우, 폭언·폭행 및 직장 내 성희롱·괴롭힘 등 노동관계법령을 위반하는 중대한 행위로 다수의 피해자가 발생하거나 발생 우려가 있어 언론에 보도되는 등 감독 필요성이 상당한 사업장
다. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 발생할 우려가 있는 사업장에 대하여 본부에서 특별감독계획을 시달한 경우

제00조(감독결과 조치) ① 감독관은 사업장감독 결과 확인된 위법사항에 대하여는 대통령령으로 정하는 위반사항 조치기준에 따라 처리하되, 다음 각 호

의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 범죄인지 또는 과태료 부과 조치를 하여야 한다.

1. 특별감독 결과 위법사항을 확인한 경우
2. 감독실시일 기준 최근 3년간 근로감독결과 동일한 사항을 다시 위반한 경우
3. 근로조건 자율개선 지원을 받은 사용자가 점검결과를 허위로 보고한 경우
4. 고의 또는 중과실로 주요 근로조건을 위반하여 사회적 물의를 일으켜 즉시 범죄인지 또는 과태료 부과가 필요하다고 판단되는 경우

② 감독관은 감독결과 보고 즉시 시정지시서에 위반 법 조항, 시정지시 내용, 시정기한 등을 구체적으로 적시하여 사용자에게 발부하여야 하며, 사용자로 하여금 시정지시서를 사업장의 근로자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고, 이에 대한 증빙자료를 제출하도록 지도하여야 한다.

③ 사업장감독을 진행하는 과정에서 건설회사가 「건설산업기본법」 제16조, 제25조, 제29조 등을 위반하여 동법 제2조제7호에 따른 건설업자가 아닌 자에게 하도급한 사실을 확인한 경우에는 관련 사실을 해당 건설회사의 건설업 등록 행정기관에 통보하여야 한다.

마. 신고사건의 처리에 관한 규정

신고사건의 조사는 수사절차와 유사한 측면이 있으며, 신고사건의 처리 결과 형사사건으로 진행될 수도 있다는 점에서 조사 절차와 방법, 조사 결과에 따른 처리 기준 등에 관한 기본적인 사항은 법률에 규정할 필요가 있다. 법률에서 신고사건 조사에 관한 사항을 규정하여 근로감독관 권한의 근거를 명확히 하고 국민들이 근로감독관의 조사에 관한 내용을 명확히 알 수 있도록 할 필요가 있다.

제00조(신고사건의 정의) "신고사건"이란 사업 또는 사업장에서 노동관계법령의 위반행위로 권익을 침해당한 자 또는 제3자(이하 "신고인"이라 한다)가 그 위반사항(이하 "신고내용"이라 한다)에 대하여 문서·구술·전화·우편·기타의 방법으로 행정관청에 진정·청원·탄원·고소·고발 등을 한 사건을 말한다.

제00조(신고사건 심사위원회) ① 기피 신청에 대한 수용 여부의 결정 및 재신고 사건에 관한 사건처리 방법 및 내용에 관한 심사를 위해 지방관서에 신고사건 심사위원회를 둔다.

② 신고사건 심사위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 5인 이내의 위원(외부 위원을 1명 이상 포함한다)으로 구성하되, 위원장은 지방관서장으로 한다.

1. 대학교수·변호사·공인노무사 등 노동관계법 분야에 전문적 지식과 경험이 있는 사람
2. 지방관서장, 노사상생지원과장, 근로문화개선지원과장, 근로개선지도과장, 광역근로감독과장, 고용센터 소장 또는 과장

③ 신고사건 심사위원회는 필요하다고 판단되는 경우 신고인을 참석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 신고인의 사정으로 참석이 어려운 경우 우편, 팩스 등을 통해 의견을 제출하게 할 수 있다.

제00조(사건조사의 회피) 감독관은 신고인, 피신고인과의 친족관계 또는 그에 준하는 특별한 관계로 인하여 사건 조사의 공정성을 의심받을 우려가 있는 사건에 대하여는 해당 사건의 조사를 담당하지 않아야 한다.

제00조(사건조사의 기피) ① 신고인 또는 피신고인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 담당 감독관의 기피를 신청할 수 있다.

1. 감독관이 제00조의 사건 조사 회피 사유에 해당되는 때
2. 감독관이 사건 청탁, 방어권 침해 등 불공정한 조사를 하였거나, 불공정한 조사를 할 우려가 있다고 불만한 객관적·구체적 사정이 있는 때

② 기피 신청서가 제출된 때에는 기피 신청을 한 신고인 또는 피신고인에게 기피사유를 소명하도록 요청할 수 있고, 이 경우 기피 신청자는 3일 이내에 기피사유를 서면으로 소명하여야 한다.

③ 기피 신청 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청을 각 하한다.

1. 기피 신청 대상 사건이 종결되거나 송치된 경우
2. 동일한 사건에 대하여 이미 기피 신청이 있었던 경우
3. 제1항에 따른 신고인 또는 피신고인이 아닌 자가 기피 신청을 한 경우

4. 제2항에 따른 기피사유에 대한 소명이 없는 경우

- ④ 기피 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 사건 담당 감독관을 재지정하여 사건을 처리하도록 하여야 한다.
- ⑤ 기피 신청 내용에 대해 별도의 심의가 필요하다고 판단되는 경우에는 신고 사건 심사위원회를 개최하여 기피 신청에 대한 수용 여부를 결정하여야 한다.
- ⑥ 기피신청의 처리 결과에 대해 기피 신청자에게 통보하여야 한다.

제00조(사건의 관할 및 이송) ① 신고사건은 해당 사건이 발생한 사업장을 관할하는 지방관서장이 처리하여야 한다. 다만, "사업 또는 사업장"(법인의 경우 수 개의 지점·지사·출장소 등이 장소적으로 분리되어 있다 하더라도 원칙적으로 법인 전체를 하나의 "사업 또는 사업장"으로 본다)이 폐지하였거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주된 사업장의 소재지를 관할하는 지방관서에서 처리하여야 한다.

1. 사업주가 「임금채권보장법」 제7조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우

2. 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「문화재수리 등에 관한법률」에 따라 등록을 하지 아니한 사업자(등록을 필요로 하지 아니하는 사업자도 포함한다)가 시공한 공사가 완공되거나 중단된 경우

② 제1항 단서에 따른 주된 사업장의 소재지는 사업자등록지로 하고, 사업자등록지가 아닌 장소에서 사업을 하는 경우에는 실제 사업을 영위하는 장소로 한다. 다만, 주된 사업장을 두고 있지 않는 경우에는 해당 사업주의 마지막 주소지(주민등록 말소 여부와 무관하다)로 하되, 실제 거소지가 확인된 경우에는 실제 거소지로 한다.

③ 제1항에도 불구하고 피신고인이 동일한 신고사건으로서 둘 이상의 지방관서의 관할에 속하거나, 신고인이 원거리 거주 등의 사유로 다른 지방관서에서 사건처리를 희망한 경우에는 지방관서장간 사전 협의를 거쳐 사건을 이송할 수 있다.

④ 관할이 아닌 사건을 접수한 지방관서는 해당 사건을 근무시간 내에 관할 지방관서로 이송하되 신고인이 원하는 경우에는 빠른 시일 내에 신고인에 대

한 조사를 마친 후 사건관할 지방관서로 이송하여야 한다.

제00조(사건의 병합) 「형사소송법」 제11조와 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제14조에 해당하는 사건은 병합하여 처리할 수 있다.

제00조(사건의 조사) ① 감독관은 신고사건을 처리하도록 지정받은 때에는 신고인의 신고내용에 대하여 신속·친절·공정·정확히 조사·처리하여야 한다. 다만, 신고내용이 전체 근로자에 관한 사항이거나 신고내용의 조사결과 신고인 외의 다수 근로자도 동일내용의 법 위반으로 피해를 입고 있다고 판단된 경우에는 신고내용 이외의 사항에 대하여도 조사를 할 수 있다.

② 감독관은 신고내용의 조사를 위하여 필요한 경우에는 당사자 그 밖의 참고인에게 출석을 요구할 수 있다.

③ 감독관이 제2항에 따라 당사자 등에게 출석을 요구하는 때에는 출석요구서를 발부하여야 한다. 다만, 신속한 출석요구 등을 위하여 필요한 경우에는 전화, 모사전송, 그 밖의 상당한 방법으로 출석요구를 할 수 있다.

④ 신고내용에 대한 조사는 진술조서 및 자술서 작성, 관련서류 사본의 징구 및 현장조사 등 사실조사에 필요하고 적절한 최소한의 방법을 택하여야 하며, 사실조사는 당사자가 공동날인한 사실확인서의 징구로 갈음할 수 있다

⑤ 신고사건 관할 지방관서장은 필요한 경우에 다른 지방관서장에게 사건과 관련한 특정사실의 조사 또는 소재수사를 의뢰할 수 있다. 이 경우에 의뢰받은 지방관서장은 지체 없이 조사 또는 소재수사하여 회보하여야 한다.

⑥ 고소·고발사건 이외의 사건으로서 피신고인이 법 위반사실을 시정할 의사를 표시하는 경우 출석조사를 생략하고 14일 이내의 기간을 주어 자율적으로 해결하도록 지도할 수 있다.

⑦ 고용노동부장관은 노동사건을 조사 또는 처리하는 과정에서 필요한 경우에는 지방관서의 장에게 관련 법령의 해석 및 적용 등에 관하여 지원 및 지시를 할 수 있다.

제00조(사건 유형별 조사 원칙) ① 직장 내 성희롱 사건은 전담 근로감독관이 나 피해자와 동일한 성(性)의 근로감독관이 조사하되, 피해자가 수치심을 느끼지 않고 조사에 응할 수 있도록 별도의 독립된 공간에서 조사하여야 한다.

- ② 직장 내 괴롭힘 사건은 전담 근로감독관 지정 등을 통해 조사하되, 피해자 등으로부터 구체적인 진술을 확보할 수 있도록 별도의 독립된 공간에서 조사하여야 한다.
- ③ 직장 내 괴롭힘 사건처리를 위해 지방관서장은 5명 이상 7명 이내의 위원(외부위원을 3명 이상 포함한다)으로 구성된 전문위원회를 설치하여 자문을 받을 수 있다.
- ④ 감독관은 사건관계인에 대하여 의사소통이나 의사표현에 어려움을 겪는 장애가 있는지 여부를 확인하고 그 장애인에게 형사사범 절차에서 조력을 받을 수 있음과 그 구체적인 조력의 내용을 알려주어야 하며, 신체적 또는 정신적 장애로 사물을 식별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에는 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제41조 등이 정하는 바에 따라 신뢰관계인이 동석하게 하는 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

제00조(간이진술제) ① 감독관은 신고인 및 참고인 등이 교도소 수감, 장기간 입원 등 출석하지 못할 사정이 있거나 다수 참고인으로부터 동일 또는 유사한 진술을 요하는 경우 등 필요한 때에는 조서작성에 갈음하여 우편진술서를 우편으로 제출하게 할 수 있다.

- ② 신고내용을 전화로 확인한 결과 내사종결이 예상되거나 당사자의 주장이 일치하는 경우 조서작성에 갈음하여 전화 등 사실확인내용을 작성할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 전화진술에 근거하여 범죄인지를 할 때에는 「전화 등 사실확인서」를 팩스·우편 등의 방법으로 진술인에게 송부하거나 방문하도록 하여 서명 또는 날인을 받아야 한다. 다만, 서명 또는 날인을 받을 수 없는 불가피한 사유가 있거나 서명 또는 날인을 받기 위해 최선의 노력을 다하였음에도 서명 또는 날인을 받지 못한 경우에는 그 사실을 기록한 후 범죄인지를 할 수 있다.

제00조(사건 조사결과에의 처리) ① 신고사건(고소·고발 및 범죄인지 사건은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 조사결과 법 위반사실이 확인되었을 때에는 대통령령으로 정하는 위반사항 조치기준에 따라 처리하여야 한다.

- ② 신고인의 신고내용 중 법 위반사실이 시정되었음이 확인되었을 때에는 그

사실을 신고인에게 회시하고 내사 종결 처리하여야 한다. 다만, 신고인이 시정되었음을 이유로 신고를 취하하였을 때에는 회시를 생략할 수 있다.

③ 법 위반 사실이 확인된 신고사건을 내사 종결 처리하는 경우 피신고인에게 비슷한 사건의 재발이 없도록 경고 또는 지도하여야 한다. 다만, 사업폐지 등으로 경고 또는 지도가 불필요하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 신고내용의 조사결과 법 위반사실을 발견할 수 없는 때에는 신고인과 피신고인에게 그 사유를 회시하고 내사종결 처리하여야 한다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고인이 신고의사가 없는 것으로 간주하여 신고인에게 이를 회시하고 내사종결 처리할 수 있다.

1. 감독관이 신고인의 진술을 듣기 위해 2회 이상 출석을 요구하였음에도 응하지 아니한 경우. 다만, 신고인·참고인 등에 대한 조사결과에 따라 법 위반사실이 확인되면 즉시 수사에 착수한다.

2. 신고인의 소재 불명 또는 수취거부 등으로 우편물이 2회 이상 반송된 경우

3. 신고인이 신고내용에 대해 서면, 통신기기 문자 또는 유선으로 신고의사가 없음을 명확히 표시한 경우

⑥ 신고인이 피신고인의 처벌 등 법에 따른 처리를 요구한 경우로서 법 위반 사실이 발견된 때에는 범죄인지보고 후 수사에 착수하거나 과태료를 부과하는 등의 조치를 하여야 한다.

제00조(반의사불벌죄의 처리) ① 감독관은 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없는 「근로기준법」 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제9조제1항, 제17조제2항·제3항, 제20조제5항, 제23조의7제2항, 제25조제3항 위반 사건에 대하여는 피해자에게 법 위반자에 대한 처벌을 원하는지 여부를 확인하여야 한다.

② 감독관은 제1항 및 제2항에 따라 반의사불벌죄가 적용되는 사건은 다음 각 호와 같이 사건조사 및 수사를 종료하여야 한다.

1. 진정사건(재진정을 포함한다) 등 내사사건의 경우에는 체불금액 및 청산여부와 관계없이 내사종결

2. 고소·고발(재고소·재고발을 포함한다) 및 범죄인지사건의 경우에는 "공

소권 없음" 의견으로 송치. 다만, 피의자에 대한 조사 없이 고소·고발장의 기재사실 또는 고소·고발인의 진술만으로도 처벌을 희망하지 아니하는 피해자의 의사를 확인할 수 있는 경우에는 "각하"의견으로 송치

제00조(재신고사건의 처리) ① 이미 처리한 사건(고소·고발사건 및 범죄인지사건은 제외한다)에 대하여 민원인이 이의를 제기하는 경우에는 다음 각 호 중 어느 하나의 방법에 따라 처리하여야 한다.

1. 담당 감독관을 변경하여 처리
2. 검사의 지휘를 받아 처리
3. 지방관서 내 사건유형별 전문위원회의 자문을 받아 처리

② 재신고 사건에 대해 별도의 심의가 필요하다고 판단되거나, 제1항에 따라 재신고사건을 처리하였음에도 불구하고 동일한 사건이 다시 접수된 경우에는 지방관서별 신고사건 심사위원회의 심사를 통하여 사건처리 방법 및 내용을 결정할 수 있다.

③ 신고사건 심의위원회에서 재신고 사건 처리방법 및 내용 등이 결정된 때에는 결정 결과와 이유를 상세히 작성하여 재신고인에게 서면으로 통지하여야 한다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 처리한 반복민원은 「민원처리에 관한 법률」 제23조를 준용하여 처리할 수 있다.

바. 수사에 관한 규정

형사소송법이 수사에 관한 사항을 규정하고 있으나, 근로감독관 업무의 특성을 고려하여 필요한 사항은 별도로 규정할 필요가 있다. 수사에 관한 사항 중 특히 강제수사와 경찰장구 사용 등에 관한 사항은 국민의 기본권이 미치는 영향이 크다는 점에서 법률에 근거를 두어야 한다.

제00조(범죄의 내사 및 범죄인지 기준) ① 감독관은 직무범위에 속하는 범죄에 관한 신문·방송 그 밖의 보도매체의 기사, 익명의 신고 또는 풍문이 있는 경우에는 내사할 수 있고, 범죄의 혐의가 있다고 인정되는 때에는 즉시 수사

에 착수하여야 한다.

② 감독관은 사업장감독 또는 신고사건 처리, 노동동향 파악 등 직무수행 중에 발견한 법 위반사실이 대통령령으로 정하는 위반사항 조치기준에 따라 시정이 필요한 경우에는 사용자에게 이에 대한 시정을 서면으로 지시하고, 기한 내 이행하지 아니한 때에는 즉시 범죄인지서를 작성하고 수사에 착수하여야 한다.

③ 제1항의 법 위반사실이 대통령령으로 정하는 위반사항 조치기준 중 "즉시 범죄인지"에 해당하는 경우에는 즉시 범죄인지서를 작성하고 수사에 착수하여야 한다.

제00조(사건의 수사) ① 감독관은 제45조에 따라 범죄를 인지하거나 고소·고발을 접수하였을 때에는 「특별사법경찰관리 수사준칙」이 정하는 바에 따라 범인과 범죄사실을 수사하고 그에 관한 증거를 수집하여야 한다.

② 감독관은 범죄를 수사하거나 그 수사를 보조하는 때에는 검사의 지휘를 받아야 한다.

③ 감독관이 범죄수사에 관하여 사용하는 문서와 장부는 「특별사법경찰관리 수사준칙」이 정하는 바에 따른다.

④ 감독관은 「형사소송법」 제241조부터 제243조까지, 제243조의2, 제244조, 제244조의2부터 제244조의5까지의 규정 및 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제44조에 따라 피의자를 신문하여야 한다.

⑤ 감독관은 「형사소송법」 제243조의2 및 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제10조와 제11조에 따라 정당한 사유가 없는 한 변호인을 참여하게 하여야 한다.

제00조(수사개시 통보 등) ① 감독관은 공무원에 대하여 수사를 개시하거나 종료(송치)한 경우에는 「국가공무원법」 제83조제3항 및 「지방공무원법」 제73조제3항에 따라 그 사실을 해당기관의 장에게 통보하여야 한다.

② 감독관은 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제25조제10호바목 및 같은 조 제11호에 해당하는 범죄에 대하여 수사를 개시했을 때에는 관할 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 보고하여야 한다.

제00조(범죄경력 조회) 감독관은 범죄를 인지하거나 고소·고발을 접수하여 수사에 착수한 경우 피의자의 범죄경력을 조회하여야 한다. 다만, 고소·고발사건 중 "혐의없음, 공소권없음, 죄가안됨, 각하, 참고인중지" 의견으로 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제00조(노동쟁의 중 불법행위에 대한 사법경찰권 행사) ① 감독관은 노동쟁의 과정에서 발생한 불법행위가 노동관계법이 아닌 형사법에 위반된다고 판단될 때에는 즉시 검사의 지휘를 받아 관할경찰이 수사하도록 통보하여야 한다.
② 감독관은 노동쟁의와 관련하여 고소·고발·진정을 받았을 때에는 지체 없이 조사하여야 하며, 그 내용이 형사법 위반인 때에는 즉시 검사의 지휘를 받아 관할경찰서로 이송하여야 한다.

제00조(수사공조) 감독관은 노동쟁의과정에서 발생한 불법행위가 노동관계법 위반의 죄와 형사법 위반의 죄가 경합될 경우에는(「형법」 제40조의 상상적 경합을 포함한다) 구속을 요하는 사건은 검사의 지휘를 받아 경찰과 공조수사하고 불구속사건은 각각 수사함을 원칙으로 한다.

제00조(구속영장 신청기준) ① 구속영장 신청 대상은 다음 각 호 각 목과 같다.

1. 근로기준법 위반

가. 재산은닉 등에 따른 체불행위

나. 3개월분 이상의 임금이 누적되어 체불되거나 1회의 체불기간이 30일 이상으로 연간 5회 이상의 체불을 하는 등 상습적인 체불로 인하여 노사분규를 야기한 경우

다. 근로자를 착취하는 반사회적 체불행위

라. 임금, 퇴직금 등을 집단체불하고 도주하였다가 검거되었을 경우

마. 폭행·협박·감금 등 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로서 근로자의 자유의사에 반하여 근로를 시킨 경우

바. 확정된 노동위원회의 부당해고 구제명령을 불이행하여 노동위원회로부터 고발이 있는 경우(부당해고 인원이 5명 이상인 경우에만 해당한다)

사. 여성과 18세 미만인 자를 도덕상 또는 보건상 유해위험한 사업에 사용한 경우

2. 노동조합 및 노동관계조정법 위반

가. 노동쟁의과정에서 법적 절차와 수단을 준수하지 아니하고 불법행위를 주동하는 경우

나. 부당노동행위가 중대·명백한 경우

② 감독관은 피의자가 제1항에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 검사에게 구속영장을 신청하여야 한다.

1. 피의자가 일정한 주거가 없는 때
2. 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때
3. 피의자가 도망하거나 도망할 염려가 있는 때

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 구속영장 신청을 하지 않아도 될 합리적인 사유가 있는 경우에는 구속영장을 신청하지 않을 수 있다.

제00조(경찰장구의 사용) ① 감독관은 체포·구속영장을 집행하여 호송하거나 수용하기 위하여 필요한 때에는 최소한의 범위 안에서 수갑·포승 또는 호송용 포승을 사용할 수 있다.

② 감독관은 노동관계법령을 위반한 피의자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 필요한 한도 내에서 수갑·포승 또는 호송용 포승을 사용할 수 있다. 이 경우 감독관은 지방관서장의 승낙을 받아야 하고, 긴급을 요하여 사전승낙을 받지 못할 경우에는 사용 후 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 범죄를 범한 자로서 도주하거나 도주하려고 할 때
2. 자살 또는 자해행위를 하고자 하는 때
3. 다른 사람에게 위해를 가하거나 가하고자 하는 때
4. 공무집행에 대한 항거의 억제를 위하여 필요하다고 인정되는 상당한 이유가 있는 때

제00조(피의자 출국금지·정지 및 해제) ① 감독관은 범죄 수사를 위하여 출국이 적당하지 않은 피의자 등에 대하여 근로기준정책관에게 출국금지(외국인의 경우 출국정지) 조치를 요청할 수 있다.

② 출국금지(정지) 기간은 1개월 이내로 요청할 수 있다, 다만, 다음 각 호에 해당하는 자는 그 호에서 정한 기간으로 한다.

1. 소재를 알 수 없어 기소중지 또는 도주 등 특별한 사유가 있어 수사진행이 어려운 경우는 3개월 이내
2. 기소중지된 경우로서 체포영장이 발부된 자는 영장 유효기간 이내

③ 출국금지(정지) 기간을 초과하여 계속 출국금지(정지)가 필요한 경우 출국금지(정지) 기간이 끝나기 7일 전까지 근로기준정책관에게 연장 조치를 요청할 수 있으며, 출국금지(정지) 사유가 없어진 경우에는 즉시 근로기준정책관에게 해제 조치를 요청하여야 한다.

제00조(입국 시 통보 및 해제) ① 감독관은 피의자가 국외로 출국한 경우 피의자의 성명, 국적, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호), 담당 감독관 연락처, 요청사유 등을 기재하여 근로기준정책관에게 입국 시 통보 조치를 요청할 수 있다,

② 감독관은 제1항에 따른 입국 시 통보 조치 요청 시 요청기간을 입국 시까지로 하며, 입국 시 통보요청 사유가 해소되었을 때에는 즉시 근로기준정책관에게 입국 시 통보 해제를 요청하여야 한다.

제00조(지명수배 · 통보 및 해제) ① 감독관은 소재가 불명한 노동관계법 위반 피의자에 대하여는 관할경찰관서에 지명수배 · 통보를 의뢰한 후 관련서류를 동 사건서류에 편철하여 기소중지 의견으로 검찰에 송치하여야 한다.

② 감독관은 제1항에 따라 지명수배 · 통보를 한 피의자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 관할 경찰관서에 지명수배 · 통보의 해제를 의뢰하여야 한다.

1. 피의자가 자수한 경우
2. 피의자가 검거된 경우
3. 공소시효가 만료된 경우
4. 사망 등으로 공소권이 소멸된 경우 등

제00조(지명수배자 신병인수 등 협조) ① 수배관서 담당감독관은 경찰관서에서 지명수배자 소재발견 통보가 있는 경우에 지체 없이 피의자의 신병을 인계받

아 조사를 실시하고 체포한 때부터 36시간 이내에 구속영장을 신청하거나 검사의 신병지휘를 받아야 한다.

- ② 관할지역 이외에 소재한 경찰관서에서 지명수배자 소재발견 통보가 있는 경우에는 그 경찰관서의 관할 지방관서장과 사전 협의하여 신병인수 및 피의자 조사 등을 의뢰할 수 있다. 이 경우에 의뢰받은 지방관서장은 적극적으로 협조하여야 한다.

제00조(수사자료표 작성) 감독관은 피의자에 대한 수사자료표를 작성하여야 한다. 다만, 「지문을 채취할 형사 피의자의 범위에 관한 규칙」 제2조제2항제1호·제2호 또는 제4호의 어느 하나에 해당하지 않은 경우로서 고소·고발사건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 혐의없음
2. 공소권없음
3. 죄가안됨
4. 각하
5. 참고인중지

제00조(사건의 송치) ① 감독관은 고소·고발사건과 노동관계법령 위반으로 범죄인지하여 수사한 사건은 수사완료 즉시 그 결과를 지방관서장에게 보고하여야 한다.

- ② 감독관은 「특별사법경찰관리 수사준칙」이 정하는 바에 따라 송치서류를 작성하고 관할 검찰청에 송치하여야 한다.

- ③ 감독관은 사건을 송치한 후 그 사실을 신고인과 피신고인에게 회시하여야 한다.

2. 근로감독에 관한 법률의 입법 방향

변화하는 고용관계에서 근로감독에 관한 기본적인 사항을 법률로 규정할 필요성이 있다. 근로감독관에 관한 별도의 법률을 제정하는 일은 새로운 법률의 제정이므로 법적 정합성의 검토 등 많은 논의과정을 거쳐야한다는 현실적인 고려에서 현

행 「근로기준법」 제11장에 근로감독에 관한 규정을 보완하는 규정을 신설하는 법 개정 방식을 우선적으로 고려할 필요가 있다.

「근로기준법」 제11장에 근로감독관에 관한 규정을 신설한다면 법률화가 가장 시급한 사항은 근로감독에 관한 지원 중 자료의 제출 요구에 관한 사항과 권리구제 지원관 등 민간지원에 관한 사항이다. 근로감독의 역량은 근로감독관의 수와 정보가 중요한 요소인데, 그 동안 근로감독관을 대폭 충원하여 근로감독관의 수는 어느 정도 확보가 되었으나 근로감독을 위한 정보 요청의 근거는 마련되어 있지 않다. 또한 권리구제지원관이 임금체불의 청산 등의 업무를 지원하고 있으나 이 역시 법에 근거를 두고 있지 않다. 따라서 최소한 위 사항은 조속히 「근로기준법」에 반영되도록 해야 한다.

그 외에도 근로감독에 관한 기본적인 사항은 법률에서 규정하여야 하므로, 「근로기준법」 제11장 안에 앞서 제안한 법률안과 같이 근로감독에 관한 구체적인 규정을 두도록 대폭 개정하는 방안도 적극적으로 검토할 필요가 있다.

장기적으로는 근로감독에 관한 별도의 개별법을 제정하여 근로감독에 관한 일반적인 법적 근거를 마련하면서 근로감독의 전문화·효율화를 도모할 수 있도록 해야 할 것이다.

참고문헌

- 고용노동부, 「고용노동백서 2023」, 2023. 7.
- 국회법제실, 「입법이론과 법제실무」, 국회사무처, 2008.
- 김 린, “근로감독기능의 지방자치단체 배분의 법적 한계 - 우크라이나 사례의 시사”, 「강원법학」 제69권, 강원대법학연구소, 2022. 11.
- 김동희, 「행정법 I」, 박영사, 2003.
- 노상현, “근로감독관제도의 재검토와 과제”, 「노동법학」 제42호, 한국노동법학회, 2012.
- 노호창, “근로감독에 관한 개별 근거 법률 제정에 관한 법적 검토”, 노동법연구 제54호, 서울대학교노동법연구회, 2023. 3.
- 노호창, “기본소득의 법적 고찰”, 사회보장법학 제9권 제1호, 2020. 6.
- 노호창, “대만의 형사법 체계의 입법적 개관 및 주요 특징”, 「법학논총」 제41권 제4호, 전남대 법학연구소, 2021.
- 노호창, “실업으로부터 노동자 보호에 관한 스페인의 법제도적 대응에 관한 연구”, 「노동법학」 제85호, 한국노동법학회, 2023. 3.
- 대검찰청, 「노동법 별칙해설 I」, 2019.
- 대검찰청, 「산업안전보건법 별칙해설」, 2020.
- 賴怡欣·노호창, “대만 노동기준법과 기업인수·합병법상의 고용승계결정권에 대한 소고”, 「노동법연구」 제52호, 서울대노동법연구회, 2022 상반기.
- 박균성, 「행정법강의」, 박영사, 2007.
- 박정훈, 「행정법의 구조와 기능」, 박영사, 2006.
- 박준희 외, 「특별사법경찰에 관한 연구(I)」, 한국형사·법무정책연구원, 2022. 12.
- 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2006.
- 임종휘·박수철, 「입법과정론」, 박영사, 2006.
- 장태주, 「행정법개론」, 현암사, 2004.
- 정병하·임정호, 「특별사법경찰 조직의 전문화 방안에 관한 연구」, 한국형사정책연구원, 2009. 9.
- 홍준형, 「행정법총론」, 한울아카데미, 2001.

前田貴洋, “労働監督制度をめぐる戦前と戦後(2)”, 都法 제58권 제2호, 2018.1.

渡辺章, “工場法史が今に問うもの”, 日本労働研究雑誌 제562호, 2007.5.

劉志鵬, 勞動三法實施十周年之回顧與展望(노동3법 실시 10주년의 회고와 전망), 樂說頭條, 台灣勞工季刊 NO. 68, 勞動部, 2021. 12.

대만 勞動檢查統計年報中華民國110年(근로감독통계연보 2021년), 勞動部職業安全衛生署, 2022. 7

공장법(1911년 제정, 1916년 시행)
(
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F00000000000000006288&ID=M00000000000001748214&NO=&TYPE=imagePrint&DL_TYPE=pdf, 일본 국립공문서관, 최종방문 2023. 2. 28.)

국제노동기구 한국비준현황
(
https://www.ilo.org/gateway/faces/home/standards?_adf.ctrl-state=7tbctp9re_9&locale=EN&countryCode=KOR, 최종방문 2023. 10. 27)

대만 ‘근로감독관 선발 및 전문직무훈련에 관한 시행령’
(
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070006&kw=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e5%93%a1%e9%81%b4%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%b0%88%e6%a5%ad%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%be%a6%e6%b3%95>, 대만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만 ‘근로감독법 제28조에 따른 노동자에 대한 즉각적인 위험발생 우려의 인 정 기 준’,
(
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070016&kw>

=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e6%b3%95, 대
만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만
(
[https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070001&kw=
=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e6%b3%95](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070001&kw=%e5%8b%9e%e5%8b%95%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e6%b3%95), 대
만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만
근로감독법시행세칙
(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070004>, 대
만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만
노동기준법
(<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=N0030001>, 대
만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만
노동부
통계자료
(
<https://www.mol.gov.tw/media/dccoluhq/3-%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%97%9C%E4%BF%82.pdf>, 최종방문 2023. 2. 28.)

대만
지방제도법
(
[https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0040003&kw=
=%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%b3%95](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0040003&kw=%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%b3%95), 대
만법률정보, 최종방문 2023. 2. 28.)

大原クロニカ, 「社会・労働運動大年表」解説編, 工場監督官[政]
1 9 1 5 . 1 2 . 2 5 .
(http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/khronika/1911-15/1915_17.html)

스페인 2012년 ‘노동시장개혁을 위한 긴급조치에 관한 왕실 명령법’에 의한
개정 근로자헌장법 내용
(<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-2076>, 최종방
문 2023. 2. 28.)

스페인
근로감독법

(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168>, 최종방문 2023. 2. 28.)

스페인 디지털플랫폼 영역에서 배달에 종사하는 사람의 노동권을 보장하기 위하여 왕실입법령에 의해 승인된, 근로자헌장법 개정 (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15767>, 최종방문 2023. 2. 28.)

스페인 자영노동헌장법 (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409>, 최신 개정 2022. 9. 7, 최종방문 2023. 2. 28.)

일본 노동기준법 (<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00000000049>, 일본 법령검색, 최종방문 2023. 2. 28.)

[부록] 노동기준감독관 직무규정

대외비(部外秘)

노동기준감독관 직무규정

(1950. 3. 제정)

노동성 노동기준국

목차

제1장 총칙

제1절 감독관의 사명

제2절 감독관의 일반직무방법

제2장 감찰감독관의 사명과 직무방법

제3장 감독관의 교양, 훈련

제1절 통칙

제2절 「총칙」

제3절 「근로계약」

제4절 「임금」

제5절 「근로시간, 휴게 휴일 및 연차유급휴가」

제6절 「안전 및 보건」

제1관 안전

제2관 보건

제7절 「여성 및 연소자」

제8절 「기능자 양성」

제9절 「재해보상」

제10절 「취업규칙」

제11절 「기숙사」

제12절 「잡칙」

제5장 재감독

제6장 신고에 의한 감독

제7장 재해조사

제8장 사법경찰사무

제9장 허가, 인가, 인정, 심사, 중재 및 신고 수리사무

제10장 감독양식

부칙 노동기준감독관규정

노동기준감독관 직무규정

제1장 총칙

제1절 감독관의 사명

제1조 노동기준감독관(이하 ‘감독관’이라 한다)이 감독업무 그 밖의 직무를 수행함에 있어서 법령과 통지에 의하는 이외, 이 규범에 따라야 한다.

제2조 감독관의 제일의 사명은 무엇보다 우선 노동기준법(이하 ‘법’이라 한다) 관계법령의 시행을 통하여 근로자의 근로조건을 확보하는 것으로서 공공의 사회적 경제적 이익을 증진하고, 이로써 국민전체에 대한 봉사하는 데에 있다.

제3조 감독관은 법령의 입법취지와 법률의 해석을 숙지하여야 하며, 법령의 완전한 시행이 근로자의 이익뿐만 아니라 사용자의 이익 내지 공공의 복리에도 합치한다는 것을 명확히 인식하고, 모든 기회에서 근로자 또는 사용자에 대하여 이를 철저히 인식하도록 하여야 한다.

제4조 감독관은 감독업무의 실시에 관해서 근로자의 실질적 권리 확보에 중점을 두고, 원만한 상식과 선의로서 항상 법령 내에서 행동하여야 하며, 노사쌍방의 납득과 협력으로써 법령이 자발적으로 준수되도록 노력하여야 한다.

제5조 감독관은 개인의 권위가 아니라 국가의 법령에 따라 권한을 가지는 자로서 그 임무를 수행함을 명심하여야 한다.

제6조 ① 감독관은 노사쌍방에 대하여 근로자의 안전, 건강, 복지의 확보를 도모하며, 또한 기능을 향상하여 능률을 증진시키는 수단과 방법을 권고, 조언하는 등의 중요한 사명을 가지고 있으므로 일상의 집무가 단순한 법령의 시행에 그치지 아니하도록 주의하여야 한다.

② 감독관은 법령 시행 이외에 임무를 수행함에 있어서는 감독과 권고, 조언 그 밖의 조치와의 구별을 명확히 하여야 하며, 부주의하게 강제로 행하여서는 아

니 된다.

제7조 감독관은 법령의 단속에 그치지 아니하고, 전문적 기술과 지식의 습득에 노력하며, 그 전문적 기술과 지식을 활용하여 사용자의 이익을 증진하도록 노력하여야 한다.

제8조 감독관은 노무관리, 복지시설의 운영 그 밖에 대하여 항상 참고자료 수집에 노력하며, 그것을 관련자에게 제공하는 방법 등으로 원조하도록 유의하여야 한다.

제9조 감독관은 감독업무 그 밖의 직무가 책상 위에서 처리되는 것이 아니라 발을 사용하지 아니하며 효과가 오르지 아니한다는 것을 명심하여야 한다.

제10조 감독관은 그 사명을 원만하게 수행하기 위하여 항상 일반 근로조건의 움직임이나 산업경제의 흐름 등에 유의하여야 한다.

제8장 사법경찰사무

제337조 감독관은 근로자의 권리를 구제하기 위하여 감독상 권한으로 부여하지만, 노동기준법 위반사실에 대한 사법사건의 처리에 대해서는 감독관으로서의 권한 행사가 아니라 형사소송법에 기한 사법경찰관으로서 권한을 행사함을 명확하게 인식하고, 그 권한 행사를 혼동하지 아니하도록 하여야 한다.

제338조 감독관은 한편으로 인권존중의 헌법 정신에 반하지 아니하고, 다른 한편으로는 법의 엄정한 유지를 위하여 끊임없이 관할 지방검찰청 검찰간과 밀접하게 연락을 유지하고, 부주의하게 위법한 처리가 없도록 하여야 한다.